المملكة المغربية
جامعة عبد المالك السعدي
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية
طنجة

بحث لنيل دبلوم الإجازة في القانون الخاص بعنوان :

التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه - جائحة كورونا نموذجا-

تحت إشراف الدكتورة لبنى الغومرتي

من إعداد الطالبة الباحثة : ياسمين حرودي HARROUDI Yasmine

السنة الجامعية : 2021/2020

إهداء

إلى من قال فيهما سبحانه و تعالى :

باسم الله الرحمن الرحيم

"و قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا"

إلى رمز العطف و الحنان و المساندة الدائمة أبي و أمي و جدتي أطال الله في عمرهم و أسدل عليهم ثياب الصحة و العافية و أبقاهم رمزا للتحدي و عونا لي في السراء و الضراء.

شكر و تقدير

إذا كان لا بد لكل عمل متكامل من تضافر جهود متعددة توفر له أسباب الدعم و النجاح فانني أعترف و باعتزاز كبير بفضل أولئك الذين قدموا لي يد المساعدة بأشكالها المختلفة من أجل البحث وأرى أنه من واجبي أن أتقدم بالشكر و الامتنان للدكتورة الفاضلة أستاذتي **لبنى الغومرتي** التي أشرفت على هذا البحث، على سعة صدرها و تواضعها و على ملاحظاتها النيرة التي قدمتها لي طيلة فترة البحث، والتي لم تبخل عني أبدا لا بوقتها أو توجيهها أو إرشاداتها القيمة التي قومتني ووجهتني و سهلت لي إخراج هذا البحث بالشكل المطلوب.

و أن تلك التوجيهات و النصائح القيمة ستبقى لي دوما عونا نحو كل خطوة أخطوها في المستقبل للوصول إلى تحقيق كل هدف علمي نبيل في مجال دراستي.

فإليها أتقدم بخالص الشكر و عظيم التقدير.

شكرا

مقدمة

مقدمة

إن الطابع الاجتماعي للفرد لا يخول لأي كان ، مهما أوتي من علم ومال أن يعتمد على نفسه في تدبير جميع شؤون معيشته نظرا لتعدد حاجياته وتنوع متطلباته، لذلك كان لابد من أن يتعامل مع أفراد آخرين لتحصيل تلك الحاجات وتدبير تلك المتطلبات، وهذه حكمة الله في خلقه من أجل تحقيق التكامل والتلاحم بين بني البشر. ولأن الفرد أناني بطبعه فهو يهدف إلى تحقيق مصلحته الخاصة دون مراعاة مصلحة الأفراد الآخرين، لذلك استدعى الأمر إيجاد وسيلة مشتركة وفعالة تضمن قيام الفرد بالوفاء بما التزم به مع ضمان حقه في الحصول على المقابل، وقد اهتدى العقل البشري إلى العقد كوسيلة لتحقيق ذلك.

يلعب العقد دورا هاما في ميدان الحياة باعتباره أداة للتعامل بين الأفراد إذ يحقق تبادل المنافع بطريقة عادلة تتفق مع السلوك الحضاري للفرد، لأن الوضع في السابق كان يتسم بالفوضى. كما يلعب العقد دورا بارزا في تقدم الشعوب إذ يساهم في النهوض بالاقتصاد وبالتالي تطور المجتمع. و يقوم العقد على أساس الإرادة التي تنشئه وتحدد مضمونه وآثاره، ونظرا لأهمية الإرادة ودورها في إنشاء الالتزام العقدي فقد ظهرت كمبدأ هام سمي بمبدأ بسلطان الإرادة، هذا الأخير نشأ في ظل النظام الفردي الذي يمجد الفرد ويكرس حريته. ويتجلى دور الإرادة في تكوين العقد و آثاره، ففيما يتعلق بتكوين العقد فيظهر دور الإرادة في حالة إبرام العقد إذ تكفي الإرادة وحدها لإنشاء العقد دون الحاجة إلى شكلية معينة، فالأصل في العقود هو مبدأ الرضائية، ويخرج عن ذلك كاستثناء ما يتطلبه القانون كشكلية معينة في بعض العقود، أما بالنسبة لمضمون العقد فيتجسد دور الإرادة في حرية الأفراد في إبرام ما يشاءون من العقود وتحديد مضمونها، وهم غير مقيدين في ذلك سوى بالاعتبار المتعلق بالنظام العام والآداب العامة.

أما فيما يتعلق بآثار العقد فيستخلص من مبدأ سلطان الإرادة نتيجة هامة و هي مبدأ القوة الملزمة للعقد التي عبر عنها المشرع ب"العقد شريعة المتعاقدين" إذ تتمخض عن تلاقي الإرادتين رابطة إلزامية بينهما تحتم على أصحابها تنفيذ ما اشتمل عليه العقد، فهو شريعتهم التي لا يستطيع أحدهما من حيث الأصل أن يعدل أو يفسخ محتواه بإرادته المنفردة.

إن القاعدة في العقد تقضي بأن هذا الأخير وجد لينفذ، فكلا المتعاقدين علقا وجوده على تحقيق مصالحهما، ويستوجب في تنفيذ العقد أن يتم بحسن النية، فيقتضي اختيار الوسائل التي تتفق مع الأمانة والنزاهة كما يقتضي التعاون بين أطراف العقد ويعتبر العقد خير وسيلة لقيام علاقة أكثر عدلا بين الأطراف، لأنه أداة تندمج فيها إرادات هدفها تحقيق مصالحها، وقد صاغ الفقيه **FOUILLÉ Alfred** ذلك في عبارة وجيزة لها دلالة كبيرة "فمن قال عقد، قال

عدل"، فالعقد يعبر حقيقة عن وجود عدالة تعاقدية بين الطرفين متى تم إنشاءه بإرادة حرة، لأنّه ليس من المعقول قبول التزام لا تتحقق من خلاله مصلحة أحد أطراف العقد.

إلا أن الانطلاق من فكرة أن العقد يحقق بالضرورة العدالة التعاقدية ينجر عنه نتائج منها ما عبر عنها الفقيه "**IHERING**" أن " القول بأن اتفاق الإرادتين يكون بالضرورة عادلا، معناه إعطاء رخصة صيد للقراصنة ورجال العصابات مع منحهم الحق في أخذ كل ما تقع عليه أيديهم، ويضيف أنه :بين القوي و الضعيف، الحرية تستبعد، والقانون هو الذي يحرر، فما يصدق بالنسبة للمراكز المتساوية لا يصدق بالنسبة للمراكز غير المتساوية، فالعقد قد تعتريه عقبات أو حالات تمس بتوازنه الاقتصادي، التي قد تنشأ أثناء تكوين العقد أو أثناء تنفيذه، وفي مثل هذه الحالات يصعب التسليم بأن العقد يحقق العدالة بين الطرفين.

لقد أدى التطور بالمجتمع الإنساني إلى تشعب العلاقات والمعاملات بين الناس، الأمر الذي دعا إلى زيادة عدد العقود المبرمة فيما بينهم، وكلما ازدادت هذه العقود، اتجهت القناعة نحو التسليم بزيادة المصالح المتعارضة بين الأشخاص، فكل فرد يبحث عن تحقيق مصالحه، شريطة أن يحققها في الإطار المسموح به، فالقانون هو الذي يكفل عدم تصادم مصالح الأشخاص فيما بينها، ما دام أن من حق كل واحد منهم أن يحقق مصلحته في توفير سبل الحياة وديمومتها. وتتعدد أوجه تعارض المصالح، لدرجة أنها قد تصل إلى حد التعاكس أو التناقض، فمصلحة البائع تتناقض حتما مع مصلحة المشتري، عندما يقف كل واحد منهما عند رأيه سواء في البيع بالسعر الذي يريد، أو بالشراء بالسعر الذي يريد، فيأتي دور القانون ويصور هذا التناقض على أنه مجرد تعارض يمكن الجمع في النهاية بين مصلحتين لتحقيق على الأقل، الحد الأدنى لكل منهما. فينعقد العقد ويلتقي الطرفان في نقطة وسطى بينهما، فتتحول العلاقة بين الطرفين من علاقة بين شخصين لا يجمعهما رابط معين، إلى علاقة خاصة متجسدة في العقد.

وفي هذا العقد قد تتناقض المصالح، فيخل أحد الطرفين بالتزامه تحقيقا لمصلحة خارجة عن ما اتفق عليه، فلا بد أن يعطي القانون للمتعاقد آلية لحماية مصالحه ، وبالتالي يقيه انحراف الطرف الآخر عن سلوكه القائم على حسن النية، وهذه الآلية غالبا ما تتمثل في تحريك دعوى المسؤولية العقدية، أو المطالبة بالتنفيذ العيني جبرا على المدين أو المطالبة بالفسخ، عندما تصل العلاقة العقدية إلى حد يصعب معه استمرارها فيما بين المتعاقدين. وما هو متفق عليه أن للعقد قوة ملزمة، وعدم تنفيذه هو واقعة مخالفة للقانون، مما تمكن الدائن من أن يلجأ للقضاء ليطالب مدينه بتنفيذ ما تعهد به، وقد يكون إجبار المدين على التنفيذ المباشر للعقد غالبا أمرا صعبا، لأن عدم التنفيذ إما قد حدث عن قصد أو بسبب مانع قانوني كما في حالة الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل، حيث لا يمكن إجبار المدين على القيام بتنفيذ الالتزام، ولا يحصل الدائن إلا على التنفيذ بطريق التعويض.

يعتبر العقد أحد مصادر الالتزام أو أحد مصادر الحق الشخصي، ومن أكثرها إنشاء للالتزامات، فعندما ينعقد العقد صحيحًا فإنه يترتب العديد من الالتزامات في ذمة طرفيه أو أطرافه عند تعددهم، والذي يحدد هذه الالتزامات أطراف العقد بصورة لا تخالف القواعد القانونية الآمرة التي يجب احترامها ولا يجوز لأطراف العقد الاتفاق على ما يخالف حكمها، وعند وجود نقص في بنود العقد التي تحدد الالتزامات فإن القواعد القانونية المكملة تتدخل لسد هذا النقص ببيان الطرف الواجب عليه القيام بالالتزام، الذي لم يرد النص عليه في العقد.

إن الهدف الأساسي للمسؤولية المدنية كان وما زال هو جبر الضرر الذي يلحق بالمضرور من فعل الغير، هذه الوظيفة الدائمة تعد وظيفة أصلية لا يتخلى عنها لصالح أي هدف آخر. فيجب أن يتحمل المسؤول في ذمته كل نتائج هذا الانحراف، أي بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالمضرور عن طريق التعويض العادل، فالمسؤول إذا كانت لديه الحرية في الاختيار و قد اختار سبيل الإضرار بالغير فوجب أن يتحمل بكل نتائج مسلكه و هذا جزاء له على اعتدائه على القاعدة الأخلاقية.وإذا كان المضرور يستحق التعويض من الوجهة الاجتماعية، فإن مدى التعويض يجب أن يتقيد هو الآخر بالمنطق نفسه. فعدالة التعويض تعني استبعاد التعويض الكامل و الاكتفاء بالتعويض العادل الذي فيه ما يكفي لجبر الضرر.

غير أنه منذ ظهور الآلة ظهرت اتجاهات تدعو إلى الاكتفاء ببعض عناصر المسؤولية المدنية، على أساس أن ما يصيب الشخص أو مجموعة الأشخاص من ضرر لا بد أن يكون له تعويض يزيل آثاره، و أن الفكرة السائدة لدى الجمهور في الوقت الحاضر هو أن المسؤول الأخير عن ضمان التعويض هو المجتمع أو الهيئة الجماعية.

لقد جرت العادة على تقسيم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية و أخرى تقصيرية، فالمسؤولية العقدية تنشأ جزاء للإخلال بالتزام عقدي، وإذا تخلف أي طرف من أطراف العقد في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه تجاه الطرف الآخر، عندئذ تنهض في مواجهته المسؤولية العقدية، فالمسؤولية العقدية هي جزاء عدم تنفيذ العقد، ولقيام المسؤولية العقدية يفترض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ ولم يقم المدين بهذا التنفيذ ، إلى جانب عدم تنفيذ المدين لالتزامه قد يقوم بتنفيذه ولكن تنفيذه يكون معيبًا، أي ليس بالصورة المطلوبة المتفق عليها، وقد يتأخر المدين في عملية التنفيذ عن الوقت المطلوب منه تنفيذ التزامه فيه .فإذا توفرت أي حالة من الحالات الثلاث المذكورة عندئذ يكون من حق الدائن المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية.

فالمسؤولية العقدية لا تتحقق إلا بتوافر شروط أساسية، وهي وجود عقد صحيح بين المتعاقدين، وكذا أن ينصب الإخلال على التزام ناشئ عن هذا العقد .وأن يصيب الدائن ضرر بسبب الإخلال بالالتزام العقدي، سواء كان هذا الإخلال في صورة عدم التنفيذ أو التأخر فيه، وأن يكون هذا الضرر ناتج عن هذا الإخلال وهذا ما يسمى بالعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وبتحقق هذه الشروط تقوم المسؤولية العقدية، لترتب أهم اثر لها وهو جبر الضرر اللاحق بالدائن من جراء عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه، وذلك عن طريق التعويض.

ويجمع الفقه، على أن عدم تنفيذ العقد يمكن أن ينتج عنه ثلاثة نتائج، تتمثل فيما يلي؛ التنفيذ الجبري إذا كان ذلك ممكنا، أو فسخ العقد إذا كان هذا الأخير ملزما لجانين، وأخيرا إعطاء تعويض لفائدة الدائن فيما يعرف بالمسؤولية العقدية.

والتعويض كموضوع من مواضيع المسؤولية المدنية؛ وأهم أثر لها، يثير العديد من الإشكالات والجدال الفقهي التي تحتاج إلى دراسات تحليلية معمقة، وعلى الرغم من الكتابات العديدة في هذا الموضوع؛ إلا أننا نرى أن هذه الدراسات غير كافية؛ نظرا لاقتصارها على الدراسة في مجال المسؤولية التقصيرية دون العقدية، وإذا وجدت دراسة في مجال المسؤولية العقدية إلا أنها تكون مقتصرة على دراسة جزئيات معينة دون الإلمام بالموضوع. هذا وإذا كان سابقا ليس لدراسة التعويض في المسؤولية العقدية أهمية، نظرا لقلة إبرام العقود وبساطتها، إلا أنه بتطور العلاقات في المجتمع وظهور التكنولوجيا، أصبحت لهذا الموضوع أهمية بالغة نظرا لكثرة العقود التي يبرمها الأفراد، وتعدد أطرافها، وكذا طرق إبرامها.

على مستوى تنظيم المشرع المغربي للمسؤولية المدنية بوجه عام، فإننا نجده تناول كلا من المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية في موضعين مختلفين؛ ففي الوقت الذي تناول فيه هذه الأخيرة في الفصول من 77 إلى 106 من قانون الالتزامات و العقود (في الباب الثالث من القسم الأول الذي خصصه لمصادر الالتزام، حيث عنون هذا الباب تحت تسمية الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم، قبل أن يضيف إليه الباب الرابع الذي خصصه للمسؤولية الناجمة عن المنتوجات المعيبة[1])، نجده في المقابل نظم المسؤولية العقدية في العديد من المناسبات، فبالإضافة للمواد التي تشكل النظرية العامة للمسؤولية، كالفصول من 261 إلى 267 من قانون الالتزامات و العقود، فان المشرع المغربي تطرق لهذه المسؤولية أيضا بمناسبة تناوله للعديد من العقود في الكتاب الثاني من قانون الالتزامات و العقود.

[1] تم ذلك بمقتضى المادة 65 من **القانون رقم 24.09** المتعلق بسلامة المنتوجات و الخدمات و بتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.140 الصادر في 16 رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5980 الصادرة في 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)؛ ص 4678.

إن التمسك بالقوة الملزمة للعقد كمبدأ مطلق - حيث لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الإرادات التي أنشأته أو للأسباب التي يقررها القانون، كما يوجب على القاضي احترام العقد فلا يجوز تعديل ما اتفق عليه المتعاقدين بحر إرادتهما -دون الّنظر إلى الظروف الخاصة التي قد يتواجد فيها المتعاقدين يؤدي إلى نتائج ظالمة، هذا الوضع أدى في نهاية الأمر إلى ظهور فكرة التعديل، فقد منحت معظم الّتشريعات ومنها الّتشريع المغربي للقاضي رخصة الّتدخل من أجل معالجة مشكلة عدم التوازن الاقتصادي للعقد، بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ومن بين الحالات الشائعة التي يتدخل فيها القاضي في العقد حالة وجود ظروف طارئة تثقل كاهل المدين و حالة وجود شروط تعسفية في عقد الإذعان، هذه الحالات تعتبر حدود لمبدأ القوة الملزمة للعقد، حيث يخرج القاضي عن القاعدة التي تقضي بوجوب تنفيذ العقد دون تعديله إلا من طرف الإرادات التي أنشأته. إن تدخل القاضي في العقد يعتبر من أدق الموضوعات وأكثرها صعوبة كون العقد يعتبر أهم مظهر للّتصرفات التي تنشأ عنها الالتزامات، و قد أثار تدخل القاضي في العقد جدلا كبيرا في الفقه واستقطب اهتمامه، باعتباره مساس بمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يعتبر أهم المبادئ القانونية لأّنه يمّثل ذروة تقديس سلطان الإرادة المنشئة للالتزام.

كما تتسم سلطة القاضي في تعديل العقد بخطورة باعتبارها خروج عن مهامه الأصلية التي تقتصر على تطبيق القانون الخاص للطرفين الذي يتمثل في العقد، وتفسيره إذا كان محل لتأويله بالكشف عن نية الطرفين، فلا يجوز أن يغّلب إرادته لأن تفسير العقد ما هو إلا مظهر من مظاهر سلطان الإرادة حيث يتقيد القاضي في ذلك بما قصدت إليه إرادة الطرفين.

وتخضع العقود لقاعدة أساسية تتمثل في أن العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى أن ما اتفق عليه الأطراف في العقد هو الذي يجب أن يلتزموا به، ولا يجوز لأي طرف أن يخل به أو يطلب تعديله، وقد أقرت هذه القاعدة غالبية القوانين الوضعية مثل التقنين المدني الفرنسي، حيث تناول ذلك في المادة 1134 بقوله "أن الاتفاقات التي تمت على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقديها .فبين المتعاقدين يكون مضمون العقد واجب التنفيذ، فهما يحترمانه ويلتزمان به كما هو الشأن بالنسبة إلى أية قاعدة ينص عليها القانون" وهذه القاعدة ليست سوى نتيجة طبيعية لمبدأ سلطان الإرادة، فما دام المشرع يعترف للإرادة بسلطان في حدود النظام والآداب العامة، فإن ما تنعقد عليه إرادة الطرفين يكون بالنسبة إليهما بمثابة قانون واجب التطبيق.

وبالتالي فإن الأصل في العقود الصحيحة الإلزام أي التزام الأطراف بتنفيذ ما ورد بها من بنود، وعدم استطاعة أحد المتعاقدين الرجوع عنه بإرادته المنفردة، حيث يكون ملزما لطرفيه، ويجب عليهما الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، ليس هذا فقط بل أن أطراف العقد لا يستطيع أي منهم أن يقوم بصفة منفردة بتعديل العقد سواء بالزيادة أو النقصان إلا باتفاقهما على ذلك، أو استنادا إلى نص في القانون ملزم لهم، مما يعني أن الالتزامات التي ترد في العقد تتساوى مع ما يفرضه القانون من التزامات وهذه المساواة أقرها القانون ذاته حينما ألزم الأطراف بتنفيذ التزاماتهم العقدية.

وإذا كان الأصل في العقود هو التزام الأطراف بها فإن ذلك يتطلب أيضا أن يكون هناك توازن بين التزامات الأطراف من الناحية الاقتصادية في مرحلة تكوين العقد وتنفيذه، بحيث إن حدوث اختلال في مرحلة تكوين العقد يؤدي إلى لجوء الأطراف إلى إزالة هذا الاختلال والآثار الناجمة عنه والمتمثلة في الأضرار التي تلحق بأحد الأطراف ، وتتم تلك الإزالة بواسطة اللجوء إلى الأحكام الخاصة بهذه العقود. لكن إذا كان هذا الاختلال في التوازن الاقتصادي للعقد قد حدث بعد إبرام العقد وحال التنفيذ، بسبب ظروف غير متوقعة، فإن إزالة هذا الاختلال والآثار الناجمة يتم بواسطة اللجوء إلى الأحكام الخاصة بنظرية الظروف الطارئة.

وبالتالي فإن نظرية الظروف الطارئة أو الاستثنائية تفترض وجود عقد يتراخى وقت تنفيذه إلى أجل، وعندما يحل هذا الأجل تطرأ ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها من قبل الأطراف ويترتب عليها اختلال التوازن الاقتصادي للعقد بين طرفيه اختلالا خطيرا بحيث يصبح تنفيذ المدين للعقد يهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المعقول، وفي هذه الحالة فإن الطرف المضرور يقوم باللجوء إلى القضاء بهدف إعادة التوازن الاقتصادي للعقد بناء على نظرية الظروف الطارئة التي تعد خروجا عن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

وفي هذا الصدد، و اثر ما شهده العالم من حالة رعب و خوف بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، و امتداد أثره من العلاقات الإنسانية إلى العلاقات التعاقدية، و بما أن مبدأ سلطان الإرادة و ما يترتب عنه من نتائج و التي تعد القوة الملزمة للعقد أهمها، يعتبر المؤطر الأساسي و الرئيسي لهذه العلاقة، وبما أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة ولا تتأتى هذه الغاية إلا بمسايرة ومواكبة القواعد للضرورات الاجتماعية والاقتصادية التي تنصب عليها، فانه وتماشيا مع ما ذهب إليه العالم بهدف الحد من انتشار هذه الجائحة ومجابهتها لحماية أرواح الناس وسلامتهم، اتخذت الحكومة المغربية على غرار نظائرها في العالم، العديد من الإجراءات لمجابهة الوباء تمثلت في إغلاق الحدود البرية و الجوية و البحرية، وإلغاء جميع التجمعات و التظاهرات الرياضية و الثقافية و الفنية و تعليق الجلسات في المحاكم و منع التنقل إلا برخص استثنائية تصدرها السلطات المختصة، أدى

إلى خلق مجموعة من المعيقات أثناء تنفيذ العد أصبح من خلالها الالتزام صعب التنفيذ في الأجل المتفق عليه بين الأطراف.

ويعد مرسوم القانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، و الذي تضمن في مادته السادسة أن جميع الآجال تتوقف خلال فترة حالة الطوارئ، فضلا عن إعلان وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بالمغرب على تحمل الدولة و القطاع البنكي **" التكلفة الكاملة للفوائد العرضية وتأجيل سداد قروض السكن و الاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس و يونيو 2020 وذلك بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسب حالة الطوارئ الصحية المقررة"**، من المقتضيات القانونية التي اتخذتها السلطات المسؤولة والتي تعكس رؤية و إستراتيجية الدولة في الحفاظ على التوازنات العقدية بين كل من الدائن و المدين و التي تتجلى أساسا في استقرار الالتزامات و المعاملات المدنية، سواء من خلال منحها آجالا معقولة للأداء من جهة، أو من خلال توقيف سريان الآجال من جهة أخرى.

و عليه ستتم دراسة موضوع التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه من خلال هذا البحث اعتمادا على ما شهده العالم من جائحة كورونا عموما، و ما شهده المغرب خصوصا.

و تبرز أهمية هذه الدراسة في كون التعويض يعتبر أحد المواضيع المهمة في إطار المسؤولية العقدية بعد التنفيذ العيني للالتزام، الذي يحتل المرتبة الأولى في الأهمية باعتباره يمثل الغاية المرجوة من وراء العقد، ولكن في ظل غياب التنفيذ أو تأخره، تبرز أهمية التعويض كونه الوسيلة التي من خلالها يتم جبر الضرر الذي يصيب الدائن، تنصب الدراسة في هذا البحث على التعويض الذي يستحقه الدائن في حال تأخر المدين في تنفيذ التزامه، وتنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوعًا محل خلاف بين الفقهاء المسلمين المعاصرين، فهنالك من يرى جواز التعويض في حال تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، وله في ذلك مبررات وأسانيد، وفي المقابل هنالك من يرى عكس ذلك معتمدًا في وجهة نظره على ما لديه من حجج وأدلة، وكذلك الحال بالنسبة للقوانين المدنية العربية، التي اختلفت مواقفها من هذا النوع من التعويض، بالإضافة إلى ما توصل إليه القانون الفرنسي المقارن.

تثير دراسة التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه العديد من الإشكالات، منها ما يتعلق بالأحكام الخاصة به التي وردت في القوانين التي أخذت به، ومنها ما يتعلق بالمبررات الفقهية التي يستند إليها من يرى جواز الأخذ به، أو من يرفضه ويقول بحرمته. كما أنه و في إطار بحثنا هذا اعترتنا العديد من الصعوبات و المشاكل المتعلقة بقلة المراجع فيما يخص المواضيع المتعلقة جائحة كورونا، ذلك أن هذه الجائحة مستجدة و مفاجئة و لم تمر سنة على بدايتها وبالتالي يصعب الحصول على المراجع الجديدة في هذا الموضوع.

ولقد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي التحليلي، فمن خلال هذا المنهج سيتم الوقوف عند النصوص القانونية التي عالجت التعويض بصورة عامة والتعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه بصورة خاصة، من أجل التعرف على كل الجوانب القانونية الخاصة بكل قانون من القوانين محل الدراسة.

عند البحث في موضوع التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه في المراجع، يتبين بأنه قد تمت دراسته والتعرض له في إطار البحث في التعويض في المسؤولية العقدية باعتباره أحد حالات استحقاق التعويض، ويظهر في تلك المراجع أنها قد ركزت اهتمامها على الصورة الخاصة للتعويض عن التأخير والتي تتمثل في تأخر المدين في تنفيذ التزامه العقدي الذي يكون محله أداء مبلغ من النقود، والتي اصطلح على تسميتها بالفائدة القانونية.

فإلى أي حد عمل المشرع على ضمان حق الدائن في استحقاق التعويض، في حال تأخر المدين عن تنفيذ التزامه؟ هل يستطيع الدائن مطالبة مدينه بالتعويض في تأخره في تنفيذ التزامه، وهل يشمل ذلك جميع الالتزامات سواء كانت التزامًا بالقيام بعمل أو التزامًا بالامتناع عن القيام بعمل والالتزام بدفع مبلغ من النقود ؟ وهل يشترط لاستحقاق هذا النوع من التعويض وقوع ضرر في جانب المدين وإثباته ، أم يكفي مجرد التأخير في التنفيذ لاستحقاق التعويض؟ وهل يمكن للمدين أن ينفي وقوع ضرر في جانب الدائن ليتجنب الحكم بالتعويض أم أن هذا الافتراض لا يقبل إثبات العكس؟

و لا شك أن التدابير الاحترازية المفاجئة تفرض وبإلحاح شديد مجموعة من التساؤلات في الموضوع من قبيل، **ما مصير الالتزامات التعاقدية التي صادف تنفيذها مرور البلاد بجائحة زمنية مفاجئة؟ وهل تُعد جائحة فيروس كورونا قوة قاهرة أو ظرف طارئ تجيز لأطراف التعاقد فسخ العقود التي أُبرمت قبل وقوعها أو على الأقل المطالبة بإعادة التوازن وردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول؟ والى أي مدى يمكن امتصاص الصدمة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين طرفي العقد عند اللجوء إلى نظرية القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة، لمعالجة آثار جائحة فيروس كورونا؟**

للإجابة عن هذه التساؤلات، فان خطة بحثنا تتمحور حول فصلين أساسيين:

الفصل الأول : أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية

الفصل الثاني : تأثير جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية

الفصل الأول :

أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية

المبحث الأول : التعويض عن الضرر المترتب عن المماطلة في الديون

يتناول هذا المبحث بالدراسة التعويض من حيث المفهوم، وذلك من خلال البحث عن معناه اللغوي والاصطلاحي الوارد في كتب اللغة والفقه، من خلال التعرض للعديد من التعريفات التي حاول واضعوها تحديد مفهوم التعويض، وكذلك دراسة العلاقة القائمة بين مصطلحي التعويض والضمان فيما إذا كانا يؤديان نفس المعنى أم لا؟ ودراسة أنوع التعويض وطرق تقديره، وكذلك سيتم البحث في شروط استحقاق التعويض في إطار المسؤولية العقدية والمتمثلة بالخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية والإعذار، وما يتفرع عن دراسة هذه الشروط من مسائل قانونية، وحتى تكون دراسة التعويض شاملة ستكون أنواع التعويض الثلاث، القضائي والاتفاقي والقانوني وحالات استحقاقه محلا للدراسة والبحث، وتتوزع دراسة هذه المواضع على مطلبين، يتناول المطلب الأول، مفهوم التعويض وعناصره، أما المطلب الثاني، فيتناول شروط استحقاق التعويض في إطار المسؤولية العقدية وأنواعه.

المطلب الأول : مفهوم التعويض عن الضرر و عناصره

يرتبط المعنى الاصطلاحي للتعويض الوارد في كتب الفقه بمعناه اللغوي، ولتحديد وبيان هذه العلاقة لا بد من البحث في كلا المعنيين على حدا، ومن ثم الربط بينهما، ويتفرع التعويض من الناحية القانونية من حيث الطريقة التي يتم فيها تحديد مقداره إلى ثلاثة أنوع، هي التعويض القضائي، الذي يتولى القاضي أمر تقديره، والتعويض الاتفاقي الذي يحدد مقداره طرفا العقد ويكون للقاضي أحيانًا سلطة تعديله، والتعويض القانوني الذي ينفرد المشرع في تحديد مقداره دون أن يكون للمحكمة أو لأطراف العقد في الغالب دور فيه، وفي الفرعين التاليين سيتم دراسة هذه المواضيع.

الفرع الأول : تعريف التعويض و تمييزه عن النظم المشابهة

يقتضي الحديث عن التعويض عن الضرر، تحديد تعريفه (أولا) ثم تمييزه عن النظم المشابهة له (ثانيا).

أولا : تعريف التعويض

التعويض لغة هو العوض ، و العوض معناه البدل أي الخلف و يقال (عاضه) بكذا و عنه و منه- عوضا أعطاه إياه بدل ما ذهب منه ، فهو عائض .

و من ذلك أيضا أن العوض يعني البدل و تعوض منه و اعتاض أي أخذ العوض و عاضه أصاب منه العوض و عضت أصبت عوضا.

أما التعويض اصطلاحًا فيعرّف بأنه عبارة عن مبلغ من النقود أو أي ترضية من جنس أخر يساوي المنفعة التي كان يحصل عليها الدائن لو نفذ المدين التزامه على النحو الذي يقضي به مبدأ حسن النية في التعامل.

وتنبغي الإشارة إلى أن التعويض مر بمراحل عديدة حتى أصبح على الشكل المعروف به حاليا حيث اقر الرومان قبل وضع الألواح الاثني عشر حق المجتمع في مقاضاة الأشخاص الذين يحدثون بالغير أضرارا جسيمة متى كانت لهذه الأضرار انعكاس على صفو المجتمع و استقراره.[2]

و قد كان الشخص المضرور حرا في أن يثأر لنفسه أو ف أن يقبل أخد الدية التي كان يحدد مقدارها بالاتفاق بينه و ين الفاعل (الدية الاختيارية) و في حالات أخرى كان ملزما بقبول الدية التي تولى القانون تحديدها (الدية الإجبارية) فالمبلغ المتقاضى هنا ليس إلا بديلا عن القصاص و ليس تعويضا كما يصطلح عليه الآن.

وقد ورد التعويض على لسان الفقهاء بأنه : 'واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة' وهو عبارة عن رد مثل الشيء الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا.

وعرف الدكتور مصطفى الزرقاء الضمان بأنه : التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير.

و لقد شرع التعويض للجبر لا للعقوبة، و لذا لم يفرق الفقهاء في التعويض بين المميز و غيره، و الجاد و الهازل، والعامد و المخطئ، لأن الخطأ لا ينافي عصمة المحل، فكل فعل ضار يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير يعد مخالفا للقانون، و إذا كان الضرر ممنوعا في القانون فانه لا بد من رفعه، و من ثم يلزم الشخص إما بدفع قيمته لجبر الضرر و إزالته، أو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر.

وعند فقهاء الشريعة الإسلامية الأصل أن من ارتكب فعلا ضارا في حق غيره ألزم بالتعويض وذلك عن طريق الإلزام برد عين الشيء للشخص المضرور إذا كان الشيء المغصوب قائما لم يتلف بعد فإذا استحال هذا الأمر كأن يحصل نقص في هذه العين فهنا نكون أمام حالة ثانية و هي التعويض بالمثل و المثل في الشريعة هو ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به.

كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية لا يستعملون اصطلاح التعويض عند الحديث عن جبر الضرر، و إنما يستعملون مصطلح الضمان، فالضمان عندهم يحمل في طياته ما يقصد به

[2] مرزوق ايت الحاج، **محاضرات في المسؤولية المدنية**، مطبعة فولك، طنجة، 2018

من اصطلاح التعويض عند فقهاء القانون المدني. و الضمان هو واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة.[3]

والتعويض يستمد مشروعيته من كتاب الله و سنة نبيه، وفي ذلك وردت آيات في القران الكريم منها قوله تعالى **"وكتبنا عليكم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص"**[4]

ثم إن القوانين المدنية لم تتعرض لتعريف التعويض بوضع نصوص محددة تبين تعريفه، و إنما يتعرضون مباشرة لبيان طريته و تديره عند التطرق لجزاء المسؤولية.

والمشرع المغربي لم يعرف التعويض و إنما ترك أمر تعريفه للفقه و القضاء، حيث تطرق فقط لشروطه و أركانه في الفصول من 77 إلى 106 و 246 من قانون الالتزامات و العقود.

و من أهم التعاريف التي وزدت في الموضوع أن التعويض مبلغ من النقود يساوي المنفعة التي كان سيحصل عليها الدائن لو نفذ المدين التزامه على النحو الذي يقضي به مبدأ حسن النية و الثقة المتبادلة ين الناس.[5]

من خلال هذا التعريف نجد أنه ركز على جانب واحد من جوانب التعويض و ذلك على اعتبار أن التعويض هو مبلغ من النقود. غير أن هناك أوجه أخرى للتعويض، فقد يكون هذا الأخير عينا أو بمقابل غير نقدي، فهو ليس بالضرورة أن يتخذ صورة النقد، خاصة إذا ما تولدت للقاضي قناعة بأن التعويض العيني أو بمقابل غير ندي هو أجدى من الحكم بمبلغ من النقود لمحو الضرر.[6]

و هناك من عرف التعويض بأنه وسيلة القضاء لمحو الضرر أو تخفيف وطأته، إذا لم يكن محوه ممكنا، و الغالب أن يكون مبلغ من المال يحكم به للمضرور على من أحدث الضرر، و لكنه قد يكون شيئا آخر غير المال كالنشر في الصحف أو التنويه بحق المدعي في الحكم.[7]

هذا التعريف و إن لم يقع في خطأ حصر التعويض في كونه نقدي فقط، إلا أنه ركز على جهة تقديره على اعتبار أن القضاء وحده هو من يتولى تقدير التعويض، غير أن التعويض قد يقومه الطرفان بالاتفاق مسبقا على تقديره و هو ما يعرف بالتعويض الاتفاقي، و قد يكون محددا بنص القانون و هو ما يسمى بالتعويض القانوني.

---

[3] أبي حامد الغزالي، **الوجيز في فقه الإمام الشافعي**، الجزء الأول، دار المعرفة، بيروت، 1979.
[4] سورة المائدة، الآية 45.
[5] حسن علي الذنون، **النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام**،طبعة 1976.
[6] أشواق الدهيمي، **أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية**، الجزائر، 2013.
[7] منذر الفضل، **النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام**، الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان 1996، ص 426.

وهناك من يعرف التعويض بأنه جبر للضرر الذي لحق المصاب، ومن عرفه بأنه حق مدني يتعلق بالمتضرر بذمة المحكوم عليه، ولا يحكم به إلا بناء على طلب من صاحب الحق.

و هناك من يعرفه بأنه وسيلة لإصلاح الضرر، وعلى وجه التحديد يقصد به الإصلاح و ليس المحو التام و الفعلي للضرر الذي وقع.

نلاحظ من خلال التعاريف السابقة أنها لم تكن شاملة للتعويض من كل جوانبه، بحيث أن كل تعريف ركز على جانب دون الأخر، فإذا أردنا أن نعطي تعريفا واضحا للتعويض، فانه لا بد أن نجمع بين كل التعاريف السابقة و القول بأن التعويض هو **حق للدائن يثبت له بمجرد إخلال المدين بتنفيذ التزامه، وبالتالي فبصورة مقابلة، و باعتبار التعويض حقا للدائن فهم التزام من جهة المدين، وهذا التعويض قد يتخذ صورة النقد أو أي ترضية أخرى معادلة للمنفعة العامة التي كان سيحصل عليها الدائن.**

وبالتالي فان التعويض هو حق لدائن و التزام للمدين، يثبتان في ذمتهما عند الإخلال بالالتزام، و يكون إما نقديا أو في شكل أخر يساوي المنفعة التي كان سينالها الدائن لو لم يتم الإخلال بالالتزام.

ثانيا : تمييز التعويض عن الضرر عن النظم المشابهة

و في حديثنا هذا عن تعريف التعويض، فانه تنبغي الإشارة إلى أنه و كغيره من الأنظمة المستقلة، ينفرد بعض الخصائص المميزة له عن الأنظمة المشابهة، و من بين هذه الأنظمة نذكر : **الغرامة التهديدية، فائدة القرض، والعقوبة الجنائية.**

- **تمييز التعويض عن الغرامة التهديدية :** يحتاج تنفيذ بعض الالتزامات تدخل المدين شخصيا للقيام بذلك، بمعنى أن شخصية المدين تعتبر محل اعتبار، و مثال ذلك التزامه بالتمثيل في مسرحية معينة و الذي يتطلب قيامه بذلك شخصيا دون غيره، أو التزام شركة احتكارية للمياه و الكهرباء تقديم خدماتها لمن تعاقد معها من الجمهور، فلا يتصور التنفيذ العيني لهذا الالتزام إلا إذا قامت به الشركة ذاتها، كما أن إجبار المدين بطريق مباشر على التدخل شخصيا للقيام بتنفيذ التزامه قد لا يكون منتجا، وقد يقتضي المساس بحرية المدين الشخصية، وهذا لا يجوز لذلك ابتدع القضاء الفرنسي وسيلة لحمل المدين على التنفيذ العيني في مثل هذه الحالات و تسمى هذه الوسيلة بالتهديد المالي أو الغرامة التهديدية.

فالغرامة التهديدية عبارة عن مبلغ من النقود يحكم به على المدين عن كل وحدة زمنية أو عن كل مرة يخل فيها بالتنفيذ، فهي لا تخرج عن كونها وسيلة غير مباشرة لإجبار المدين على التنفيذ عينا.

فهي طريقة من طرق التنفيذ التي رسمها القانون و حصر نطاقها بالنسبة للالتزامات التي يستلزم الوفاء بها تدخل المدين شخصيا.

و الغرامة التهديدية لا تعد تعويضا للضرر لذا لا يشترط للحكم بها إثبات هذا الضرر، إلا أنه يجب على القاضي و هو يتصدى لتقدير التعويض بصورة نهائية أن يراعي إضافة ما أصاب الدائن من ضرر، مدى التعنت الذي بدا من المدين، بحيث يصبح التعنت هنا عاملا من عوامل التشديد في تقدير التعويض، دون أن يكون عنصرا من عناصره، أي أنه يلقى تقييما مستقلا إلى جانب العناصر التي يتضمنها التعويض وهما الكسب الفائت و الخسارة اللاحقة[8]

و تتلخص الغرامة التهديدية في أن القضاء يلزم المدين بتنفيذ التزامه عنا خلال مدة معينة، فإذا تأخر المدين في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخير، مبلغا معينا عن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو أية مدة من الزمن، أو عن كل مرة يأتي عملا يخل بالتزامهن وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو أن يمتنع نهائيا عن الإخلال بالالتزام ثم يرجع إلى القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامات التهديدية، ويجوز للقاضي أن يخفض هذه الغرامات أو أن يمحوها بتاتا. ويقصد من هذه الغرامة التغلب على ممانعة المدين المتخلف، فالغاية منها إرهاب المدين و حمله على التنفيذ العيني، و ليس الغرض منها تعويض الدائن عن تأخر المدين في الوفاء.[9]

و الغرامة التهديدية وفق التشريع المغربي، هي وسيلة قانونية منحها المشرع بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية للدائن لتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني، متى كان الأمر يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عنه لصيق بشخص المنفذ عليه، فقد جاء في الفصل المذكور ما يلي : **" إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، و أخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.**

يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته."[10]

---

[8] أشواق الدهيمي، **مرجع سابق**، ص 17

[9] حازم ظاهر عرسان صالح، **التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه –دراسة مقارنة-** 2011 الأردن، ص 113

[10] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدني.

و يختلف التعويض عن الغرامة التهديدية في الأمور التالية :

1. تنظم الغرامة التهديدية ضمن الأحكام الخاصة بالتنفيذ العيني، أما التعويض عن التأخير فمجال تنظيمه يتمحور في الأحكام الخاصة بالتعويض.
2. القاضي ملزم بتسبيب حكمه في التعويض، وغير ملزم بذلك في الغرامة التهديدية.
3. إن تحديد مقدار الغرامة التهديدية مرتبط ما يبديه المدين من تعنت في رفضه للتنفيذ العيني لالتزامه و بمركزه المالي، بينما يرتبط مقدار التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بوجه عام بالضرر اللاحق بالدائن.
4. يبدأ احتساب الغرامة التهديدية بعد صدور قرار المحكمة بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينا، أما التعويض عن التأخير، فيحسب من وقت صدور قرار المحكمة بإلزام المدين بالتعويض و تأخره عن ذلك.
5. تمثل الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على المدين لإلزامه بتنفيذ الالتزام المطلوب منه تنفيذا عينيا، أما التعويض عن التأخير فيحكم به في حال تأخر المدين في تنفيذ التزامه، أيا كان هذا الالتزام.
6. لا يجوز الحكم بالغرامة التهديدية إذا كان موضوع الالتزام أداء مبلغ من المال، لأن التنفيذ العيني بهذا المبلغ على المدين ممكن دون الحاجة إلى تدخله الشخصي، فلا مجال لاجتماع الغرامة التهديدية مع الفائدة القانونية (فائدة التأخير).
7. إن الحكم بالتعويض عن التأخير هو حكم قطعي لا يخضع لمراجعة من المحكمة التي أصدرته، ماعدا طرق الطعن المقررة قانونا، بينما يمكن للمحكمة التي أصدرت الحكم بالغرامة التهديدية مراجعته، وذلك بأن تلغيها أو تخفضها أو تحولها إلى تعويض، وبالتالي لا يعتبر الحكم فيها نهائيا، بل هو حكم قابل للتعديل و للمراجعة.

- **<u>تمييز التعويض عن فائدة القرض:</u>** فإلى جانب الفائدة القانونية (فائدة التأخير) التي يلتزم بها المدين إذا قصر في الوفاء بالتزامه بدفع مبلغ من النقود في الموعد المحدد له، يوجد نوع آخر من الفوائد يمكن أن تسمى **بالفوائد الاستثمارية**، يلزم بها المدين في عقد من عقود المعاوضة. و أكثر ما تصادف هذه الفوائد في عقد القرض حيث يتفق الدائن مع المدين على دفع فائدة معينة مقابل الانتفاع بالمبلغ المقترض. و هذا

النوع من الفوائد يطلق عليها جانب من الفقه مصطلح الفوائد التعويضية. إلا أن الفقه الغالب يطلق عليه مصطلح الفوائد الاستهلاكية.[11]

فعقد القرض من أكثر العقود شيوعا الذي يتضمن فائدة يلتزم المدين بردها مع أصل الدين، و يشار لعقد القرض في التشريع المغربي ب **"عارية الاستهلاك"** و قد عرفه قانون الالتزامات و العقود في الفصل 856 بقوله : **"عارية الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للأخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير عند انقضاء الأجل المتفق عليه، أشياء أخرى مثلها في المقدار و النوع و الصفة."**[12]

و نظرا لاختلاف الإطار القانوني المنظم لكلا نوعي الفائدة و الغاية منهما، فانه تبرز أهم أوجه الاختلاف بينهما فيما يلي :

1. إن التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بوجه عام والفائدة القانونية هو أثر لإخلال المدين في تنفيذ التزامه، بمعنى أن التعويض عن التأخير يستحق في حال تأخر المدين في تنفيذ التزامه، والذي يحكمه القواعد العامة للمسؤولية العقدية والاستثناء عليها الخاص بالفائدة القانونية، أما بالنسبة لفائدة القرض فهي احد الالتزامات المترتبة بموجب عقد القرض، بمعنى أنها أثر من آثار عقد القرض.
2. تختلف فائدة القرض عن الفائدة القانونية (فائدة التأخير) ، في أن الأولى دائمًا اتفاقية، أما الثانية فقد تكون قانونية وقد تكون اتفاقية، إذا تم النص عليها في العقد، وفي حال سكوت طرفي العقد عن تنظيمها يتولى المشرع تحديدها، وبالتالي تكون الفائدة القانونية (فائدة التأخير) فائدة قانونية واتفاقية.
3. يمكن للدائن(المقرض) مطالبة المدين (المقترض) بفائدة القرض عند حلول أجل الدين، أو عند حلول أجلها – أي الفائدة-، أما بالنسبة للفائدة القانونية(فائدة التأخير) فيتم المطالبة بها بعد أن يتأخر المدين في الوفاء بدينه.
4. يبدأ احتساب الفائدة القانونية (فائدة التأخير) بمواعيد متخلفة حسبما تم النص عليها في القوانين التي نظمتها، فهنالك ديون يبدأ احتساب الفائدة القانونية فيها من تاريخ استحقاق الدين، وهنالك ديون أخرى من تاريخ

---

[11] مع أن الدكتور **السنهوري** يميز الفائدة القانونية (**فائدة التأخير**) عن فائدة القرض بقوله : "تختلف الفوائد التعويضية عن الفوائد التأخيرية، كما قدمنا، في أن الأولى يلتزم بها المدين في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود و يكون في ذمته للدائن، أما الفوائد التأخيرية فهي ليست إلا تعويضا عن التأخير في الوفاء بدين هو مبلغ من النقود كما مر القول" ، فبما أن الغاية من الفوائد القانونية (**فوائد التأخير**) حسب قوله هي تعويض الدائن عما لحق به من ضرر بسبب تأخر المدين في الوفاء بدينه، و بالتالي يكون مسمى **الفوائد التعويضية** أقرب إلى الفائدة القانونية (**فائدة التأخير**) كونه يتناسب مع وظيفتها المتمثلة في التعويض، من فائدة القرض التي ليس لها صلة بموضوع التعويض.

[12] الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود.

الإنذار (الإخطار) أو المطالبة القضائية، ويستمر احتسابها حتى سداد قيمة الدين، أما بالنسبة لفائدة القرض فيبدأ احتسابها من اليوم الذي يستلم فيه المقترض مبلغ القرض، وليس قبل ذلك، حتى لو انقضت مدة بين تمام عقد القرض وتسلم المبلغ المقترض، لم يجب على المقترض أن يدفع الفوائد عن هذه المدة.[13]

5. وجدت الفائدة القانونية (فائدة التأخير) من أجل تعويض الدائن عما لحق به من ضرر نتيجة لتأخر المدين في الوفاء بدينه عن الموعد المتفق عليه، مع أنها غير مرتبطة بالضرر وجودًا وعدمًا ومقدارًا، كون الضرر فيها مفترض وغير قابل لإثبات العكس، ومع ذلك فيها تقابل ذلك الضرر المفترض في جانب الدائن، بينما فائدة القرض لا صلة لها بفكرة التعويض .فهي تمثل في الواقع مقابلا يرتضي المدين مقدمًا أن يدفعه للدائن نظير انتفاعه خلال أجل معين بمبلغ من النقود، لذلك فإن تسميتها بالفوائد التعويضية لا ينسجم مع وظيفتها والغاية منها.

- **<u>تمييز التعويض عن العقوبة الجنائية</u> :** إذا كان التمييز بين التعويض والعقوبة لا يحتل أهمية تذكر في ظل التشريعات التي كانت تحكم المجتمعات البدائية فهو ذو صبغة جنائية، فالأمر ليس كذلك في الوقت الحاضر،فأصبح للتعويض مفهوم وغاية تختلفان عن غاية ومفهوم العقوبة؛ خاصة بعد أن انفصلت المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية، وكان لذلك أثر في ظهور التمييز بين العقوبة والتعويض، "فالعقوبة هي جزاء يفرض لمصلحة الهيئة الاجتماعية ضد كل من ارتكب جريمة، وثبتت بحقه كرد فعل اجتماعي يقابل ما أصاب تلك الهيئة من مساس بكيانها ويتناسب مع خطأ الفاعل، فهي لا تتقرر لمصلحة المجني عليه شخصيا، وإنما لمصلحة المجتمع حماية لأمنه وكيانه، وتفرض من قبل سلطة قضائية مختصة بعد إجراءات تحقيقية أدت إلى ثبوت الجريمة بحق مرتكبها"[14] وبالرغم من التغيير الذي طرأ على مفهوم العقوبة خاصة في ظل التشريعات الحديثة، فأصبحت أداة ردع وإصلاح في الوقت نفسه، فلا يعني ذلك أنها أصبحت تقترب من التعويض فبينهما فروق عديدة سنشير إلى بعض منها:

<u>1.</u> أن العقوبة تفرض دون حاجة لوقوع الضرر نفسه كما في حالة الشروع في الجريمة جنائية أم جنحة، بينما التعويض لا يقضى به إلا إذا وقع ضرر فهو

[13] د .السنهوري، عبد الرزاق أحمد :**الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (5) العقود التي تقع على الملكية (الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح)** ص 465

[14] جلال مصطفى السعيد، **الأحكام العامة لقانون العقوبات الجديد**، ط 4، دار المعارف مصر، 1962، ص 547

محدد دائما بالقدر اللازم لتغطية الضرر وإعادة الوضع إلى الحالة نفسها التي كان عليها قبل وقوعه، فالتعويض بالمعنى المتقدم لا يصح اعتباره عقوبة.

2. أن العقوبة هي شيء ذاتي يتأثر بمجموعة من الاعتبارات منها الجاني والمجني عليه، مكان ارتكاب الجريمة، زمانها، وكذا درجة الخطأ، بينما لا يكون لأي تلك الاعتبارات تأثير على التعويض، على اعتبار أنه شيء موضوعي لا يراعى فيه إلا الضرر ومقداره، فهو يدور معه وجودا وعدما. وانطلاقا من مبدأ شخصية العقوبة فإن هذه الأخيرة تسقط بوفاة المحكوم عليه، بينما هذه المسألة لا تأثر على التعويض فيجوز التنفيذ على تركته، إضافة إلى ذلك؛ "إذا كان سبب الضرر متجددا أو مستم ا ر فللمتضرر أن يطلب من القضاء الحكم بإيقاف الفعل أو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الضرر الناشئ عنه؛ لأن التعويض يهدف إلى الإصلاح، ويكون عن طريق محو سبب الضرر متى كان ممكنا"

3. إن فرض العقوبة مقيد بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فالمشرع الجنائي يحدد الأفعال التي تعد جرائم، ويحدد العقوبات لكل منها، أما التعويض فلا يوجد تحديد لمقداره، فمقداره يتحدد تبعا لمقدار الضرر المراد جبره، ولا يوجد أيضا تحديد للأفعال الضارة؛ لعدم إمكانية حصرها ويقتصر دور المشرع على إيراد نص عام يحدد فيه مسؤولية الشخص عن فعل يلحق ضررا بالغير، كما ورد في الفصل 77 من قانون الالتزامات و العقود المغربي : **"كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة و اختيار، و من غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا أثبت أن هذا الضرر هو السبب المباشر في حصول الضرر."**

من خلال مقارنة و تمييز التعويض عن بعض الأنظمة المشابهة يتبين أن التعويض يختلف عنها من حيث أهدافه و غاياته و مشروعيته، و بالتالي نقول أن التعويض نظام قانوني قائم بذاته، فإذا كان التعويض جزاءا مدنيا محضا لا يهدف إلى معاقبة المدين؛ بل إصلاح الضرر، ومناط الحكم به هو مقدار الضرر الحاصل ولا علاقة له بجسامة الخطأ. فأن الأمر يستلزم تمييزه عن الغرامة التي تفرض على المدين لغرض إكراهه وجبره على تنفيذ التزامه وهي الغرامة التهديدية أو الإكراه المالي، وكذلك عن فائدة القرض و العقوبة الجنائية.

الفرع الثاني : عناصر التعويض عن الضرر

إن التعويض لا ضرورة للحكم به إذا لم يكن يحقق الغاية المبتغاة من فرضه، وهي جبر الضرر ومحوه قدر الإمكان، ومن الطبيعي أن تلك الغاية لا تتحقق إلا إذا كان التعويض شاملا لكل ما أصاب الدائن من خسارة أو ما فاته من كسب. وبالتالي فإن التعويض عن الضرر يتحلل إلى عنصرين هما الخسارة اللاحقة والكسب الفائت. وقد عرف المشرع المغربي الضرر بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود على أنه : "هو ما حق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام."

أولا : ما لحق الدائن من خسارة

يدخل في مفهوم الخسارة :تفويت صفقة تجارية توقع الدائن أنها رابحة، وكان توقعه مبنيا على أسباب معقولة، فلو تعهد ناقل بأن ينقل شخص إلى مكان ما للاشتراك في مزايدة لإبرام صفقة تجارية، ونتيجة لعدم تنفيذ الناقل لتعهده أو التأخر في تنفيذه، ترتب حرمان الراكب من الاشتراك في المزايدة فيكون بذلك قد تضرر بسبب ما لحقه من خسارة نتيجة مصاريف النقل؛ وكذا ما أنفقه على إجراءات الاشتراك في المزايدة ، وما كان يتوقعه من ربح إذا رست هذه المزايدة عليه.

وقد تضمنت أغلب التشريعات النص على العنصرين الذين يجب مراعاتهما في تقدير التعويض، فعلى سبيل المثال نصت المادة 1149 من القانون المدني الفرنسي على أنه **"يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب"**[15]

وقد أكدت عليه الكثير من القرارات الصادرة عن المحاكم، نذكر منها قرار محكمة التمييز المصرية الذي جاء فيه **"إن التعويض يستحق عن كل التزام ينشأ عن العقد ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب التأخير في استفاء المنفعة"**[16]

و لتحديد الخسارة التي لحقت الدائن والتي يلتزم المدين بتعويضها لا بد من التمييز بين حالتين:

---

[15] **Code civil français,** dernière modification: 2020-09-01, Edition 2020-09-26, Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 -art. 2

[16] سعيد أحمد شعلة، **قضاء النقض المدني في المسؤولية و التعويض، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض خلال اثنين و سبعين سنة من 1931 إلى 2002** ، طبعة 2003، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية ، ص 296.

<u>في مجال المسؤولية العقدية</u> يلزم المدين بتعويض الدائن عن ما لحقه من خسارة وما أصابه من ضرر متوقع، بشرط أن يكون هذا الضرر نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالتزامه أو التأخر فيه ويكون الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن باستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

أما **<u>في مجال المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية الناتجة عن غش المدين أو خطئه الجسيم</u>**، يلزم هنا المدين بتعويض الدائن عن ما لحقه من خسارة وما أصابه من ضرر؛ متوقع أو غير متوقع بشرط أن يكون هذا الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو التأخر فيه.

<u>ثانيا : ما فات الدائن من كسب</u>

يدخل في مفهوم الكسب الفائت مجرد التأخر في استيفاء المنفعة، فمثلا لو عهد شخص يملك أرضا إلى مقاول لبناء فندق سياحي عليها لغرض استثماره، إلا أن المقاول لم يقم بتنفيذ العمل أو التأخر في تسليم البناء عن الموعد المتفق عليه، فادى ذلك إلى تضرر صاحب الأرض (رب العمل)، وضرره يتمثل في ما فات عليه من ربح كان من الممكن أن يحصل عليه لو أتم المقاول العمل في موعده من خلال استثماره الفندق واستقبال النزلاء. وبالتالي على القاضي أثناء تحديده لقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق الدائن مراعاة ما فات الدائن من كسب مالي نتيجة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه.

إلا أنه في القانون الأنكلوساكسوني في حالات بيع السلع فان عناصر التعويض هي ما أصاب الدائن من خسارة في جميع الأحوال، أما ما فات من كسب فلا تعويض عنه إلا إذا كان المدين على علم بالظروف التي ستؤدي إلى فوات الكسب على الدائن، فلا توجد تفرقة بين الخسارة والكسب الفائت فكل منهما خسارة أما ما فات من كسب فيعتبر بعيد الصلة بالإخلال الواقع، وذلك يعود لأسباب اقتصادية تهدف إلى تحديد مخاطر النشاط التجاري .أما في غير حالات بيع السلع فانه يجوز للقاضي أن يعتبر ما فات من كسب احد عناصر التعويض ومتى ما توافرت ظروف خاصة أحاط بها المدين وكان الإخلال بمثل تلك الظروف يؤدي إلى تفاقم الضرر.

- ✓ **وفي رأينا تحليل تقدير التعويض إلى هذين العنصرين ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، يهدف إلى جعل التعويض كاملا وعادلا وشاملا وبالتالي يغطي الضرر، بحيث لا يكون مصدرا لإثراء الدائن - المضرور - على حساب المدين، فلو تضمن الحكم بالتعويض إعطاء الدائن أكثر من الضرر الذي لحق به، فان ذلك يعد كسبا دون سبب وهو أمر لا يجيزه القانون.**

المطلب الثاني : أنواع التعويض و شروط استحقاقه

بعد التعرف على التعويض من حيث اللغة والقانون و الشرع وكذا العناصر اللازم مراعاتها عند تقديره، نجد أنفسنا أمام الإشكال القائل : ما هي أنواع التعويض وما هي شروط استحقاقه؟. ذلك أنه لا يحكم بالتعويض لمجرد حدوث الضرر فلا بد من توافر جملة من الشروط الأخرى الشكلية والموضوعية، كما أن للتعويض أنواع لا بد من مراعاتها عند إصدار الحكم، ذلك من أجل جبر الضرر قدر الإمكان من خلال اختيار التعويض الأنسب للمتضرر في المسؤولية العقدية. هذا الإشكال هو ما حاولنا الإجابة عليه في هذا المطلب من خلال الإشارة إلى أنواع التعويض **(الفرع الأول)** ثم التطرق إلى شروط استحقاقه **(الفرع الثاني).**

الفرع الأول : أنواع التعويض

إذا ما ثبتت المسؤولية العقدية في حق مرتكب الخطأ يبقى الحكم بالتعويض الذي يأخذ إحدى الصورتين:

- الحكم برد الحال إلا ما كانت عليه، أي أن يتم تقرير الإجراءات التي من شأنها رد المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يقترف الخطأ أو الإخلال بالتنفيذ، وبالتالي يتم رد العين المغصوبة إلى صاحبها، أو إبدال العين التالفة أو المعيبة بأخرى سالمة وصحيحة، وهكذا لا يبقى من الإخلال بالتنفيذ أو ارتكاب الخطأ سوى الذكرى، أما آثار هذا الإخلال فقد انمحت واندثرت بالتعويض، وهذا ما يسمى بالتعويض العيني أو كما يسميه بعض الفقهاء بالتنفيذ العيني. **(التعويض العيني)**
- أن يتم الحكم بجبر الضرر وبتعويض المضرور عنه بمقابل نقدي غالبا وغير نقدي أحيانا، بمعنى يتم توفير منفعة للمضرور تساوي مقدار ما لحق به من ضرر، فتتناقص هذه المنفعة مع الضرر وبذلك تعود حالة المضرور حكما لا حقيقة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، وهذا هو التعويض بمقابل أو التنفيذ بمقابل. **(التعويض النقدي)**

أولا : التعويض العيني

يعرف التعويض العيني بأنه" :الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل أن يرتكب المسؤول الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر."[17]

والتعويض العيني بهذا المعنى يعد أفضل من التعويض النقدي ذلك أنه يؤدي إلى محو الضرر وإزالته بدلا من بقاء الضرر على حاله وإعطاء المتضرر مبلغا من المال عوضا عنه كما هو الحال في التعويض النقدي،" فلا يبقى من الإخلال أو العمل غير المشروع سوى الذكرى " [18]

و" بعبارة أخرى يحقق المتضرر ترضية أخرى من جنس ما أصابه من ضرر، وذلك بطريقة مباشرة، أي غير الحكم له مبلغ من نقود"

"فالتعويض العيني هو طريقة ناجعة بالنسبة للمضرور، إذ يهدف إلى محو ما لحقه من ضرر، طالما كان ذلك ممكنا، أي إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وهو الأصل في الشريعة الإسلامية التي تقضي انه إذا كان الشيء الذي اتلف أو اعدم، مثليا وجب تعويضه بمثله، وان كان قيميا فبثمنه" [19]

هذا وقد خاض الفقه جدالا حادا حول مفهوم التعويض العيني من الناحية القانونية وانقسموا في هذا المجال إلى مؤيد لفكرة التعويض العيني و رافض لها :

- **الاتجاه الرافض للتعويض العيني :** كما سبق بيانه فإن التعويض العيني هو محو الضرر، بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الإخلال بالالتزام، إلا أن هذا التعريف قوبل بانتقادات كثيرة إلى حد رفض وجوده، فانقسم أصحاب هذا الاتجاه إلى فريقين، الأول رافض للمصطلح، والثاني رفض للمضمون.
  - **الاتجاه الرافض للمصطلح :** إذا كان التعويض كجزاء للمسؤولية المدنية بوجهيها العقدية و التقصيرية، يمثل منفعة بإزالة الضرر إلا أن بعض الآراء اعترضت على أن إزالة الضرر تعويض عيني. إذ لا يرى الأستاذ **سافاتيه** أن : **" إزالة المخالفة تعويض عيني، وإنما هو إصلاح للشيء التالف لأن القاضي لا يعوض وإنما يهتم بإزالة المخالفة".**[20] ويرى **فقيه أخر** أنه : **"إذا كان الغرض من الحكم هو إنهاء حالة التصرف غير المشروع فلسنا بصدد مسؤولية، بمعنى آخر إن ذلك ليس تعويضا عينيا"**

---

[17] موريس نخله، **الكامل في شرح القانون المدني**، -دراسة مقارنة- الجزء الثالث، منشورات الحلبي القانونية، لبنان 2007 ، ص 336

[18] عبد الرزاق السنهوري، **الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، مصادر الالتزام**، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، 1952، ص 966.

[19] وهبة الزحيلي، **نظرية الضمان في الفقه الإسلامي**، دار الفكر دمشق، 1970، ص 150.

[20] Savatier: **Traite de la responsabilité civile en droit Français**, tome 2, deuxième Edition, Paris, 1951, P 593.

وثمة رأي آخر يرفض التعويض العيني، ويتبلور هذا الرأي من خلال طرح **ربيرت وبولانجييه** إذ يذهب هذان الكاتبان إلى أن " التعويض هو الحكم بمبلغ من النقود أما سوى هذا الطراز من التعويض يمثل الحكم باحترام الحق"[21] ففي نظرهما معالجة الضرر تعتبر تعويض، أما احترام الحق فهو إجراء لحماية هذا الحق، وبالتالي لا يكون طلب المدعي للحكم له بالتدابير لحماية حقه الشخصي المنتهك تعويضا عينيا.

بناءا على ما تقدم فإن الأصل في هذا الاتجاه، هو أن المضمون واحد بوجود إجراء آخر لإزالة الضرر إلى جانب الحكم بمبلغ من النقود، لكن الاختلاف هو المصطلح في عدم تسمية هذا الإجراء تعويضا عينيا، ونحن لا نتفق مع أصحاب هذا الرأي بالقول بأن جزاء حماية الحق الشخصي المنتهك غريب عن المسؤولية، ولا يمكن القول أن حمايته تتحقق من خلال إجراءات أخرى، وليس من خلال المسؤولية.

- **الاتجاه الرافض للمضمون :** إن أهم من رفض التعويض العيني من حيث مضمونه وأنكر وجوده هي لوسيان ربير وأهم ما دعمت به فكرتها؛ هو أنه إذا دققنا النظر في تعريف التعويض العيني يفيد أن محوره التعويض، لذا في رأيها " من الخطأ الاعتقاد بوجود التعويض العيني المتمثل في محو الضرر عندما تتم إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وان الوسيلة الوحيدة لتعويض المتضرر هي الحكم له بمبلغ نقدي، وكل ما يمكن الحكم به فضلا عن التعويض النقدي هي الحيلولة دون وقوع الضرر وليس محوه، كما أن الإجراءات اللازمة للحيلولة من دون وقوع الضرر؛ لا يمكن اعتبارها تعويضا عينيا، لأن التعويض يفترض وقوع الضرر، في حين أن الضرر هذا غير محقق وإنما محتمل، أما إذا وقع الضرر فإنه لا يمكن محوه أبدا، وفي هذه الحالة فإننا لا نستطيع سوى منع استمرار الضرر في المستقبل، ومن هنا يجب التمييز بين ما يتضمنه الحكم بالتعويض النقدي من الضرر الماضي وبين التدابير المخصصة لتجنب الضرر في المستقبل" [22]

في حين ذهب رأي ثان، إلى استحالة التعويض العيني، لأنه لا يمكن محو الضرر المفاجئ، كما أن أخذ كلمة **"محو"** حرفيا من تعريف التعويض العيني فهذا يعني أن التعويض النقدي لا يمحو الضرر، لذلك لا يمكن إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوث الضرر، وعليه يحكم بالتعويض النقدي عن الضرر المحقق.

---

[21] Ripert (G.) et Boulanger: **Traite élémentaire de droit civil de Planiol**, tome 2, 4 Edition, 1952, P 1146.

[22] Lucienne Ripert: **La réparation du préjudice dans la responsabilité délictuelle**, thèse, Paris, 1933, P.38 ,39.

وهناك رأي آخر يذهب إلى" تسمية التعويض العيني بالتنفيذ العيني الجبري، تمييزا له عن امتناع المدين عن القيام بالعمل الذي التزم بالامتناع عن القيام به، والذي هو التنفيذ العيني الاختياري، إذ يرى أصحاب هذا الرأي أن التعويض إنما يلجأ إليه عند عدم إمكان إجبار المدين على التنفيذ العيني، ويكون التعويض دائما بمبلغ من النقود"[23]

غير أن الكثير من الفقهاء الذين كانوا يدافعون على هذا الطرح تراجعوا عنه في آخر المطاف، ومنهم الأستاذ السنهوري؛ الذي يرى أن هناك ترادفا بين لفظي التعويض العيني و التنفيذي العيني، وهو الوفاء بالالتزام عينا، ويقع هذا كثيرا في الالتزامات العقدية، إلا أنه تراجع عن هذا الرأي قائلا بعدم وجود مثل هذا الترادف حيث يقول :"والفرق بين التنفيذ العيني والتعويض العيني، أن الأول يكون قبل وقوع الإخلال بالالتزام فيكون هناك تنفيذ عيني للالتزام عن طريق عدم الإخلال به، والثاني يكون بعد وقوع الإخلال بالالتزام فإزالة المخالفة تكون هي التعويض العيني"[24]

- **الاتجاه المؤيد للتعويض العيني :** لقد تبنى المشرع الفرنسي فكرة التعويض العيني، كلما كان هذا التعويض أقرب إلى العدالة من التعويض النقدي، وهذا ما أكده القضاء الفرنسي في نطاق المسؤولية العقدية للحكم بالتعويض العيني في كل مرة يكون هذا التعويض متفقا ومقتضيات العدالة، إذ تبنت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه بقرارها الآتي : "يجب أن ينقض القرار الذي حكم على إحدى شركات النقل للقطار - دون أن تأخذ محكمة الموضوع بعين الاعتبار ما عرضته الشركة من نوع التعويض -بأن تعمل بنفسها على تعويض الأضرار بإصلاح الأثاث المتضررة من خلال عملية النقل" ويرى بعض أنصار هذا الاتجاه أيضا، بأنه للقاضي سلطة تقديرية في اختيار طريقة التعويض، فله أن يحكم بالتعويض العيني عن الضرر المادي، بأن يرتب على المدين الالتزام بالقيام بعمل وهو الإصلاح أو إزالة الضرر، إلا أن هذا الالتزام عند عدم تنفيذه يؤدي أيضا إلى اللجوء إلى التعويض عن عدم التنفيذ. كما أن للقاضي أن يحكم بالتعويض العيني، وأن يؤدي المدين نفقات هذا التعويض ويستبعد الحكم بالتعويض العيني، إذا كان المتضرر قد أصيب بأضرار جسيمة أو كانت الأضرار معنوية[25].

---

[23] منذر الفضل، **النظرية العامة لالتزامات الجزء الثاني، أحكام الالتزام**، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، طبعة 1998، ص 25.

[24] عبد الرزاق السنهوري، **مرجع سابق**، ص 455

[25] Article **1382**, Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4 : « **Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.** »

ثانيا : التعويض بمقابل

إن التعويض العيني كما سبقت الإشارة يتم اللجوء إليه من طرف القاضي متى ما كان ممكنا كما يعتبر التنفيذ العيني هو الطريق الأصلح من طرق التعويض لجبر الضرر الذي أصاب الدائن، إلا أنه في حالات عديدة ترتبط أشد الارتباط بنوع الضرر، فقد يرى القاضي أن التعويض العيني غير ممكن أو غير ملائم لجبر الضرر، خاصة بالنسبة للضرر المعنوي، فعندئذ لا يبقى أمامه سوى اللجوء للتعويض بمقابل سواء كان تعويضا نقديا أو غير نقدي.

1. التعويض النقدي :

يكون التعويض نقديا متى تضمن الحكم الصادر به إلزام مدين بدفع مبلغ من النقود للدائن، كمقابل للضرر الذي أصابه نتيجة لإخلال المدين بتنفيذ التزامه العقدي.
وفي الوقت الراهن يعتبر التعويض النقدي أهم أنواع التعويض وهو الطريق الطبيعي لمحو الضرر وإصلاحه، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن النقود تمثل إضافة إلى أنها وسيلة للتبادل وسيلة للتقويم، لذا وفي كل حالة يتعذر فيها الحكم بالتعويض عينا ولم يكن هناك سبيل للحكم بالتعويض غير نقدي، تعين على المحكمة أن تحكم بالتعويض نقدا. والحكم بالتعويض النقدي يعني إدخال قيمة مالية جديدة موازية للقيمة المالية التي فقدها المتضرر من ذمته نتيجة لإخلال مدنية بتنفيذ التزامه. وقد نصت العديد من التشريعات على التعويض النقدي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القانون المدني العراقي في المادة 255 منه قد نصت على أنه : "ينفذ الالتزام بطريقة التعويض في الأحوال وطبقا للأحكام التي نص عليها القانون"[26] و منه يتضح أن المشرع العراقي لم يقيد قاضي الموضوع بإتباع طريقة معينة لتقدير التعويض، وإنما ترك المجال مفتوحا أمامه لاختيار الطريقة الملائمة لجبر الضرر.

2. التعويض غير النقدي :

قد يكون التعويض الذي يحكم به القاضي جبرا للضرر تعويضا غير نقديا، فهو ليس بالتعويض النقدي، لأنه لا يتضمن إل ا زم المدين المخل بتنفيذ التزامه أداء مبلغ من النقود للدائن، كما أنه ليس بالتعويض العيني على اعتبار لا يتضمن أيضا إلزام المدين بأن يؤدي للدائن ذات ما التزم بأدائه. فالتعويض غير النقدي يمكن أن يعتبر تعويضا من نوع خاص تقتضيه الظروف في بعض الصور وحسب نوع الضرر المحدث، فيغلب الحكم به في الضرر المعنوي دون الضرر المالي، ويتخذ شكل

[26] سليمان مقرس، **الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الفعل الضار والمسؤولية العقدية**، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، 1957، ص 528.

الحكم بمصرفات الدعوى أو نشر الحكم الصادر في الجرائد إظهار حق المدعي تجاه المدعى عليه، واللجوء إلى هذا الطريق من طرق التعويض يعد من الأمور التي تدخل في سلطة القاضي عند نظر الدعوى فكما، أ رينا أن نص المادة 225 من القانون المدني العراقي لم تشترط في التعويض أن يكون نقديا .وقد يتخذ هذا النوع من طرق التعويض صور الحكم بمصروفات الدعوى، فقد يطالب من أصابه ضرر معنوي مثلا بإلزام المدعي عليه بمصروفات الدعوى، وذلك يشكل ترضية كافية له، وفيه ما يكفي لجبر الضرر، أو يتخذ الحكم بمبلغ رمزي ليس فيه معنى مقابل الضرر وإنما إقرار من القضاء بحقه، فمنح المضرور المبلغ الرمزي لا يعني أن التعويض قد أصبح نقديا، بل يعني استنكار القضاء لما صدر من المدين من إخلال بتنفيذ التزامه، وإقرار في الوقت نفسه بحق المتضرر الذي يستطيع بواسطته تلافي ما قد يتعرض له من أذى في سمعته، خاصة إذا كان المتضرر ذا سمعة تجارية ولا يسعى إلى الربح عند المطالبة بالتعويض.

أما الصورة الأخرى التي قد يتخذها التعويض بمقابل غير نقدي، هي صورة نشر الحكم الصادر في الصحف المحلية فليس من المستبعد أن يكون الدائن المتضرر شركة صناعية

أو زراعية أو تجارية، ولا شك أن ما تتمتع به هذه الشركات من سمعة تجارية له دور كبير في تحديد مدى نجاحها في ممارستها للنشاط الاقتصادي، وفي مدة تعامل الأفراد و الشركات الأخرى معها، لذا فإنها ستكون حريصة على سمعتها التجارية وعلى ضرورة تنفيذ المتعاقد معها لالتزاماته بكل دقة حماية لما تتمتع به من سمعة وثقة في التعامل، فلو حصل إخلال من جانب المتعاقد معها في تنفيذ التزامه، فيكون كافيا أن يتم نشر الحكم الصادر بإدانة من اخل بتنفيذ التزامه، وفي هذه الحالة لا يكون الحصول على مبالغ من النقود هو الدافع الأول لرفع دعوى التعويض.

والأصل في التعويض بمقابل أن يكون مبلغا من المال يدفع دفعة واحدة للمضرور ومع ذلك يجوز أن تختلف صوره، فيجوز للقاضي أن يجعله على أقساط تدفع للمضرور، كما يجوز أن تكون إيرادا مرتبا مدى الحياة، كما يجوز للقاضي أن يلزم المدين بتقديم تأمين معين.

الفرع الثاني : شروط استحقاق التعويض

إن التعويض كجزاء لتحقق مسؤولية المدين المخل بتنفيذ التزامه، لا يحكم به لمجرد رفع دعوى المطالبة به من قبل الدائن، فلابد أن يتأكد القاضي من توافر جملة من الشروط، وهو يتولى النظر في تلك الدعوى. وشروط استحقاق التعويض منها ما يتعلق باركان المسؤولية العقدية عموما، من خطأ وضرر وعلاقة سببية، والتي تندرج ضمن الشروط الموضوعية للتعويض، ومنها ما يتعلق بطبيعة القواعد التي تحكم المسؤولية العقدية بحيث يشترط توافر الاعذار، وعدم وجود اتفاق مسبق على الإعفاء من المسؤولية العقدية ونضمن هذه الشروط في الشروط الشكلية.

أولا : الشروط الموضوعية لاستحقاق التعويض

إن التعويض عن الضرر في المسؤولية، لا يكون مستحقا كما سبقت الإشارة إلا إذا توافرت شروطه، ومن البديهي أن تكون هذه الشروط هي نفسها أركان المسؤولية العقدية، ذلك انه إذا لم تقم المسؤولية العقدية فلا نكون أمام مسالة التعويض، والمسؤولية العقدية لا تنهض إلا لوقوع إخلال بالتزام عقدي هذا الأخير الذي يسبب ضر ا ر للدائن مما يستوجب التعويض عن هذا الضرر.

1. **الخطأ العقدي :** يعد الخطأ (الإخلال بتنفيذ التزم عقدي) شرطا ضروريا لاستحقاق التعويض؛ والإخلال المقصود هنا هو الإخلال بمعناه الواسع،" ذلك أن المتعاقد يسأل عن إخلاله الشخصي بالعقد، فتنهض المسؤولية العقدية عن الخطأ الشخصي إذا توفرت بقية الأركان، كما أنه قد يسأل عن خطأ الغير أو عن الأشياء التي تحت حراسته .كما قد تعدل قواعد المسؤولية العقدية بالاتفاق عن طريق التامين من المسؤولية."

لاشك أن هناك بعض الصعوبات التي تكتنف تحديد المقصود بالخطأ العقدي، نظرا لما أحاط فكرة الخطأ بحد ذاته من غموض ، كما أن ارتباط تلك الفكرة بفكرة الأخلاق جعلها غير محددة، لان فكرة الأخلاق يعوزها التحديد و الضبط، الأمر الذي انعكس على فكرة الخطأ، إلا أن ذلك لا يعني استحالة إعطاء تعريف للخطأ خاصة في نطاق المسؤولية العقدية، ذلك أن تحديد مفهوم الخطأ في المسؤولية العقدية أيسر من تحديده في المسؤولية التقصيرية ، ففي الأولى توجد ا ربطة قانونية بين الطرفين، وهذه الرابطة هي التي تحدد العلاقة بين المتعاقدين، فأي تجاوز لممارسة تلك الرابطة من حدود؛ يوصف بأنه خطأ أي الإخلال بالالتزامات التي تولدت عن تلك الرابطة، أما في المسؤولية التقصيرية فلا وجود لتلك الرابطة، وبالتالي تظهر صعوبة إعطاء تعريف

للخطأ التقصيري. وقد طرحت تعاريف متعددة للخطأ؛ فقد عرفه جانب من الفقه بأنه "عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه" بينما اتجه جانب أخر من الفقه إلى اعتبار أن الخطأ العقدي هو الإخلال بالالتزام، ففي الفقه الفرنسي يرى الأستاذ بلانيول أن الخطأ هو الإخلال بالتزام سابق. أما الأستاذ سافاتييه فقد عرف الخطأ انه إخلال بواجب قانوني كان في وسع المخل أن يتجنبه.

وهناك من عرف الخطأ العقدي على انه عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ من العقد، فالمدين التزم بالعقد وعليه تنفيذ التزامه بينما ذهب فقهاء آخرون إلى اعتبار أن الخطأ "إخلال بواجب قانوني سواء كان التزاما بمعناه الدقيق مسؤولية عقدية ، أم كان واجبا قانونيا عاما تترتب المسؤولية التقصيرية عن الإخلال به".

- ✓ وفي رأينا أن التعريف الذي أورد عبارة الإخلال هو أشمل تعريف للخطأ العقدي، ذلك انه بقولنا أن الخطأ العقدي هو الإخلال بالت ا زم عقدي نكون بذلك قد أعطينا تعريفا كاملا للخطأ يشمل كل صور الخطأ العقدي، سواء كان لعدم التنفيذ؛ أو للتأخر فيه؛ أو التنفيذ المعيب.

وقد ذهب فقهاء القانون حسب معيار تدرج الخطأ إلى تقسيم الخطأ إلى ثلاثة درجات : جسيم، ويسير، وتافه. فالخطأ العقدي الجسيم هو الخطأ الذي لا يرتكبه أشد الناس إهمالا، وهو اقرب إلى العمد ويلحق به، وخطأ يسير لا يرتكبه الشخص المتوسط أو المعتاد، وآخر تافه لا يرتكبه الشخص الحازم الحريص في شؤونه، كما قسم هذا الفقه العقود تبعا لذلك إلى طوائف ثلاث :عقود تعقد لمصلحة الدائن وحده، كالوديعة بلا أجر، وفيه يسال المدين عن الخطأ الجسيم فقط، وأخر يعقد لمصلحة المتعاقدين ويشمل عقد المعاوضة، وفيها يسال المدين عن خطئه اليسير، وأخر يعقد لمصلحة المدين وحده كالإعارة وفيه يسال المدين عن الخطأ التافه[27]

غير أن اغلب التشريعات هذه النظرية نظرا لعدم استيعابها لفكرة الخطأ ومنها القانون الفرنسي الذي اتخذ النظرية الحديثة مسارا له أو ما يسمى بنظرية الرجل العادي.

و المقصود بإثبات الخطأ العقدي هو إثبات وقوع الإخلال بالعقد سواء عن عدم القيام بالتنفيذ أو التأخر فيه أو تنفيذه بصورة معيبة، أو تنفيذه بصورة جزئية. كما قد يجتمع أكثر من صورة في عقد واحد كالتأخر في التنفيذ مع التنفيذ المعيب. والقاعدة في مجال الإثبات هي أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فالدائن هو الذي يدعي بوقوع الإخلال بالالتزام العقدي فعليه أن يثبت وجود العقد الصحيح وحصول الضرر بعدم بذل المدين للعناية المطلوبة أو عدم تحقق النتيجة المرجوة الأمر الذي يسبب له خسارة مادية أو معنوية، وربما يثبت المدعى عليه عدم

وجود الضرر أو يثبت انتفاء ا ربطة السببية بقيام السبب الأجنبي.

[27] عبد الرزاق السنهوري، **مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الجزء السادس**، دار إحياء التراث العربي، ص 116 و 117

وكمثال عن الالتزام بتحقيق نتيجة، التزام المؤجر تجاه المستأجر، كأن يثبت المستأجر خطأ المؤجر كامتناعه عن تسليم العين المؤجرة مثلا لغرض الانتفاع بها، فعلى المؤجر هنا إثبات العكس كان يثبت أن عدم تسليمه للعين المؤجرة كانت لأسباب لا يد له فيها وإنما تعود مثلا للقوة القاهرة كالمرض مثلا.
وفي الالتزام ببذل عناية، التزام الطبيب مثلا بعلاج المريض فيثبت المريض أن الطبيب ارتكب خطا باستئصاله للكلية السليمة بدلا من الكلية المريضة، أو أن تشخيصه للمرض ليس صحيحا، وعلى الطبيب هنا أن يثبت العكس وانه بذل العناية المطلوبة.

2. **الضرر :** لما كانت الغاية من التعويض هي جبر الضرر وإزالته، لهذا لا يكفي مجرد إخلال المدين بتنفيذ التزامه من اجل الحكم عليه بالتعويض، فلابد من أن يترتب عن هذا الإخلال ضرر يصيب الدائن، فالضرر هو ركن أساسي من أركان المسؤولية، ويوصف بأنه روح المسؤولية وعلتها التي تدور مع الضرر وجودا وعدما وشدة وضعفا.
"فإذا انعدم الضرر انعدمت معه دعوى التعويض طبقا للقاعدة التي تقضي بأن لا دعوى بلا مصلحة"، فتحقق الضرر هو شرط ضروري لاستحقاق التعويض باعتبار أن هذا الأخير يعتبر جزاء المسؤولية العقدية.[28]
و الضرر لغة يعني : "عدم النفع، والشدة والضيق وسوء الحال، و النقص في الأموال والأنفس".
و يعرَف في الفقه الإسلامي بأنه " إلحاق مفسدة بالآخرين أو هو كل إيذاء يلحق بالشخص سواء كان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته."
أما تعريفه قانونا " :فهو عبارة عن أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة مالية أم لم تكن."
أما الضرر في المسؤولية العقدية هو" ذلك الذي ينشا عن الإخلال بالتزام عقدي يربط بين المتعاقد المتضرر مع آخر اخل به، فيشكل عدم القيام بالالتزام أو للتأخر في التنفيذ أو لتنفيذه بصورة معيبة أو لتنفيذه بصورة جزئية"، وفي إطار المسؤولية العقدية فانه تتطلب شروط محددة في الضرر حتى يتم التعويض عنه و تتمثل هذه الشروط فيما يلي :

[28] عبد الرزاق السنهوري، **الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، مصادر الالتزام**، مرجع سابق، ص 670.

- **أن يكون الضرر مباشرا:** قد تتعدد الأضرار التي تصيب الدائن نتيجة لإخلال المدين بتنفيذ التزامه، فهل يكون المدين مسؤولا عن تلك الأضرار ؟، خاصة أن الأضرار الناتجة قد تتصل اتصالا مباشرا بواقعة خرق العقد، أو تكون في أحيان أخرى نتيجة غير مباشرة وغير متصلة بها، وتوصف بأنها الأضرار بعيدة الصلة بها، بعدا يختلف سعة وضيقا باختلاف الأحوال، فالدائن لا يستطيع المطالبة إلا بتعويض الضرر المباشر، يوصف الضرر بالمباشر متى كان نتيجة طبيعية لإخلال المدين بتنفيذ التزامه، ويكون الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن باستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. وإذا كان معنى الضرر المباشر بالنحو الذي رأيناه، فالتعويض لا يكون إلا عنه سواء كان ذلك في المسؤولية العقدية أم التقصيرية، لأنه في الضرر غير المباشر تنتفي الرابطة السببية؛ ويتخلف ركن من أركان المسؤولية. و إذا كان التعويض عن الضرر المباشر فقط، فان ذلك يكون مقتصرا على الضرر المباشر المتوقع في المسؤولية العقدية، أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن كل الضرر المباشر متوقعا كان أو غير متوقع. هذا وإذا كانت مسؤولية المدين العقدية مقتصرة على الضرر المباشر المتوقع فان ذلك مرتبط بعدم صدور غش أو خطا جسيم من طرفه .لأنه في هذه الحالة الأخيرة يعتبر المدين مسؤولا عن ضرره المباشر المتوقع أو غير المتوقع.
- **أن يكون الضرر محققا:** يشترط في الضرر أن يكون محققا حتى يمكن تعويضه، أما إذا كان محتملا فلا يعوض لأنه ضرر افتراضي والأحكام لا تبنى من الافتراض، فلا يكون التعويض إذن إلا عما تحقق من ضرر. فيشترط لصدور الحكم بالتعويض أن يثبت للمحكمة أن المدعي كان يكون في مراكز أفضل لو لم يقترف المدعى عليه ما اقترفه من عمل خاطئ، والمسألة واضحة وبسيطة متى كان الضرر الذي لحق بهذا المدعي قد وقع بالفعل. فالضرر الذي يعوضه هو الضرر المحقق فقط، وهو إما أن يكون ضررا حالا، أو مستقبلا، فالضرر الحال هو ذلك الضرر الذي وقع فعلا وتكونت عناصره ومظاهره التي توفر للقاضي إمكانية تقديره وتحديد مقداره، أما الضرر المستقبل فهو الضرر الذي حدث سببه، ولكن نتائجه كلها أو بعضها قد تراخت إلى المستقبل، ويجوز التعويض عنه طالما انه محقق الوقوع في المستقبل.
- **أن لا يكون الضرر قد سبق تعويضه:** سبقت الإشارة إلى أن الهدف من المسؤولية العقدية هو الحصول على التعويض عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو التأخر فيه، وبالتالي بمجرد حصول الدائن على هذا

التعويض، فان الأمر يكون منته لان الغاية الأساسية قد تم الوصول إليها، وهي الحصول على التعويض بالحكم فيها، وعليه لا يستطيع الدائن رفع دعوى أخرى للحصول على تعويض آخر،على أساس سبق الفصل في الدعوى، كما انه لا يجوز له الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر. ومسالة عدم جواز الجمع بين تعويضين لاقت نقاشا حادا بين الفقهاء؛ خاصة في حالة وجود عقد تأمين، ذلك أن الشخص الذي يدفع التعويض في هذه الحالة ليس مرتكب الخطأ والمتسبب في الضرر، وإنما شركة التأمين، فهل يجوز في هذه الحالة الجمع بين تعويضين؟ ذلك أن مسؤولية الطرفين ثابتة . فشركة التأمين مسؤولية بمقتضى عقد التأمين والمدين باعتبار انه مرتكب الخطأ .للإجابة على هذه الإشكالية يقتضي الأمر التفرقة بين فرضين:

الفرض الأول إذا كان المسؤول هو المستأمن (أي المؤمن له)، فلا يجوز للمضرور الذي حصل على التعويض من المؤمن (شركة التامين)، أن يرجع بعد ذلك على المسؤول بتعويض آخر إلا في حالة عدم تمكنه من الحصول على تعويض كامل من شركة التامين، فيرجع على المسؤول بما يكمل التعويض.

أما الفرض الثاني إذا كان المضرور هو المؤمن له، فيجب في هذه الحالة التفرقة بين التامين على الأشخاص والتامين على الأشياء: فإذا كان المضرور مؤمنا على حياته ضد الحوادث التي عساها أن تقع له، كان للمضرور آو لورثته حقا لحصول على التعويض من شركة التامين، وحق التعويض من المسؤول. وبذلك يجمع بين الحقين لان لكل حق مصدرا غير المصدر الذي قام عليه الحق الآخر، فالحق في التعويض مصدره الخطأ الذي ارتكبه المسؤول، ومبلغ التامين مصدره عقد التامين، وليس له صفة التعويض بل هو مقابل الأقساط التي دفعها المضرور لشركة التامين.

وهذا الحكم يجد تأييدا صريحا في نص المادة 765 قانون مدني فرنسي التي تقضي بأنه " :في عقد التامين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث.

ونجد نفس الحكم في القانون المغربي فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 61 من

مدونة التأمينات على أنه : "يمكن جمع التعويض الذي يتوجب على الغير المسؤول دفعه للمؤمن له أو لذوي حقوقه مع المبالغ المكتتبة في تامين الأشخاص"

- **أن يكون الضرر قد أصاب المتضرر شخصيا** : بمعنى أن يكون الضرر قد أصاب طالب التعويض شخصيا، فليس له أن يطالب بتعويض عن ضرر أصاب غيره وبالتالي يشترط في طالب التعويض، أن يكون الضرر قد أصابه شخصيا، وذلك له أشد الارتباط بشرط المصلحة في طالب الدعوى التي سبق الإشارة إليه، إلا انه يحق للمدعي المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بغيره إذا كان نائبا له أو خلفا كالوارث، بعد أن يثبت انه وارث ويتحقق هذا الشرط سواء كان المضرور شخصا طبيعيا أو معنويا، كما يتحقق بالنسبة للضرر الذي يصيب أشخاص آخرين، وهو ما يسمى بالضرر المرتد والذي يعتبر ضررا شخصيا لمن ارتد عليه.

✓ **من خلال ما سبق يتبين لنا أن المسؤولية العقدية لا تستوجب تعويض كل ضرر، وإنما لا بد أن تتوافر في هذا الأخير مجموعة من الشروط حتى نكون أمام ضرر مستحق للتعويض، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون الضرر مباشرا وان يكون محققا، وان لا يكون قد سبق تعويضه.**

3. **علاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر:** لا يكفي أن يقع خطأ من المدين وان يلحق ضرر بالدائن حتى تقوم المسؤولية العقدية لاستحقاق التعويض، بل لابد أن يكون هذا الخطأ هو السبب في الضرر، وهذا هو المقصود بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، باعتبارها ركنا من أركان المسؤولية العقدية، والمشرع لم يلق على الدائن عبء إثبات وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر، بل افترض أن الضرر ا رجع إلى الخطأ وعلى المدين إذا كان يدعي عكس ذلك أن يقوم بنفي علاقة السببية بين الخطأ و الضرر.

فالمدين ينفي علاقة السببية إذا اثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه أي راجع لسبب أجنبي. وقد تم تأكيد المبادئ المشار إليها من طرف القضاء المدني ، حيث جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا أن : "العلاقة التي تربط بصاحب الحمام هي عقد خدمات ومثل هذا العقد يضع على عاتق صاحب الحمام التزاما بسلامة الزبائن وهو التزام بنتيجة، المسؤولية فيه مفترضة ما لم يثبت أن الحادث يرجع إلى سبب لا يد له فيه"[29]

فعلاقة السببية هي معيار التفرقة بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر، ويتجلى هذا المعيار في أهمية وجود العلاقة بين فعل المسؤول وما نجم عنه من ضرر للمضرور، وكلما وجدت هذه العلاقة، أصبح الضرر نتيجة حتمية أو محققة للخطأ، فإذا تخلفت هذه العلاقة كنا بصدد ضرر غير مباشر. [30]

---

[29] قرار رقم 20310 مؤرخ في 1983/03/02 ، نشرة القضاة 1987، عدد 01 الصفحة 64.

[30] RAYNAUD: **Cours de droit civil,** polycopié, Paris, année 1961-1962, P 744.

ثانيا : الشروط الشكلية لاستحقاق التعويض

بالإضافة إلى الشروط السابقة الذكر ، والتي يجب توافرها من أجل استحقاق التعويض، والتي تتعلق بأركان المسؤولية العقدية، فإنه لابد من توافر شروط خاصة أخرى، حتى نقول أن التعويض مستحق في المسؤولية العقدية، وهذه الشروط متعلقة بطبيعة القواعد التي تحكم المسؤولية العقدية، وهي شرطين أولهما الاعذار، والثاني هو عدم الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية.

1. الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض (إعذار المدين) :

الاعذار عمل ايجابي يصدر من الدائن ويعبر فيه عن رغبته بضرورة قيام المدين بتنفيذ التزامه وإلا كان مسؤولا عن ذلك، ويتخذ هذا العمل شكلا يبينه القانون.

فالإعذار كقاعدة عامة شرط لقيام المسؤولية وللمطالبة بالتعويض، وهذا يعني أنه لا إلزام على المدين في دفع التعويض إلى الدائن المتضرر،ما لم يقم الأخير بإعذار الأول بالوفاء بما ترتب في ذمته من تعويض نجم عن تحقق مسؤوليته العقدية، والغرض من هذا الإجراء هو انتفاء شبهة الدائن بتأخير الوفاء، وشبهة إقراره الضمني بعدم حصول ضرر له من ذلك التأخير.

وقد جاء النص على الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية في جل التشريعات العربية نذكر على سبيل المثال ما جاء في المادة 281 من القانون المدني المصري: "لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك."

فمن خلال هذا النص جعل المشرع المصري التعويض غير مستحق إلا بعد قيام الدائن بإعذار المدين وبالتالي الاعذار شرط أساسي لاستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية.

هذا وإذا كانت القاعدة العامة هي أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، فانه وردت مجموعة من الاستثناءات على هذه القاعدة فهناك حالات لا ضرورة فيها للاعذار، وهي الحالات التالية:

- إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين.
- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر.
- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق، أو شيء استلمه دون حق وهو عالم بذلك.
- إذا صرح المدين كتابة أنه ينوي تنفيذ التزامه.

وتطبيقا لذلك نعطي أمثلة عن هذه الحالات:

- **إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين،** كما لو التزم مقاول ببناء جناح في معرض، ويقام المعرض وينتهي دون أن يقوم المقاول بتنفيذ التزامه، أو يتعهد محام برفع طعن في إحدى الأحكام و يهمل في ذلك حتى ينقضي موعد الطعن، ففي هاته الحالات لا ضرورة فيها للاعذار نظرا لأن تنفيذ الالتزام أصبح غير ممكن وغير مجد.
- **إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل مضر،** وهنا أيضا يكون عدم لزوم الاعذار قائما على نفس علة الاستغناء عنه في الحالة السابقة، فارتكاب العمل غير المشروع إخلال بواجب الحيطة والحذر؛ لمنع إحداث ضرر للغير، ولمجرد ترتب الضرر على خطأ المسؤول يوجب التعويض . فبعد حدوث الضرر لا يتصور وجوب الاعذار.
- **إذا كان محل الالتزام تعويضا رد شيء يعلم المدين انه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك،** فتقصيره في هذه الحالة بين، ولا يحتاج إلى أي إجراء من قبل صاحب الحق في استرداد ذلك الشيء لإثباته، ولذا لم يجد القانون فائدة من الاعذار في هذه الحالة.
- **إذا صرح المدين كتابة انه لا ينوي تنفيذ التزامه،** فبعد صدور هذا التصريح مكتوبا لا معنى لإلزام الدائن بمطالبة المدين بالتنفيذ العيني، بعد أن ثبت امتناعه عن الوفاء ثبوتا جازما.

2. عدم وجود اتفاق مسبق على الإعفاء من المسؤولية:

تقوم المسؤولية العقدية بمجرد اكتمال أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وبمجرد توافر هذه الأركان يتم الحكم بالتعويض. غير انه قد يتم إعفاء المدين المسؤولية بناء على اتفاق الطرفين، ذلك أن العقد كما هو معروف ينشأ عن الإرادة، فتكون الإرادة هي أساس المسؤولية ولهذا يكون لها في الأصل حرية تعديل أحكام المسؤولية العقدية إما بالتشديد أو التخفيف أو الإعفاء. غير أن هذا التعديل لا يكون مطلقا بحيث يظل المدين مسؤول عن غشه وخطئه الجسيم، إلا أن المتعاقد قد يعفي نفسه من الغش والخطأ الجسيم الذي يصدر من الغير الذين يستخدمهم لتنفيذ التزامه.

وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشا عن غشه، أو خطئه الجسيم، غير انه يجوز أن يشترط إعفائه من

المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه ويبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي.

والأصل هو جواز هذا الشرط في مجال المسؤولية العقدية، وبطلانها في مجال المسؤولية التقصيرية. فبالنسبة للمسؤولية العقدية، فالأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعدها، وذلك نتيجة منطقية للاعتراف بحقهم في إنشاء الروابط التعاقدية، كل ذلك في حدود القانون والنظام العام والآداب العامة. و بمفهوم المخالفة فان هذا الجواز ينصب على الأخطاء الشخصية اليسيرة فقط، أما إذا كان الشرط يرمي إلى الإعفاء مما قد ينشأ عن الغش وما يلحق به من خطأ جسيم، فإنه يعد باطلا، ويبرر هذا الحكم بأنه لو اجزنا ذلك لكان الالتزام التعاقدي معلقا على شرط إرادي محض.

وبالتالي كما سبقت الإشارة وباعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، فيمكن للطرفين الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب عن عدم تنفيذه لالتزامه التعاقدي، بشرط أن لا يكون هذا الاتفاق مخالف للنظام العام والآداب العامة، وبالتالي يصبح التعويض غير مستحق في هذه الحالة غير انه لا يمكن الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية الناتجة عن غشه أو خطئه الجسيم، باستثناء إذا كان هذا الغش أو الخطأ الجسيم يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

وتجدر الإشارة إلى أنه ترد مجموعة من الاستثناءات على مبدأ جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية، فإذا كان الأصل هو جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية إلا في حالتي الغش و الخطأ الجسيم الصادرين من المدين، إلا أن هناك استثناءات على هذا المبدأ أشار إليها الفقه نبينها فيما يلي:

- **بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية عن الأضرار الجسدية:** يعد جسد الإنسان وحياته ومقوماته المعنوية من القدسية والاحترام، ما يجعلها في منأى عن أي اتفاق من شانه أن يمس بها، فهذه حقوق لصيقة بشخص الإنسان تولد معه وترتبط به حتى وفاته ويقع أي اتفاق على المساس بها باطلا ، وهذا ما ذهب إليه غالبية شراح القانون، الذين أشاروا إلى انه لا يجوز الاتفاق على إعفاء المدين عن الأضرار الجسدية، لان جسم الإنسان يخرج عن دائرة التعامل المالي، ولأنه ليس شيئا قابلا للتصرف به.
- **إبطال شرط إعفاء التاجر من مسؤوليته تجاه المستهلك:** من الناحية التجارية يعد العقد المبرم بين التاجر والمستهلك من العقود التجارية المختلطة التي تعتبر بالنسبة لطرف عملا مدنيا، وهو المستهلك، ولطرف أخر علاقة تجارية وهو التاجر . وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني نجد أن المشرع تدخل في كثير من العقود لمصلحة الطرف الضعيف. وفي هذه الحالة يثور التساؤل : **هل يجوز إدراج شرط**

يعفي التاجر من المسؤولية العقدية؟. وللإجابة عن هذا التساؤل نقول :أن القضاء الفرنسي ذهب أثناء تطبيقه لمرسوم عام **1978** المتعلق بحماية المستهلك من الشروط التعسفية إلى الحكم بإبطال الشرط المعفي من المسؤولية، وذلك في عقد البيع دون غيره من العقود، فقد نصت المادة الثانية من القانون المذكور أنفا بأنه يعتبر تعسفا الشرط الذي يكون محلا أو أثرا له إلغاء الحق في تعويض المستهلك في حالة إخلال البائع بأحد التزاماته أيا كانت، ومتى اعتبر الشرط تعسفيا على هذا النحو وجب اعتباره كان لم يكن واردا في العقد، بحيث يلغى الشرط ويصح العقد دون الرجوع أو الاعتداد بإرادة المتعاقدين غير المبينة في بعض الحالات على أسس سليمة في القانون والنظام.[31]

- **عدم جواز شرط الإعفاء من المسؤولية إذا كان تعسفيا في عقود الإذعان:** إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

✓ **الخلاصة المتوصل إليها هي أن التعويض حق للدائن والتزام للمدين؛ يثبتان في ذمتهما عند الإخلال بالالتزام، ويكون إما نقدي وإما في شكل ترضية أخرى مساوية للمنفعة التي كان سينالها الدائن لو لم يتم الإخلال الالتزام. ولاستحقاق هذا التعويض لابد من توافر مجموعة من الشروط الشكلية تتعلق بالأعذار وعدم وجود اتفاق مسبق على الإعفاء من المسؤولية العقدية، كما لا بد من توافر شروط موضوعية تتعلق باركان المسؤولية العقدية وهي الخطأ العقدي الصادر من المدين، والضرر اللاحق بالدائن والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.**

[31] محمد السيد عمران، **حماية المستهلك أثناء تكوين العقد**، دراسة مقارنة، منشأة المعارف الإسكندرية، جمهورية مصر، 1986، ص 36.

المبحث الثاني : كيفية التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام

بعد التعرض لمفهوم التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية في المبحث الأول، من خلال تبيان تعريفه، وكذا شروط استحقاقه في إطار المسؤولية العقدية، وكذا حددنا العناصر اللازم مراعاتها أثناء تحديده حتى يكون التعويض كاملا وكذا يحقق الهدف الذي شرع من أجله وهو جبر الضرر، فإن الإشكال المطروح في هذا المبحث هو : **كيف يتم تحديد هذا التعويض؟ أو ما هي طرق تحديد التعويض ؟ و ما هي الجهة المختصة بتحديده في إطار المسؤولية العقدية؟**

المطلب الأول : تقدير التعويض عن الضرر بوجه عام

عند توفر الشروط الواجبة لاستحقاق التعويض عن التأخير بشقيه، التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بوجه عام، والتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بأداء مبلغ من المال أو ما اصطلح على تسميتها بالفائدة القانونية، عندئذ ينشأ حق الدائن في طلب التعويض من مدينه، ولذلك لا بد من البحث في الطريقة التي وضعها المشرع لتحديد مقدار التعويض الواجب الأداء عن كلا نوعي التعويض عن التأخير، وتختلف هذه الطريقة تبعًا لاختلاف نوع الالتزام، فإذا كان الالتزام الذي تأخر المدين في تنفيذه هو أداء مبلغ من المال معين المقدار وحال الأداء، عندئذ يتولى القانون مهمة تقدير التعويض بما يعرف الفائدة القانونية، مع إمكانية وجود دور لإرادة طرفي العقد في تحديد مقدار هذا النوع من التعويض. أما إذا كان الالتزام الذي تأخر المدين في تنفيذه هو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، فإن القضاء والاتفاق هما اللذان يتوليان مهمة تحديد مقدار التعويض المستحق، أو ما يعرف بالتعويض القضائي والاتفاقي، فقد حدد المشرع ثلاث طرق لتحديد مقدار التعويض -كما سبق ذكره- هي التعويض الاتفاقي والقانوني والقضائي، وتتوزع دراسة هذه المواضيع على الفرعين التاليين:

الفرع الأول : التقدير الاتفاقي

في المجال التعاقدي، يمكن للأطراف المتعاقدة الاتفاق على تحديد مجال المسؤولية فالعديد من النصوص المنظمة للمسؤولية التعاقدية هي نصوص مكملة،" كما يمكن للأط ا رف الاتفاق مسبقا على تقدير قيمة التعويض المستحق للدائن في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو التأخير في تنفيذه، فالأصل هو أن القاضي هو الذي يقوم بتقدير التعويض، غير انه يمكن الاتفاق مسبقا على قيمة هذا التعويض، وهذا ما يسمى بالشرط الجزائي لأنه

يوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي ولكن قد يدرج في اتفاق لاحق. و لفهم طبيعة الشرط الجزائي وما يثيره من إشكالات كان لا بد أن نتعرف مفهوم الشرط الجزائي **(أولا)**، و كذا الطبيعة القانونية لهذا الشرط **(ثانيا)**.

أولا : مفهوم الشرط الجزائي

لقد شاع استعمال الشرط الجزائي في الحياة المعاصرة لاسيما في مجال المعاملات المدنية و التجارية، فالبائع يلجأ إليه حتى يضمن قيام المشتري بتسليم الشيء المبيع، والمشتري يشترطه حتى يضمن سداد الثمن دون تأخير. ولا يجوز التعويض الاتفاقي في المسؤولية التقصيرية نظرا لاعتبارات معينة، لكون مصدر هذه المسؤولية هو القانون، ولكون المسؤول غريبا عن المضرور قبل وقوع الحادث.

و عند تتبعنا للفقه و القضاء والقانون، فيما يخص التعويض الاتفاقي، فإننا نجده يحمل تسميات مختلفة، وترددت هذه التسميات بين عبارات ثلاث هي : الشرط الجزائي، البند الجزائي،و التعويض الاتفاقي.

فعبارة الشرط الجزائي قد حظيت بتفصيل الفقه والقانون القضاء، لأنها تشير بصفة عامة إلى كل شرط مضاف إلى العقد أو إلى التصرف القانوني الصادر من جانب واحد.

وعبارة البند الجزائي هي الترجمة الصحيحة لهذا المصطلح في القانون الفرنسي. أما عبارة التعويض الاتفاقي :فإنها تبين التعويض الجزافي الذي يحمله الشرط الجزائي، ويعمد إلى هذا الاصطلاح بعض فقهاء القانون الذين لا يرون في هذا النظام سوى طبيعته التعويضية.

أما الفقه الإسلامي فإنه لا يهتم بالصيغ، لأنه يرى أن الأصل في المعاملات التوسع ولأن الألفاظ لا تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده؛ وضح بأي طريقة كان العمل بمقتضاه.

ومهما اختلفت التسميات فالمعنى يبقى واحد، والتسمية الأكثر شيوعا و استعمالا من طرف الفقه و القضاء و القانون هي تسمية **"الشرط الجزائي"**.وقد وردت تعريفات فقهية عديدة للشرط الجزائي نذكر منها :

هو ضمان تنفيذ التزام معين بإلزام المتعهد بشيء ما يتعين عليه أداؤه في حالة عدم التنفيذ.[32] كما عرف بأنه : اتفاق يتعهد به المدين بدفع مبلغ معين من المال في حالة عدم

[32] مأمون الكزبري، **النظرية العامة للالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام و انتقاله و انقضاؤه**، بيروت 1967، ص 237

قيامه بتنفيذ ما تعهد به، أو تأخر في تنفيذه ويكون هذا التعيين تحديدا مقطوعا مسبقا بتعويض.[33] كما جاء في تعريف آخر :الشرط الجزائي هو اتفاق يقدر فيه المتعاقدان سلفا التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه، أو إذا تأخر في تنفيذه.[34]

ويتضح من خلال التعاريف السابقة أن كل منها يشوبها قصور معين فتناست الطبيعة القانونية للشرط الجزائي، ولا تعتبر إلا تركيبا وظيفيا يؤدي بنا إلى الخلط بين الشرط الجزائي وأوضاع قانونية أخرى نبينها في حينها. لذلك نقول أن اشمل تعريف للشرط الجزائي هو القائل بأن الشرط الجزائي هو" بند عقدي ، يدرجه المتعاقدان في عقدهما أو في اتفاق لاحق، لضمان احترام العقد وكفالة تنفيذه بحيث انه إذا أخل المتعاقد بالتزامه أدى مبلغا معينا للمتعاقد الأخر فهو في الحقيقة تقدير اتفاقي للتعويض[35]"

وقد يكون التعويض المتفق عليه مسبقا (الشرط الجزائي)، إما مبلغا من النقود أو أداء عمل أو الامتناع عنه فليس هناك مانع لتحديد التعويض بغير النقود كما سبق الإشارة في المبحث الأول من هذه الدراسة. وقد تضمنت أغلب التشريعات النص على الشرط الجزائي نذكر منها ما جاء في المادة223 من القانون المدني المصري :" يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق". و يكمن الغرض من وضع الشرط الجزائي ضمن بنود العقد أو بناء على اتفاق لاحق له، في تحقيق الأهمية التالية:

- **قطع النزاع المحتمل حول مقدار التعويض :** وذلك باعتبار أن الشرط الجزائي اتفاق مسبق على التعويض، فقد لا يرى الطرفان ترك الأمر بتقدير التعويض للقاضي، ويضمنان العقد المنشئ للالتزام بند يحددان فيه جزاء الإخلال به، فيتفقان مقدما على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، فيكون ذلك شرطا جزائيا متضمنا تعويضا إتفاقيا عن عدم التنفيذ، أو على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا تأخر المدين في التنفيذ، فيكون ذلك شرطا جزائيا عن التأخير، وقد لا يدرج الشرط الجزائي في صلب العقد الأصلي بل يتضمنه اتفاق لاحق.
- **حمل المدين على تنفيذ التزامه :** الأصل يقول أن المتعاقدان لا يبرمان العقد إلا لكي يلتزمان بما جاء فيه، ولكن قد تطرأ ظروف تجعل المدين يغير رأيه في التنفيذ، أو يرى أن من مصلحته التأخير في التنفيذ دون وضع حساب للدائن. لذلك يتم وضع شرط جزائي للضغط على المدين ولو بصورة غير مباشرة لتنفيذ التزامه دون تأخير.

---

[33] موريس نخله، **مرجع سابق**، ص 225

[34] مصطفى محمد الجمال، **ضمانات التعويض في ظل تطور المسؤولية العقدية**، ص 124

[35] عبد الرزاق السنهوري، **مرجع سابق**، ص 556

- **التحديد الاتفاقي للتعويض هو الأقرب لحقيقة الضرر :** ذلك أن المتعاقدين هما أعلم الناس بوضعهما وما يمكن أن يسبب عدم التنفيذ أو التأخير فيه من ضرر، وهما الأقدر على تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر، فعدالة التعويض المحدد مسبقا يحول في كثير من الأحيان، دون إعادة النظر في مقدار التعويض المتفق عليه.
- **جعل رقابة القاضي على تقدير التعويض رقابة هادئة ومحدودة:** لاشك أن البند الجزائي يحول دون تحكم القاضي في تحديد التعويض، نظرا لتقديره المسبق، غير أن هذا لا يحول دون طلاقة رقابة القاضي على مدى شرعية البند الجزائي، فيبطله إن رأى فيه غشا أو مخالفة لقواعد النظام العام.

ويهدف الشرط الجزائي، بصفة أصلية، إلى تقدير التعويض المستحق لأحد طرفي العقد عن الأضرار التي تنتج عن مخالفة الطرف الآخر لالتزامه، الذي اقترن به الشرط الجزائي، وتتحقق هذه الوظيفة التعويضية للشرط الجزائي في الحالة التي يتناسب فيها المقدار الذي حدد به مع حقيقة الأضرار التي تترتب على الإخلال بالالتزام الأصلي.

ثانيا : الطبيعة القانونية للشرط الجزائي

إذا ضمن المتعاقدان عقدهما أو عقدا لاحقا بندا جزائيا، فإنه ينشأ عنه التزام جديد، هو الالتزام بالشرط الجزائي، يتميز من حيث مضمونه وماهيته القانونية عن الالتزام الأصلي، الذي يمكن أن ينشأ مجردا عن الشرط الجزائي، فقد يتشابه الالتزام بالشرط الجزائي ببعض الأنظمة القانونية الأخرى، ولكنه يظل مع ذلك نظاما خاصا مستقلا بذاته، لما يتميز به من خصائص قانونية ذاتية.

و هناك بعض الأوضاع القانونية التي قد تبدو شرطا جزائيا إلا أنها تختلف عنه، فهو يتميز بطبيعته المستقلة، ونوضح ذلك فيما يلي :

1. **الشرط الجزائي ليس التزاما شرطيا:** الشرط كوصف للتراضي أو كوصف للالتزام العقدي، هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام الإرادي أو زواله. والشرط بهذه المثابة أمر عارض، أما الشرط الجزائي فهو جزء من مضمون العقد الأصلي أو الاتفاق اللاحق، يقصد به ضمان تنفيذ العقد لا تعليقه، وهو بهذا يكون موجود من البداية ولذا يتصور تعليق الشرط الجزائي ذاته على شرط، حيث يكون وجود الشرط كوصف مستقلا عن الشرط الجزائي. وبالتالي فإن الشرط الجزائي لا يهدف إلى صيرورة الالتزام الأصلي التزاما شرطيا، فتترتب على ذلك نتيجة عملية هامة تتمثل في أثر السبب الأجنبي في عدم

تنفيذ الالتزام الأصلي وعدم تحقق الشرط كوصف، فبينما يؤدي تعذر تنفيذ الالتزام الأصلي بسبب أجنبي لا يرجع للمدين إلى عدم إمكان تطبيق الحكم الجزائي على الشخص فإنه المدين في عقد شرطي لا يستطيع التنصل من التزامات الإدعاء بأن سببا أجنبيا قد حال دون تحقق الشرط.

2. **<u>الشرط الجزائي ليس عربونا:</u>** الشرط الجزائي هو تقدير اتفاقي للتعويض، ولذا فإنه قد يختلط بالعربون الذي يدفعه أحد المتعاقدين كمقابل للضرر الفعلي الذي لحق الطرف الآخر، وبقدر يتناسب مع هذا الضرر، ووجه التشابه الظاهري بين الشرط الجزائي وبين العربون يكمن في أن كلا منهما ينشأ بالاتفاق، كما أن العربون كمقابل لحق العدول يفقده من قدمه في حالة عدوله، ويرده ومثله إذا عدل الطرف الآخر، فيكون العربون بمثابة مقابل لضرر مفترض الحدوث بسبب العدول عن العقد.

ولكن هذا التشابه الظاهري يزول عند الوقوف على الطبيعة الذاتية الخاصة لكل من هاذين النظامين:

إن العربون كمقابل لحق العدول يستحق حتى ولو لم يلحق المتعاقد الأخر ضرر من جراء العدول، بل أنه لا يحق للطرف المضرور أن يطلب زيادة العربون حتى وان كان الضرر الذي لحقه أكبر من مبلغ العربون، ومن ثم يخضع مقدار العربون للسلطة التقديرية للقاضي، وكل ذلك على خلاف الشرط الجزائي الذي يجب أن يكون مقداره متناسبا مع ما لحق الدائن من ضرر بسبب عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه، ولذا يحق للقاضي مراجعة مقدار التعويض الاتفاقي، فيكون له أن يخفض مقداره، كما يكون له أن يلغيه كليا إذا ظهر أن الدائن لم يلحقه ضرر على الإطلاق، وكل هذا إعمالا للطبيعة الذاتية لكل من هاذين النظامين، فالشرط الجزائي كما يقول الأستاذ فلاكو بولس : "هو اتفاق من نوع خاص يخضع في نظامه القانوني للعقد الأصلي، ويشترط لاستحقاقه توافر عناصر خاصة هي عناصر استحقاق التعويض بوجه عام، وليس هذا هو شأن العربون الذي يدفع كثمن للعدول".

ويترتب على الاختلاف السابق بين طبيعة الشرط الجزائي وبين طبيعة العربون، أن العربون لا يشترط لاستحقاقه صدور خطأ ممن صدر منه العدول، بل أن ذلك الخطأ لا يمكن تصوره ممن عدل، حيث انه يستعمل حقا له منصوصا عليه في العقد، بعكس الشرط الجزائي الذي يفترض لإعماله خطأ من المدين ترتب عليه الضرر للدائن، ولذلك فالشرط الجزائي ينتفي بانتفاء خطأ المدين كقاعدة عامة.

من ناحية أخرى، فإنه يترتب على العربون منح المتعاقد الخيار بين التقيد بالعقد وتنفيذه، وبين العدول عنه مقابل دفع مقدار العربون، أما الشرط الجزائي فلا يمنح المدين الخيار بين تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، ويظل المدين ملتزما دائما بالتنفيذ العيني إن كان ممكنا ، فإن تعذر يلجأ إلى التنفيذ بمقابل، أي التعويض وإعمال الشرط الجزائي، وهكذا لا يرفع الشرط الجزائي على المدين واجبه الأول في التنفيذ العيني، ولا يسقط حق الدائن في طلب هذا التعويض.

3. **الشرط الجزائي ليس التزاما بدليا** : لا يشتمل محل الالتزام ألبدلي إلا على شيء واحد، ولكن ذمة المدين تب أ ر إذا وفى بشيء آخر يكون بديلا عنه، فلكي يكون أمام الالتزام ألبدلي، يجب أن يكون لهذا الالتزام محل واحد هو المحل الأصلي، ويقوم مقام هذا المحل الأصلي شيء آخر هو البديل، ويتميز الالتزام ألبدلي بأنه يجيز للمدين أن يؤدي أداء من اثنين : أما المحل الأصلي للالتزام و إن المحل البديل، وفي الحالتين تب أ ر ذمته بهذا الأداء.

وللالتزام البدلي أحكام منها أنه إذا هلك المحل الأصلي للالتزام بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، فإن الالتزام ينقضي حتى و إن كان البديل لا ا زل قائما قياما يتسنى معه للمدين الوفاء به، وسبب انقضاء الالتزام رغم ذلك يرجع إلى أن محل الالتزام هو المحل الأصلي، وليس المحل البديل، فإذا هلك المحل الأصلي بسبب أجنبي عن المدين انقضى الالتزام بمجرد هذا الهلاك، أما هلاك البديل فلا يؤثر على الالتزام الأصلي، إذ يبقى التزام المدين قائما على محله الأصلي ، ويتشابه الالتزام البدلي في هذا الحكم مع الشرط الجزائي فإذا استحال تنفيذ الالتزام الأصلي تنفيذا عينيا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، فإن الالتزام الأصلي يسقط، ويسقط معه الالتزام بالشرط الجزائي، لأن الشرط الجزائي كما مر بنا ليس إلا تقديرا إتفاقيا للتعويض، وهنا الدائن لا يستحق تعويضا وبعبارة أخرى فإنه يمكن أن يقترب الشرط الجزائي في بعض النواحي من الالتزام البدلي، لأنه ليس لكل منها سوى موضوع واحد وان هذا الموضوع يزول أو يتلاشى إذا هلك الشيء نتيجة قوة قاهرة، ولكن الفرق يبقى عند هذا الحد فقط ولا يتجاوزه إذ يختلف الشرط الجزائي عن الالتزام ألبدلي في الطبيعة بعد ذلك[36].

ويترتب على هذا الاختلاف الجوهري أن المدين لا يستطيع أن يعدل عن تنفيذ الالتزام الأصلي، إذا كان هذا الالتزام ممكنا، والحصول على الشرط الجزائي على أساس أنه بديل عنه، لسبب بسيط هو أن طبيعة الشرط الجزائي كتقدير اتفاقي

[36] سلمان بن صالح، **التعويض عن الأضرار المترتبة عن المماطلة في الديون**، بيروت، 2005، ص 39

للتعويض تختلف عن طبيعة الالتزام ألبدلي الذي لا يعتبر كذلك، فالدائن له دائما أن يطالب بتنفيذ الالتزام الأصلي تمثيلا عينيا طالما كان هذا التنفيذ ممكنا.

4. **الشرط الجزائي ليس التزاما تخييريا :** ليس هناك أي وجه للخلط بين الالتزام بالشرط الجزائي و الالتزام ألتخييري، لأن الالتزام التخييري بحسب طبيعته هو التزام يشمل محله عدة أشياء، تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحد منها، ويكون الخيار للمدين من حيث الأصل، ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك. ومعنى ذلك أن الالتزام التخييري يتميز بتعدد محل الالتزام، بحيث يتمثل المحل في شيئين أو أكثر، ولكن واحدا منها فقط هو الذي يكون واجب الأداء، و به تبرأ ذمة المدين[37].

وهكذا يبدو انه رغم تعدد محل الالتزام ألتخييري، إلا أن المدين يلتزم في العقد التزاما واحدا في جوهره، أما في حالة الالتزام بالشرط الجزائي، فإنه يكون هناك التزام أصلي، ويقوم بجانبه التزام تبعي أو احتياطي، بحيث يتسنى للدائن أن يطالب بتنفيذ هذا الالتزام التبعي، إذا لم يقم المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي أو إذا تأخر في تنفيذه. وفي الالتزام التخييري انه إذا اهلك احد الشيئين بقوة قاهرة، فإن الالتزام لا يتأثر بذلك بل يبقى دائما على موضوع واحد، ولكن الأمر على خلاف ذلك في حالة انطواء الالتزام على شرط جزائي، حيث يكون كل من الشيئين أو محلي الأداء موضوعا لالتزام مختلف، احدهما التزام أصلي بحت، والثاني التزام تابع وعرضي، يخضع وجوده لعدم تنفيذ الالتزام الأصلي، فإذا زال الالتزام الأصلي بقوة قاهرة زال الالتزام بالشرط الجزائي لأنه بطبيعته تابع له.[38]

ومن خلال تحديد الطبيعة القانونية للشرط الجزائي، وتمييزه عن ما يختلط معه من أنظمة قانونية، نستنتج أن الشرط الجزائي نظام قانوني مستقل بذاته يتميز بمجموعة من الخصائص، فالشرط الجزائي تقدير اتفاقي للتعويض وهو بهذه المثابة ذو صفة تعويضية ،ويمكن شرح هذه الصفات فيما يلي[39]:

1. **الشرط الجزائي تقدير اتفاقي للتعويض :** إن كافة القوانين تقر ذلك، فقد خول القانون للمتعاقدين حرية هذا التقدير تحقيقا للوظيفة التعويضية للشرط الجزائي، وباعتبار أن الشرط الجزائي تقدير اتفاقي للتعويض فإنه يترتب على ذلك ما يلي:
   - **المدين هو الذي يتحمل التعويض:** ذلك انه إذا أخل المدين بتنفيذ التزامه أو تأخر فيه، كان عليه أن يقوم بأداء التعويض المتفق عليه باعتبار أن هذا

[37] مصطفى محمد الجمال، **مرجع سابق**، ص 652
[38] موريس نخله، **مرجع سابق**، ص 234
[39] عبد الرزاق السنهوري، **الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق**، ص 1025

التعويض هو جزاء المسؤولية العقدية متى توافرت أركانها، وعلى ذلك فإن الشرط الجزائي كتقدير اتفاقي للتعويض، يعني اتفاق المتعاقدين على مبلغ نقدي أو أي أداء أخر، يتم تحديده جزافا وسلافا، ليكون مقابلا لجبر الضرر المتوقع حدوثه من جراء عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه الأصلي أو تأخره في تنفيذه.

- **الشرط الجزائي ليس هو مصدر التعويض:** فالشرط الجزائي بصفته تقديرا إتفاقيا على مقدار التعويض الذي يلتزم به من يخل بالتزامه الأصلي، هذا الشرط لا يتصور بداهة أن يكون هو مصدر استحقاق التعويض، ذلك أن هذا الاستحقاق له مصدر آخر، يتمثل في الإخلال بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي تم إدراج البند الجزائي في العقد لضمان تنفيذه ويترتب عن ذلك ما يلي:

إن تقدير التعويض الاتفاقي يتقيد بما يتقيد به تقدير التعويض، ولكن اتفاق المتعاقدين لا يجوز أن يخرج على قيود التعويض المقررة قانونا، لا سيما ما يتعلق منها بكيفية تقدير التعويض وحدوده، ومعنى ذلك أن التعويض يجب أن يقتصر في تحديد مقداره على ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب[40].

كذلك فان التعويض يقتصر على الأضرار المباشرة المتوقعة وحدها، دون الأضرار غير المباشرة، في حالة الالتزامات التعاقدية، إلا في حالة الغش أو الخطأ الجسيم، إما في حالة الالتزامات غير التعاقدية فان التعويض يمكن أن يشمل الأضرار غير المتوقعة.

إن تقدير التعويض الاتفاقي يتقيد بما تتقيد به كافة الاتفاقات والعقود من شروط الصحة وأسباب الانقضاء والبطلان، ومعنى ذلك إن الشرط الجزائي هو اتفاق، لذا يخضع لما تخضع له كافة الاتفاقات من شروط صحة وأسباب الانقضاء والبطلان، ولكي تتحقق الطبيعة القانونية للشرط الجزائي كتقدير اتفاقي للتعويض، فان هذا الاتفاق يجب أن يكون سابقا على الإخلال بالالتزام يستوي بعد ذلك أن يرد في ذات العقد الأصلي أو في اتفاق لاحق، ذلك أن الاتفاق اللاحق على تحقق الضرر إما أن يكون صلحا، وإما أن يكون تجديد للدين وليس شرطا جزائيا[41].

إن تقدير التعويض الاتفاقي يتقيد بتحقق شروط التعويض بوجه عام، وبالتالي التعويض الاتفاقي لا يستحق إلا إذا توافرت شروط استحقاق التعويض

---

[40] أشواق الدهيمي، **مرجع سابق**، ص 94

[41] عز الدين ألديناصوري، **ضمانات التعويض في ظل تطور مفهوم المسؤولية المدنية**، الجزائر، ص 165

السابق الإشارة إليها من خطا وضرر وعلاقة سببية و إعذار .و التقدير الاتفاقي للشرط الجزائي يستلزم أن يتم ج ا زفا، بحيث يحدد المتعاقدان مقدما، وقبل أن يقع الضرر، مقدار هذا الضرر، ومقدار التعويض الجابر لهذا الضرر.

لا يستحق التعويض الاتفاقي كما سبقت الإشارة إلا إذا تحقق الضرر وذلك إعمالا للقواعد العامة للمسؤولية، كما انه يخضع للسلطة التقديرية للقاضي في حالات معينة كما سنرى لاحقا، ولكن في رأينا كان من المفروض أن يكون التعويض الاتفاقي مستحقا حتى ولو لم يتناسب مع مقدار الضرر، وحتى وان لم يحدث ضرر عن الإخلال بالعقد سواء عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه، وهذا تمييزا للمسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية، هذه الأخيرة التي يشترط لاستحقاق التعويض فيها حدوث ضرر، و هذا هو المبدأ، ولكن لا يمكن تصور أن يكون هذا المبدأ هو نفسه في المسؤولية العقدية، ذلك انه في هذه الأخيرة وحسب اعتقادنا أن يكون المبدأ فيها تحقق الوقائع، أي حدوث الإخلال وذلك تطبيقا لقاعدة القوة الملزمة للعقد .وحث الأطراف على الالتزام به[42].

2. **<u>الالتزام بالشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي :</u>** يتسم الشرط الجزائي بكونه اتفاق تابع لاتفاق أصلي، ومن ثم فان الالتزام الذي يولده الشرط الجزائي لا يمكن أبدا أن يكون التزاما أصليا، وإنما يجب دائما أن يكون تابعا للالتزام الأصيل، الذي يتولد من العقد أو الاتفاق الأصلي. وبالتالي لا يمكن للشرط الجزائي أن يقوم وحده، وإنما هو دائما التزام تابع ويقوم مستندا للالتزام الأصلي، وهكذا تهيمن قاعدة التبعية على فكرة الالتزام بالشرط الجزائي، ويترتب على ذلك أمور أهمها أن بطلان الالتزام الأصلي يستتبعه بالضرورة بطلان الشرط الجزائي، أما بطلان الشرط الجزائي فلا يستتبعه بطلان الالتزام الأصلي، لأن انعدام التابع أو الفرع لا يؤدي إلى انعدام المتبوع أو الأصل.

ويترتب كذلك على فكرة التبعية، أن الدائن إذا اختار عند إخلال المدين بالتزامه الأصلي فسخ العقد، بدلا من المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي، سقط الالتزام الأصلي بمجرد فسخ العقد، وسقط معه الشرط الجزائي لأنه تابع له، ويطالب الدائن في هذه الحالة بالتعويضات التي يقدرها القاضي وفقا للقواعد العامة، ولا يطالب بالتعويض المقدر في الشرط الجزائي. كما يترتب على قاعدة التبعية أن الالتزام الأصلي إذا كان موصوفا أي مضافا إلى أجل، أو معلقا على شرط، فان الالتزام

[42] سليمان مقرس، **مرجع سابق**، ص 214

بالشرط الجزائي يصبح بدوره موصوفا بهذه الأوصاف فلا يستحق قبل حلول الأجل أو تحقق الشرط.

والخلاصة أن الشرط الجزائي لا يوجد مستقلا بنفسه، بل تابعا لالتزام أصلي، أيا كان مصدره، مما يترتب على ذلك الآثار المشار إليها.

الفرع الثاني : التقدير القانوني (الفائدة القانونية) و القضائي

إن التعويض كما سبقت الإشارة قد يتم تقديره باتفاق الطرفين وذلك كما يعرف بالشرط الجزائي، كما قد يتدخل المشرع وقد يقوم بتحديد قيمة هذا التعويض مسبقا، وهذا ما يسمى بالتحديد القانوني للتعويض.

أولا : التقدير القانوني للتعويض

لقد عمد المشرع إلى وضع أحكام تتعلق بتحديد التعويض تحديدا إجماليا،وعادة ما يربط الفقه هذا التحديد القانوني بالفوائد القانونية،فغالبا ما تذهب بعض التشريعات على غرار المشرع الفرنسي، إلى تحديد نسب قانونية تعرف بالفوائد القانونية تكون مستحقة الدفع عن مجرد التأخير في الوفاء، بغير حاجة إلى أن يثبت وقوع ضرر للدائن لأن الضرر مفترض في الديون النقدية نتيجة الحرمان من استثمارها اقتصاديا .ويجد التقدير القانوني للتعويض عن التأخير تطبيقه في مجال المسؤولية العقدية دون المسؤولية التقصيرية.

يمتاز التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه الذي محله أداء مبلغ من المال معين المقدار وحال الأداء، أنه لا يشترط لاستحقاقه أن يثبت الدائن أن ضررًا قد لحق به، فهو ضرر مفترض غير قابل لإثبات العكس، وهذا ما يمثل خروجًا على القواعد العامة للمسؤولية المدنية التي تستوجب وجود الضرر باعتباره أحد شروط استحقاق التعويض.

وإذا كانت القواعد العامة تقضي بأن مقدار التعويض يختلف باختلاف مقدار الخسارة أو الضرر الذي أصاب الدائن من جراء تأخر مدينه في التنفيذ أو امتناعه عنه، فإن المشرع جعل مقدار التعويض في حالة التأخر عن دفع مبلغ من النقود، ثابتًا لا يتغير، وهذا الاستثناء الثاني ليس إلا نتيجة للاستثناء الأول المتعلق بافتراض الضرر، إذ لما كان استحقاق التعويض لا يتوقف على إقامة الدليل على وجود الضرر أو وقوعه، فإن تحديد مقداره ينبغي أن يجري بمعزل عن هذا الضرر ومستقلا عنه.

فالذي يحدد مقدار هذا النوع من التعويض، أمران، هما:

- نسبة معينة من أصل الدين، تختلف حسب نوع الدين.
- طول أو قصر المدة التي يتأخر في المدين عن تنفيذ التزامه، لأن مقدار الفائدة يحسب على أساس نسبة مئوية من أصل الدين سنويا.

و التحديد القانوني لنسبة الفائدة ليس قاعدة قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها، وإنما هي قاعدة قانونية مكملة، حيث يجوز للطرفين مخالفتها والخروج عليه، ولكنه ليس خروجًا مطلقًا وإنما هو في النهاية خروج محكوم بتحديد حد أقصى للفائدة، فالنص التكميلي في حدود ما دون السقف الذي وضعه القانون كحد أقصى للفائدة، أي أنه نص آمر عند محاولة المتعاقدين تجاوز هذا السقف .إذ أن القانون أجاز الاتفاق على سعر فائدة أقل من المقرر قانونًا، ولكن لا يجوز أن يتجاوز سعر الفائدة المتفق عليه، السعر المحدد في القانون.

وإذا كانت الفائدة المتفق عليها تتجاوز الحد المسموح به قانونًا حتى وإن كانت مستترة تحت تسمية أخرى، فإنه يحق للمدين أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، وإذا تجاوزت الفائدة المتفق عليها الحد الأقصى المقرر قانونًا، فإن الاتفاق يعد باطلا فيما زاد، والبطلان سببه تعلق الحد الأقصى للفائدة بالنظام العام، ولا يترتب على الزيادة عن الحد الأقصى بطلان العقد بكامله، بل يقتصر الجزاء على إنقاص الفوائد إلى الحد الجائز قانونا وهذا ما نصت عليه المادة 227 من القانون المدني المصري، والتي جاء فيها، بأنه : " يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أي حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدًا على هذا المقدار، و كل عمولة أو منفعة أيًا كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون قد أداها ولا منفعة مشروعة."[43]

ويلاحظ أن الحد الأقصى لسعر الفائدة التي يجوز الاتفاق عليها هو سبعة في المائة، ولا يميز بين الدين المدني أو التجاري، ويختلف في حده الأعلى عن سعر الفائدة القانوني.

ومع أن التعويض المستحق في حال الفائدة القانونية غير مرتبط بالضرر وجودًا وعدمًا ومقدارًا، إلا أن المشرع المصري خرج عن هذه القاعدة وأعطى المحكمة المختصة صلاحية ربط مقدار التعويض بالضرر، في حالتين، أولهما مرتبطة بالضرر اللاحق بالمدين، والأخرى مرتبطة بالضرر اللاحق بالدائن، وهاتان الحالتان، هما:

[43] القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني المصري.

الحالة الأولى، وهي التي يتعمد فيها الدائن إطالة أمد النزاع بلا مبرر، وبقصد إطالة المدة التي يستمر فيها سريان الفائدة القانونية، وبذلك يشترط فيها أمران، هما :

- أن يطيل الدائن أمد النزاع بلا مبرر.
- أن يكون الدائن سيء النية، أي أن يكون قد تعمد إطالة أمد النزاع بقصد تراكم الفوائد.

ففي هذه الحالة أعطى المشرع للمحكمة المختصة صلاحية تخفيض الفائدة أو عدم الحكم بها عن المدة التي تعمد فيها الدائن إطالة أمد النزاع، فإذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي تخفيض الفائدة قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقًا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر، وينطلق هذا الحكم من كون أن إطالة أمد النزاع بلا مبرر يعد تعسفًا في استعمال الحق.[44]

الحالة الثانية، وهي التي يتعمد فيها المدين التأخر في الوفاء بدينه بقصد الإضرار بالدائن، لذلك أعطى المشرع المصري المحكمة المختصة صلاحية الحكم بتعويض إضافي للدائن إذا جاوز الضرر اللاحق به الفائدة القانونية.[45]

وقد اختلف الفقه حول أساس التعويض في هذه القوانين، بمعنى هل هو تعويض يقوم على أساس المسؤولية المدنية أم هو نظام قائم بذاته يخرج عن نطاق أحكام هاته المسؤولية. وقد توصل الفقه إلى اعتبار أن التعويض في هاذين القانونين هو نظام قائم بذاته، بمعنى لا يقوم على أساس المسؤولية المدنية، وبالتالي لا يدخل في نطاق دراستنا.

غير أنه ورد في القانون تقدير التعويض في مجال المسؤولية العقدية، وهذا من خلال التحديد القانوني لهذه المسؤولية، ويتم تقدير التعويض في هذه الحالة في الحدود الموضوعة من طرف المشرع، إذ قد يقوم في حالات معينة بوضع حد أقصى لا يمكن أن يتجاوزه التعويض الذي يستحقه المتضرر، ولو كان الضرر الذي أصابه يفوق المبلغ المحدد.

وتقدير التعويض من خلال التحديد القانوني للمسؤولية يختلف عن التقدير الجزافي للتعويض في أنه لا يستحق بطريقة تلقائية دون اعتبار للضرر الحقيقي اللاحق بالمتضرر، وإنما هو بمثابة حد أقصى لما يدفعه المسؤول من تعويض، بحيث إذا ثبت أن قيمة الضرر أدنى من هذا الحد، فلا يستحق المضرور إلا التعويض المساوي لهذه القيمة، دون أن يكون

---

[44] عبد الرزاق أحمد السنهوري، **الوسيط في شرح القانون المدني الجديد .(2) نظرية الالتزام بوجه عام -آثار الالتزام، مرجع سابق**، ص915

[45] فقد جاء في قرار **محكمة النقض المصرية رقم (1101-30 تاريخ 1969/07/03)** بأنه : " لا يكفي لإعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 من القانون المدني وقوع خطأ من الدائن في مسلكه في الدفاع في الخصومة ولو كان هذا الخطأ جسيمًا، بل لابد من ثبوت سوء نيته وتعمده الإضرار بالمدين حتى يتراكم عليه الفائدة، ومن ثم فإن مجرد إبداء الدائن يخفق في إثباته لا يدل بذاته على أنه سيء النية في إطالة أمد التقاضي بل لابد بذلك من أن يثبت أن هذا الدفاع كيدي وأن القصد من تقديمه إطالة أمد التقاضي إضرارًا بالمدين "

له الحق في الحصول على الحد الأقصى للتعويض المقرر قانونا، فيشترط للحصول على هذا الحد أن يكون الضرر مساويا له أو أكبر، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن أنظمة التعويض التلقائية لا تقوم على المسؤولية المدنية كما بيناه، ولا يقع على عاتق المتضرر إثبات أركانها، وإنما بمجرد ما يتبين أنه قد لحقه ضرر ترتب تعويضه، بينما فيما يتعلق بالتعويض وفقا للتحديد القانوني للمسؤولية فإنه لا يتأتى للمطالب به إلا بعد أن تقوم المسؤولية وتتحقق أركانها وهذا بغض النظر عن أساسها إن كانت مسؤولية موضوعية أو مسؤولية تقوم على أساس الخطأ بحسب أنواعه.

كما أن المشرع حدد في التعويض الجزافي قواعد يمكن معها الحصول على التعويض بصفة دقيقة، في حين أنه في التعويض وفقا للتحديد القانوني للمسؤولية مادام أن الضرر لم يصل إلى درجة الحد الأقصى للتعويض المحدد فإن القاضي هو الذي يقدر التعويض وفقا للقواعد العامة.

ثانيا : التقدير القضائي للتعويض

إن التعويض كما سبق بيانه تقدر قيمته إما من قبل الأطراف المتعاقدة ضمن بنود العقد أو في اتفاق لاحق كشرط جزائي عن الإخلال بالعقد، أو يتم تحديده من طرف القانون بحد أدنى أو أقصى، لكن بالرغم من التقدير المسبق للتعويض إلا أن القاضي يملك أيضا سلطة تقديرية في تحديد قيمة التعويض، وهذا ما يسمى بالتقدير القضائي للتعويض.

فالتعويض القضائي هو التعويض الذي يقوم القاضي بتقديره ويحكم به للدائن نتيجة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه، ويعتبر التعويض القضائي هو الأصل في تحديد التعويض.

الأصل في التعويض هو التعويض الكامل وهو ذلك الذي يكون على خطأ المدين المباشر والذي يسبب ضررا للمدين سواء كان هذا الضرر متوقعا أو غير متوقع وهذا ما سبق شرحه، غير أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء يتمثل في حالة الضرر المتوقع في مجال المسئولية العقدية إذا كان الخطأ يسير أي غير ناتج عن غش وخطأ المدين الجسيم وهذا ما يسمى بالتعويض العادل.

كما تثور هنا إشكالية تتمثل في هل سلطة القاضي مطلقة في تحديد قيمة التعويض في المسؤولية العقدية؟

التعويض كجزاء مدني يهدف إلى إصلاح الضرر الناشئ عن الإخلال بالت ا زم سواء أكان مصدره العقد أو القانون، وبعبارة أخرى سواء كانت المسؤولية عقدية أم تقصيرية، ولا تتحقق تلك الغاية إلا إذا كان التعويض كاملا، وأصبح نتيجة لذلك أن استقر مبدأ

التعويض الكامل للضرر، واعتبر من المبادئ الحيوية التي استقر عليها القضاء و الفقه. كما أن هناك مبدأ أخر يخفف في حدت المبدأ المتقدم، وهو مبدأ السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ويعد هاذين المبدأين متكاملين من الناحية العملية والنظرية.

القاعدة في التعويض هي التعويض الكامل الذي يكون عن الضرر المباشر، أما الضرر الغير مباشر فإنه لا يعوض عنه سواء في المسؤولية العقدية أو التقصيرية،غير أنه في المسؤولية التقصيرية يتم التعويض عن كل الضرر مباشر يستوي في ذلك أن يكون متوقعا أو غير متوقع، أما في حالة المسؤولية العقدية فإنه لا يتم التعويض إلا عن الضرر المباشر المتوقع وحده، خلاف الضرر المباشر الغير متوقع فلا يعوض عنه إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم.

وقد اعتبر المشرع أن الضرر يكون مباشرا متى ما كان نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أو التأخر فيه ويكون الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. و بم ا رعاة هذه الشروط المحددة في هذه المادة نكون بصدد التعويض الكامل، هذا الأخير الذي يشمل عنصرين وهما ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة.

فالقاضي ملزم في حالة التعويض القضائي بمنح المتضرر التعويض الكامل، وهو التعويض عن الضرر المباشر الذي يمثل ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب فضلا عن الضرر الأدبي.

لكن إذا كانت القاعدة هي التعويض الكامل إلا أن القضاء لا يتقيد بها في حالة الضرر المتوقع في مجال المسؤولية العقدية إذا كان الخطأ يسيرا فهنا نتحول إلى نطاق التعويض العادل.

و إذا كان مبدأ التعويض الكامل قد وجد له تطبيقا واسع النطاق، فإنه اخذ ينحصر في الوقت الحاضر ولم يعد الشكل الضروري لجبر الضرر، بل إن التعويض في ذاته لم يعد معياره الوحيد مدى الضرر الحاصل للدائن وإنما قد يرتبط تقديره باعتبارات اجتماعية أو متعلقة بالعدالة.

لذا نجد بعض التشريعات الحديثة قد أخذت تتجه إلى عدالة التعويض، وليس بالضرورة أن يكون كاملا، وسنجد أيضا عند البحث في القيود التي ترد على سلطة القاضي في تقدير التعويض أن مقتضيات العدالة توجب على القاضي تخفيض مقدار التعويض عن المقدار الذي كان من المفروض أن يحكم به، فإزاء هذا التحول من مبدأ التعويض الكامل إلى التعويض العادل ويجعله هو الأصل في التعويض، وخاصة في المسؤولية العقدية في حالة الضرر المتوقع إذا كان الخطأ يسيرا لا في حالة الغش أو الخطأ الجسيم، حيث هنا وفي هذه

الحالة تستند المسؤولية إلى فكرة الذنب و اللوم الأدبي، ويستبدل التعويض العادل بالتعويض الكامل، وبذلك يكون التعويض قد جمع بين الوظيفة الإصلاحية والوظيفة الرادعة.

وقد حاول الفقهاء تحديد أساس التزام المدين أو مبرر التزامه بتعويض الضرر المتوقع في حالة الخطأ اليسير، فذهب البعض إلى أن مبرر ذلك يكمن في احترام حسن نية المدين، وما يقتضيه ذلك من توزيع الخسائر بين الدائن والمدين، لان عدم تنفيذ الالتزام لا يعني بالضرورة توافر سوء النية في جانب المدين، فربما يستحيل عليه التنفيذ أو يتأخر فيه لسبب أجنبي لا يستطيع إثباته، فيكون من الأصح معاملته كما لو كان حسن النية، وعدم إلزامه بغير تعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

وذهب البعض الآخر إلى أن مبرر التعويض غير الكامل يكمن في أن المسئولية العقدية تقوم على التوقع، لذا فان المدين لا يجب إلزامه بتعويض أضررا لم يتوقعها وقت التعاقد، فمزايا العقد ومضاره يجب أن تدور في فلك هذا التوقع.

ويذهب البعض إلى أن التزام المدين بتعويض الضرر المتوقع وفي حالة الخطأ اليسير في نطاق المسئولية العقدية، لا يستند إلى الإرادة التعاقدية الضمنية أو المفترضة، بل إلى فكرة عدالة التعويض، فالدائن الذي يرتبط مع مدينه بالعقد إنما يسعى وراء التنفيذ العيني لا وراء التعويض، لما سيجنيه من تنفيذ العقد من مصالح ومنافع دفعته إلى التعاقد ، وكذلك المدين فهو لم يتعهد بالالتزام إلا لما تبينه في نفسه من القدرة على تنفيذ ما تعهد به، والرغبة في التنفيذ لتحقيق المصلحة التي يرمي إليها هو الأخر من وراء التعاقد، ولتجنب الحكم عليه بالتعويض .وليس هذا غريبا على المشرع الذي منح المتعاقدين القدرة على التعويض وذلك بالتقدير الاتفاقي له، أي من خلال الشرط الجزائي.

و مما لا شك فيه أن منح قاضي الموضوع سلطة تقديرية في حسم الدعاوى يعد من الأمور المسلم بها وخاصة في الوقت الحاضر ونتيجة لتعدد القضايا وتعقد الحياة وزحمة العمل القضائي اليومي، فمنح القاضي تلك السلطة خير وسيلة لتمكينه من حسم اكبر عدد من القضايا وخاصة التي تتعلق بالتعويض.

وإذا قيل أن تحكم القضاة يؤدي إلى بعض المخاطر كالحكم بتعويضات متفاوتة تفاوتا كبيرا في قضايا وحالات متشابهة ظاهريا، فإن علاج تلك المخاطر لا تكون بتحويل هؤلاء القضاة إلى مجرد آلة لتطبيق النصوص القانونية.

غير أن السلطة الممنوحة للقاضي في تقدير التعويض ليست سلطة مطلقة، بل أنها مقيدة بمجموعة من القيود التي يجب على القاضي مراعاتها عند إصدار حكمه بالتعويض،منها ما يتعلق بطلبات الخصوم، ومنها ما يتعلق بالتعويض المحدد قانونا، وكذا حالة الخطأ المشترك، والتقدير الاتفاقي للتعويض :

- **طلبات الخصوم:** لما كان القاضي ملزما في البت في كل طلب أو دفع قدم بصورة صحيحة فانه يكون قد ارتكب خطأ جوهريا في الحكم في ما لو قضى بما لم يدع به الخصوم، أو قضى بأكثر بما طلبوه و يعد ذلك مبررا للطعن فيه.

و لعل التبرير المنطقي لضرورة تقيد محكمة الموضوع بطلبات الخصوم يجد أساسه في أن ما يطلبه الخصم هو تعبير عن إرادته و على القاضي أن يحترم تلك الإرادة، لذا نجد في بعض الأحيان أن يحصل اتفاق بين الدائن و المدين على مقدار التعويض المستحق، فيما لو أخل المدين بتنفيذ التزامه (شرط جزائي) ففي هذه الحالة لو وصل الأمر للقضاء على القاضي أن يراعي قيمة الشرط الجزائي و لا يحكم بأكثر منه.

فوظيفة القضاء محددة بالفصل فيما يعرض عليه من طلبات فلا يملك ولاية التدخل في أمور لم تعرض عليه، و لا يملك أيضا الإجابة عن أمور لم يسأل فيما خارج نطاق القضايا المعروضة عليه لذا لو قررت المحكمة الحكم بشيء لم يطلبه الخصم، فان ذلك يعد مبررا للطعن به لأن الأصل في الحكم سبق الطلب فما لم يطلبه الخصم بعريضة دعواه لا يعتبر جزاء منها، و الحكم فيها يعد تجاوزا على معنى الدعوى و الخصومة.

من كل ما تقدم ، يتبين لنا أن طلبات الخصوم تعد قيدا على سلطة القاضي في تقدير التعويض فيجب على القاضي أن يتقيد بما يقدم له في عريضة الدعوى و لا يجوز له أن يتجاوز وإلا كان حكمه عرضة للنقض.

وهذا ما ذهب إليه المشرع المغربي من خلال نص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية : **" يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات و يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة."** [46]

[46] الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.

- **التعويض المحدد قانونا:** إذا كان الأصل أن القانون لا يتدخل في تقدير التعويض، إلا في بعض الحالات و منها الإخلال بتنفيذ التزام محله أداء مبلغ من النقود، فيتولى القانون بنفسه تقدير التعويض إلا أن الحالة المقصودة فيما يتعلق بالتحديد القانوني للتعويض، هي ليست حالة إخلال المدين بتنفيذ التزام محله أداء مبلغ من النقود، بل حالات أخرى ترد في نصوص متفرقة و تكاد تكون خارج نطاق القانون المدني.

و بناء على اعتبارات معينة يتدخل المشرع، و ينص على طريقة معينة للتعويض أو يبين الحدود التي يجب مراعاتها عند تقدير التعويض، كما هو الحال فيما ورد في قوانين العمل و النقل و بعض الاتفاقيات الدولية، فمتى ما أورد المشرع تحديد لمقادير التعويض وجب على القاضي مراعاة ذلك التحديد الذي يعد مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

- **حالة الخطأ المشترك :** المقصود بالخطأ المشترك هو أن يشترك خطأ الدائن إلى جانب خطأ المدين في إحداث الضرر فيكون للضرر سببان خطأ الدائن و خطأ المدين، و فيه لا يتحمل المدين المسؤولية الكاملة بل بقدر ما صدر عنه من خطأ؛أي تكون مسؤوليته مخففة و على القاضي أن يراعي تلك الحالة و يأخذها بعين الاعتبار، وهي من هذا المنطلق تعد قيدا على سلطة القاضي في تقدير التعويض و خاصة بالنسبة للتشريعات التي توجب على القاضي إنقاص التعويض أو ألا يحكم بأي تعويض إذا كان الدائن قد اشترك مع المدين في إحداث الضرر، لأننا لو رجعنا إلى النصوص التشريعية التي نظمت الأحكام الخاصة بالخطأ المشترك لوجدناها قد تباينت في مدى إل ا زم القاضي بإنقاص التعويض من عدمه.

وإنقاص التعويض أو عدم الحكم به من طرف القاضي في حالة الخطأ المشترك يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ عدالة التعويض، فلا يجوز أن يكون التعويض مصدر إثراء للدائن على حساب المدين، فمن العدل أن يتحمل الدائن جزءا من الضرر إذا كان قد اشترك مع المدين في إحداثه.

وإذا كان الخطأ مشتركا بان صدر من المدين خطأ إلى جانب خطأ الدائن فان ذلك لا يكون مقتصرا على الخطأ الذي يصدر عنه شخصيا بل يشمل الخطأ الذي يصدر من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه فيتحمل المسؤولية ولو مخففة، مع ملاحظة أنه في المسؤولية العقدية يجوز للمدين أن يتفق مع الدائن على عدم مسؤوليته عن الخطأ الذي يصدر من أولئك الأشخاص الذين استعان بهم أو استخدمهم في تنفيذ التزامه.

- **التقدير الاتفاقي للتعويض:** إن التقدير المسبق للتعويض المتفق عليه بين أطراف العقد يعتبر قيدا على سلطة القاضي في تحديد التعويض، ذلك انه لا يمكنه الحكم بغير ما تم الاتفاق عليه على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، غير أن هذه القاعدة غير مطلقة. ففي التعويض الاتفاقي تمثل سلطة القاضي ضرورة لمواجهة كل التعسفات التي قد يتسبب التعويض الاتفاقي فيها، فمبادئ العدالة تأبى أن يتحول التعويض الاتفاقي إلى أداة للاستغلال، أو منفذا من منافذ الربا، أو أن يتحول إلى عالم من عوالم الظلم، فيتوفر من خلال سلطة القاضي الضمان الكافي ليؤدي التعويض الاتفاقي مهمته فيكون على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر، وللتعرف على حدود سلطة القاضي اتجاه الشرط الجزائي فإننا نتطرق للأساس القانوني لهذه السلطة في تعديل قيمة التعويض الاتفاقي، ثم مضمون سلطة القاضي حيال التعويض الاتفاقي.

المطلب الثاني : الضرر الواجب التعويض عند تأخر المدين في تنفيذ التزامه

لم يختلف الفقهاء حول أنواع الضرر في المسؤولية المدنية، فكان تقسيمهم للضرر إلى ثلاث أنواع، ضرر جسدي يصيب الدائن في جسمه، **وضرر مالي** يصيب الذمة المالية للمدين، و**ضرر معنوي** يصيبه في أحاسيسه ومشاعره، وفي نطاق المسؤولية العقدية، فان النوع الأول من الأضرار (الضرر الجسدي) يعتبر نادر الحدوث إلا في حالات قليلة، ويمكن تصوره في العقود العلاجية بين المريض والطبيب، لذلك لن نتعرض لهذا النوع من الضرر، ونكتفي في هذا المجال بالإشارة للضرر المادي (المالي) في **(الفرع الأول)**، والضرر المعنوي نظرا لما اعترض هذا الأخير من حدة في النقاش فيما يخص وجوب التعويض عن الضرر المعنوي من عدمه في **(الفرع الثاني)**

الفرع الأول : التعويض عن الضرر المادي

ذهب الفقه و القضاء في البداية إلى أن الضرر الذي يمكن أن يطالب الدائن بتعويضه يكون في الغالب العم ماديا، **وهو الضرر الذي يمس الذمة المالية للدائن**، والذي يشمل أيضا ضياع الفرصة أو الخدمة التي كان ينتظرها. وبحسب الفصل 264 من قانون

الالتزامات و العقود المقابل للمادة 1149 من القانون المدني الفرنسي[47]، فان الضرر لا يقتصر فقط على الخسارة الحاصلة، وإنما أيضا من أجل الربح الضائع نتيجة عدم تنفيذ الالتزام.

زيادة على الضرر المادي بمفهومه الضيق الذي يقتصر على ذلك الضرر الذي يصيب الشخص في ذمته المالية، فان الضرر المادي قد يتسع ليشمل أيضا ما يسمى بالضرر الجسدي، الذي يقصد به ذلك الضرر الذي يصيب الشخص في جسمه، من قبيل التشوهات التي تنتج عن إجراء عملية تجميلية فاشلة من قبيل الطبيب تجاه زبونه المرتبط معه بمقتضى عقد طبي.[48]

يوصف الضرر بأنه مادي متى ما أصاب حقا ماليا للدائن، وليس ضررا ماديا محسوسا، وقد ارتأينا تسمية هذا النوع من الضرر بالضرر المالي، لأنها تسمية أكثر دقة من تسمية الضرر المادي، فهذا الأخير قد ينصرف معناه إلى أن الضرر محسوس له مظهر مادي خارجي، بينما تسميته بالضرر المالي لا يحمل معنى سوى انه يصيب الشخص من الناحية المالية أي انه يصيب الجانب المالي من ذمة الشخص.

ويحدد الضرر المالي بناء على الخسارة التي لحقت المتعاقد وما فاته من كسب بسبب إخلال المتعاقد بالتزامه التعاقدي كما سبق بيانه. و مثاله الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق، واعتداء على حقوقه المالية أو المساس بسلامة جسمه و عقله[49]، و هو ما عبر عنه الفصل 98 من قانون الالتزامات و العقود المغربي بأنه : **"الخسارة التي لحقت المدعي فعلا، والمصروفات الضرورية أو التي سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرارا به، وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل".**

وللضرر المالي شروط معينة يلزم توافرها حتى يكون قابلا للتعويض عنه، منها أن يكون مباشرا ومحققا (حالا ومستقبلا)، وان يصيب حقا أو مصلحة مالية مشروعة للمتضرر، وان يكون شخصيا ولم يسبق تعويضه، بالإضافة إلى شرط الاعذار المسبق وعدم الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية كما سيتم بيانه.

---

[47] Article n° 1149 Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 : « Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible.
La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.
Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession. »

[48] عبد الرحمان الشرقاوي، **القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، مصادر الالتزام**، الجزء الأول، التصرف القانونين العقد، و الإرادة المنفردة، الطبعة السادسة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2019، ص333

[49] مرزوق ايت الحاج، **مرجع سابق**، ص 162

- **أن يكون الضرر محققا :** ومعنى ذلك أن الضرر يجب أن يكون قد وقع فعلا كموت المصاب أو جرحه أو إتلاف ماله أو حدوث تشويه في جسمه، أما الضرر المحتمل أي الذي لم يقع عد ولكن ينتظر حدوثه فلا تقوم المسؤولية عنه طالما أنه لم يقع، فان قع جاز للمتضرر أن يطالب حينئذ بالتعويض عنه وذك كأن يصاب شخص إصابة تعرض حياته للموت ففي هذه الحالة لا تسوغ المطالبة بالتعويض عن الوفاة باعتبار أن الشخص سيموت، ولكنه إن مات أصبح الضرر محقا و جازت المطالبة بالتعويض عن الوفاة.

ويترتب على أن المسؤولية لا تقوم إلا على الضرر المحق دون الضرر المحتمل وجوب أن يكون الضرر حالا أي وقع بالفعل.

و يعتبر الضرر من قبيل الضرر المحق، الضرر المؤكد الوقوع استقبالا كإصابة الشخص إصابة تعطله عن العمل في الحال و يكون من المؤكد فضلا عن ذلك أنها ستؤثر على عمله في المستقبل.

ولذلك يجب التمييز بين الضرر المستقبل و الضرر المحتمل وعدم الخلط بينهما، فالضرر المستقبل محق الوقوع لذلك يجب التعويض عنه، أم الضرر المحتمل فهو غير محق الوقوع قد يقع و قد لا يقع ولذلك لا يصح التعويض عنه حتى يقع فعلا.[50]

- **أن يصيب الضرر حقا أو مصلحة مالية مشروعة :** لا تجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر إلا إذا أصاب الضرر حقا للمضرور كالاعتداء على حياة شخص أو جسمه أو ماله، و سواء كان هذا الحق ماديا أو معنويا كالاعتداء على مال الشخص أو من عرضه أو شرفه.

إلا أن الضرر قد يصيب شخصا أخر عن المضرور، فالقتل مثلا يحدث ضررا لمقتول إذ يحرمه من الحياة كما يحدث ضررا غيره، فإذا كان المقتول يعول شخص لا تجب عليه نقته إلا أن فرصة استثمار النفقة عليه محققة استقبالا فان الضرر يتحقق بالنسبة لهذا الغير و يحق له لمطالبة بالتعويض، لأن الضرر أصاب مصلحة مالية للمتضرر غير أنه يجب أن تكون هذه المصلحة مشروعة و إلا فلا يحوز الحكم بالتعويض، و لذلك لا يجوز للخليلة التي توفي خليلها نتيجة خطأ الغير أن تطالب بالتعويض عن الضرر الحاصل لها نتيجة هذه الوفاة.[51]

- **الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض (إعذار المدين) :** الاعذار عمل ايجابي يصدر من الدائن ويعبر فيه عن رغبته بضرورة قيام المدين بتنفيذ التزامه وإلا كان

---

[50] عبد الرزاق السنهوري، **مرجع سابق**، ص 974 و 975

[51] عبد الحق صافي، **الوجيز في القانون المدني، الجزء الأول، المصادر الإرادية للالتزام (العقد و الإرادة المنفردة) دراسة في ق.ل.ع و في القوانين الأخرى**، الطبعة الأولى 2020، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 162.

مسؤولا عن ذلك، ويتخذ هذا العمل شكلا يبينه القانون. فالإعذار كقاعدة عامة شرط لقيام المسؤولية وللمطالبة بالتعويض، وهذا يعني أنه لا إلزام على المدين في دفع التعويض إلى الدائن المتضرر،ما لم يقم الأخير بإعذار الأول بالوفاء بما ترتب في ذمته من تعويض نجم عن تحقق مسؤوليته العقدية، والغرض من هذا الإجراء هو انتفاء شبهة الدائن بتأخير الوفاء، وشبهة إقراره الضمني بعدم حصول ضرر له من ذلك التأخير. وقد جاء النص على الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية في جل التشريعات العربية نذكر على سبيل المثال ما جاء في المادة 281 من القانون المدني المصري : "لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك".

الفرع الثاني : التعويض عن الضرر المعنوي

بالرغم من أن الدائن لا يطالب بالتعويض عن الضرر المعنوي إلا في حالات قليلة مقارنة بالضرر المادي، فان إشكالية التعويض عن الضرر المعنوي لقيت نقاشا حادا على مستوى الفقه و القضاء. وحقيقة إن هذه الإشكالية أثيرت أساسا بخصوص المسؤولية التقصيرية، غير أن التجربة أظهرت بأنها تطرح أيضا بخصوص عدم تنفيذ العقود.

فإذا كان القضاء قد ساوى بين حالة الضرر المادي و المعنوي حينما يتعلق الأمر بالتعويض في مجال المسؤولية التقصيرية، فانه ظهر، على الأقل من الناحية المبدئية، بأنه أقل جرأة في المجال العقدي، حيث توجه في البداية إلى أنه لا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار إلا الضرر المادي من أجل تحديد التعويض.

غير أن القضاء فيما بعد، تطور في اتجاه لبرالي وأصبح يأخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي في تحديد التعويض المحدد في مجال المسؤولية العقدية. كما أن النصوص القانونية لم تضع أية تفرقة، فمضمون المادة 1148 من القانون المدني الفرنسي[52] متسع لاستيعاب الأضرار المعنوية على غرار الأضرار المادية.

والمقصود بالضرر المعنوي هو الأذى أو التعدي الذي يصيب الحق أو المصلحة المشروعة للشخص، فيسبب ألما معنويا للمتضرر، ويعتبر من قبيل الضرر المعنوي كل ما يمس شرف الشخص أو سمعته أو ك ا رمته أو حريته أو شعوره أو عاطفته أو مكانته الاجتماعية.

[52] Article **1148** Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 : « Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales. »

فقد يتمثل الضرر في مصلحة غير مالية للمضرور، كالآلام الجسمية التي يعانيها من جراء الإصابات الجسمانية، و الآلام النفسية الناتجة عن وجود عاهة أو تشوهات خلقية، أو الآلام العاطفية الناشئة عن شعوره بدنو اجله وقلقه على مصير أفراد أسرته، وكذلك يعد من قبيل الأضرار الأدبية ما يعانيه المضرور من آلام عاطفية بسبب الإصابة التي لحقت به أو بسبب فقدان شخص عزيز عليه و الآلام النفسية التي تلحق به بسبب قلقه على مصي ره بعد فقدان عائله.

هذا وإذا اجتمع الفقه على جواز تعويض الضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية، فقد وقع خلاف كبير بينهم حول تطبيق نفس القاعدة في المسؤولية العقدية نظرا لإيمان اتجاه كبير من الفقه بفكرة ازدواج المسؤولية المدنية. وقد استند أصحاب هذا الاتجاه إلى بعض الحجج، نذكر منها أن العقد يرد في دائرة تبادل المنافع المادية، ولا يرد إلا على شيء ذا قيمة مادية، وبالتالي لا يمكن أن يكون محلا لالتزام مصلحة أدبية، وان الضرر المعنوي ليس خسارة مادية حتى يتم تعويضه.

غير أنه تم الرد على هذه الحجج على أساس أن المصلحة الأدبية قد ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصلحة المادية، حتى لو كان للمتعاقد مصلحة معنوية في تنفيذ العقد، وبما أن التعويض عن الضرر الأدبي جائز في المسؤولية التقصيرية، فلماذا يحصر في هذا المجال ولا يمتد إلى المسؤولية العقدية انطلاقا من مبدأ وحدة المسؤولية المدنية.

وفي رأينا لا يوجد سبب يمنع من تعويض الضرر المعنوي في المسؤولية العقدية طالما انه ممكن الوقوع، حتى ولو كان هذا الوقوع نادر، ذلك انه بالرجوع إلى غاية التعويض التي هي جبر الضرر، فكيف نقول انه تم الحكم بتعويض شامل للضرر في حين أن الضرر المعنوي لم يشمله التعويض.

ختاما للفصل الأول من هذا البحث يمكن القول أنه و بعد تعريف التعويض و تمييزه عن النظم المشابهة، وكذا بيان عناصره و أنواعهّ إضافة إلى شروط استحقاقه و كيفية تقديره، يمكن القول بان التعويض حق للدائن والتزام للمدين؛ يثبتان في ذمتهما عند الإخلال بالالتزام، ويكون إما نقدي وإما في شكل ترضية أخرى مساوية للمنفعة التي كان سينالها الدائن لو لم يتم الإخلال بالالتزام. و كيفما كان الضرر ماديا أو معنويا، فانه يستوجب التعويض عنه متى توفرت شروط استحقاقه، و للأطراف أو القانون أو القضاء -حسب الحالات- تقديره مراعاة في ذلك مجموعة من الضوابط القانونية المحددة في ك تشريع على حدة.

وتبقى الإشكالية المطروحة في الجزء الثاني من هذا البحث (الفصل الثاني) متعلقة بمدى تطبيق هذه القواعد العامة خلال الظروف الخاصة (حالات الضرورة).

فمنذ نهاية 2020 و آلاف الأشخاص في العالم يعيشون حالة من الرعب و الخوف على حياتهم و حياة أسرهم بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، و الذي امتد إلى العلاقات التعاقدية و أحدث ارتباكا في مفهوم سلطان الإرادة و ما يترتب عنه من نتائج و التي تعد القوة الملزمة للعقد أهمها.

و هو ما يفرض مجموعة من التساؤلات حول الموضوع، سنحاول الإجابة عنها بتفصيل دقيق في الفصل الثاني من هذا الموضوع. **فما مصير الالتزامات التعاقدية التي صاد تنفيذها مرور المغرب بجائحة زمنية مفاجئة ؟ وفي حالة تكييف جائحة كورونا على أنها قوة قاهرة، هل يمكن الحديث عن تأخير تنفيذ الالتزامات التعاقدية؟**

الفصل الثاني :

تأثير جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية

المبحث الأول : الجائحة و أثرها على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

تنبني فكرة العقد شريعة المتعاقدين، و التي نظمها المشرع المغربي –على غرار نظيره الفرنسي- في الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود على أسس ثلاثة :

أول هذه الأسس ذو طابع قانوني، يتمثل في احترام مبدأ سلطان الإرادة، باعتباره الركيزة الأساسية لمختلف التصرفات القانونية عموما.

وثانيها ذو طابع أخلاقي و ديني، يتمثل في احترام العهود و المواثيق.

أما ثالثها ذو طابع اجتماعي و اقتصادي، يترجمه وجوب استقرار المعاملات الذي يتحتم أن يسود في كل مجتمع راقي و منظم.

ووجوب احترام مضمون العقد، سواء من جانب أطرافه أو من جانب القضاء، هو ما يعبر عنه في الاصطلاح عادة بالقوة الملزمة للعقد.

و إن الدراسة التي نعتزم تقديمها من خلال هذا المبحث، تنطلق من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و من فكرة القوة الملزمة للعقد، ذلك أن الظروف الطارئة و القوة القاهرة تعفي المتعاقد من تنفيذ التزامه التعاقدي، و هي بالتبعية تحجب مسؤوليته العقدية.

المطلب الأول : نظرية الظروف الطارئة

نظرية الظروف الطارئة تؤثر في القوة الملزمة للعقد فقط، لأنها تفرض – من ضمن ما تفرضه – إعادة النظر في الالتزام المترتب عنه، بكيفية ترفع عن المدين جانبا من الصعوبة التي تعترضه. و به ستنصب دراستنا عن مختلف الوسائل التي تبنتها مبادئ القانون من أجل حماية المدينين الذين أصبحوا مهددين بالإفلاس أو على الأقل المدينين الذين أصيبت ذممهم المالية بتصدع خطير في هذه الحالة، وفي الأحوال المماثلة الأخرى.

الفرع الأول : مفهوم نظرية الظروف الطارئة

إن نظرية الظروف الطارئة تجعل الالتزام التعاقدي صعب التنفيذ بالنسبة إلى الطرف المدين في هذا الالتزام. و هاته النظرية في حقيقة أمرها تطبيق لمبدأ شرعي عام مفاده أن "لا تكليف بمستحيل"[53] ، أو لا تكليف بما يتجاوز طاقة الإنسان العادية.

و من البديهيات في الوقت الراهن أن "المسؤولية العقدية تقوم على الإخلال بالتزام قانوني لا يتغير، هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير."[54]

---

[53] « A l'impossible, personne n'est du »

[54] عبد الرزاق السنهوري، **مرجع سابق**، ص 847.

من الصعب جدا وضع تعريف جامع لنظرية الظروف الطارئة لتغيير الوقائع المرتبطة بها من نزاع لآخر من جهة أولى، و لتنوع الآثار التي من الممكن أن تترتب عنها على مستوى مختلف القوانين المقارنة من جهة أخرى.

و يقول الأستاذ السنهوري في مؤلفه الوسيط في شرح القانون المدني أن نظرية الظروف الطارئة تفترض الوضع الآتي بيانه :

" عقد يتراخى وقت تنفيذه إلى أجل أو آجال، كعقد التوريد، و يحل أجل التنفيذ، فإذا الظروف الاقتصادية التي كان توازن العقد يقوم علها وقت تكوينه تغيرت تغيرا فجائيا لحادث لم يكن في الحسبان، فيختل التوازن الاقتصاد لعقد اختلالا خطيرا. وليكن الحادث خروج السلعة التي تعهد المدين بتوريدها من التسعيرة يرتفع سعرها ارتفاعا فاحشا بحيث يصح تنفيذ المدين لعقد التوريد يتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسائر التجار. فهل يؤخذ المدين في هذه الحالة تنفيذ التزامه مهما بلغت الخسارة؟"[55]

و يزيد الأستاذ السنهوري توضيحا، فيقول :

"لو أن هذا الحادث الطارئ قد جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، لكان قوة قاهرة ينقضي بها الالتزام، أو لو أنه لم يكن من شأنه إلا أن يجعل تنفيذ الالتزام يعود بخسارة على التاجر لا تخرج عن الحد المألوف في التجارة، ما كان له من أثر، فالتاجر يكس و يخسر، وكل من الكسب و الخسارة شيء متوقع، و لالتزام المدين بتنفيذ التزامه كاملا. و لكنا نفرض فيما قدمناه أن تنفيذ الالتزام لم يصبح مستحيلان ومن جهة أخرى صار مرهقا يهدد التاجر بخسارة تخرج عن الحد المـألوف، ثم إننا نفترض أن هذا كله لم يكن قائما وقت نشوء العقد، بل وجد عند تنفيذه فماذا يكون الحكم؟ تقول نظرية الظروف الطارئة أنه لا ينقضي التزام المدين لأن الحادث الطارئ ليس قوة قاهرة، ولا يبقى التزامه كما هو لأنه مرهق، ولكن يرد الالتزام إلى الحد المعول حتى يطيق المدين تنفيذه، يطيقه بمشقة ولكن في غير إرهاق..."

و انطلاقا من هذا التوضيح، نقول إن نظرية الظروف الطارئة تتمل في تواجد المتعاقد المدين في ظروف اقتصادية غالبا جد صعبة، تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي من طرفه لا يتم إلا مقابل خسارة جد فادحة، لا يمكن رفعها عنه إلا بمراجعة هذا الالتزام من طرف السلطة القضائية.

ومنه فان نظرية الظروف الطارئة ترمي من ضمن ما ترمي إليه إلى الوقوف إلى جانب المدين في التزام عقدي في ظروف تهدده بخسارة فاضحة، و هذه مسألة جد طبيعية ما دامت هذه النظرية ذات أصل ديني و أخلاقي قبل أن تكون عبارة عن مجرد قاعدة قانونية.[56] وهو ما يعني أن هذه النظرية د وضعت أساسا هد الوقوف إلى جانب المدينين السيئي الحظ في أحوال معينة.

---

[55] عبد الرزاق السنهوري، **مرجع سابق**، ص 705

[56] محمد الكشبور، **نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة**، الطبعة الأولى 1993 ص 106

غير أن بعض الفقه قد توسع كثيرا في مجال تطبيق هذه النظرية.

1) فقد قرر هذا الفقه أن نظرية الظروف الطارئة تتجاوز الالتزامات الناشئة عن العقد إلى الالتزامات التي تجد مصدرها في الإرادة المنفردة، و يمثل لذلك بالوصية التي توضع في ظروف وحينما يحين وقت تنفيذها تتغير الظروف بكيفية تضر بأحد الموصى لهم.[57]
2) وقد قرر هذا الفقه أن نظرية الظروف الطارئة تتجاوز المجال الإداري إلى مجال الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية، و الالتزامات الناشئة عن نص تشريعي.
3) وأخيرا فقد قرر هذا الفقه أن نظرية الظروف الطارئة هي تقنية قانونية يستفيد منها كل من الدائن و المدين على حد سواء، ومن ذلك مثلا رفع قيمة النقود قد يضر كثيرا بالمدين في التزام عقدي متراخي التنفيذ وأن تخفيض قيمة النقود قد يضر كثيرا بالدائن في التزام مماثل.[58]

كما هو معلوم أن للعقد دورا هاما في تنشيط الدورة الاقتصادية داخل المجمع، ذلك انه الوسيلة القانونية الوحيدة لتبادل مختلف المنافع بين أفراد المجتمع، بحيث يسعى كل فرد للحصول على مقابل ما أعطاه وتعهد به، لذلك أولاه المشرع مكانة هامة، وذلك بتنظيم العلاقة بين المتعاقدين سواء من حيث قواعد قيامه أو شروط صحته وأيضا ضمن حرية الإرادة في إبرام العقود.

لكن قد يحدث في مرحلة تنفيذ العقد أن تتغير الظروف الاقتصادية التي كان العقد يقوم عليها وقت تكوينه تغييرا فجائيا بسبب ظروف طارئة غير متوقعة، أدت إلى اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، و تعتبر نظرية الظروف الطارئة أو الاستثنائية من إبداع مجلس الدولة الفرنسي ,بهدف تمكين الدولة من مواجهة بعض الظروف الخطيرة التي تهدد سلامتها وأمنها الداخلي والخارجي، ويقصد بالظروف الطارئة تلك الظروف الاستثنائية وغير العادية التي تحدث فجأة وتهدد سلامة الدولة ونظامها مثل الحروب الأهلية والكوارث الطبيعية أو في حالة الانقلابات الأمنية أو انتشار أمراض أو أوبئة تهدد صحة و سلامة المواطنين.

---

[57] ففي إطار القانون الفرنسي نفترض أن أبا قد وزع ثروته بين ابنيه بالتساوي عن طريق وصية، منح للأول أوراقا نقدية و منح ثاني عقارات تساوي قيمتها ما منح للأول. فإذا اتضح، بعد وفاة الأب، أن الأوراق النقدية قد هلكت لسبب لا دخل للابنين فيه، وجب توزيع العقارات بالتساوي بينهما للظروف التي طرأت من جهة و إعمالا لإرادة الموصي من جهة أخرى.

[58] Article **209** du code civil français : Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

فمتى حدثت هذه الظروف الاستثنائية، يحق للدولة التدخل لإحداث قوانين تتناسب مع المرحلة، وقد تكون مخالفة للقوانين المعمول بها في الأوقات العادية، فتصبح تصرفاتها إذن مشروعة في حدود مواجهة الظروف الطارئة والخطر المصاحب لها.

وبالرغم من غياب تعريف شامل وموحد لنظرية الظروف الطارئة ,نظرا لتعدد الظروف الاستثنائية واختلافها من حيث الزمان والمكان ومرونة الفكرة، إلا أن هناك مجموعة من التعاريف العامة التي توصل إليها الفقهاء تعتبر تعاريف متضاربة، نذكر منها مثلا تعريف الفقيه والين حيث عرفها على أنها حالة مادية ذات اثر مزدوج، فهي تؤدي من جهة إلى توقيف سلطة القواعد العادية تجاه الإدارة، كما أنها تؤدي من جهة أخرى إلى تطبيق شرعية خاصة يحدد القاضي متطلباتها على تلك الأعمال.[59]

بينما ذهب فقيه آخر إلى اعتبارها تعد بناء قانوني وضعه مجلس الدولة الفرنسي، والذي بمقتضاه فإن بعض أعمال الإدارة التي تعتبر غير شرعية في الظروف العادية يمكن أن تصبح أعمالا شرعية في بعض الظروف لأنها ضرورة لحماية النظام العام وسير المرافق العامة.

تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي سار على النهج الذي سارت عليه أغلب الدول العربية، حيث لم يشر في تشريعاته إلى نظرية الظروف الطارئة.

وبما أن نظرية الظروف الطارئة تعد استثناء من القوة الملزمة للعقد، فإنه كان من البديهي أن يكون لذالك مبرراته على مستوى القانون، حيث ذهب الفقه والقانونيون إلى تبرير الأساس الشرعي لهذه النظرية، فمنهم من اعتبر بأن العقود يجب أن تنفد بحسن نية ومنهم من قيل انه نظرية السبب، وقيل أنه مبدأ الإثراء بلا سبب، كما قيل انه نظرية التعسف في استعمال الحق، ومنهم من أرجعها إلى المبادئ العامة للعدالة.

- **التيار الذي يعتبر حسن النية أساس لنظرية الظروف الطارئة :**

يذهب أنصار هذا الأساس إلى القول بأن النظرية تقوم على أساس المبدأ القاضي بأن العقود ينبغي أن تنفد بحسن نية، فإذا أصبح التزام المدين مرهقا نتيجة ظروف طارئة لم تكن في حسابه، لم يكن من حسن النية أن يقوم الدائن بمطالبة المدين بتنفيذ التزامه المرهق، إذ يكون الدائن سيئ النية لعلمه بما قد يصيب المدين من خسارة فادحة نتيجة التنفيذ بشكل يجعله متعسفا. وقد تعرض هذا الأساس للنقض، لأنه لا يمكن وصف الدائن بأنه سيئ النية، كونه طالب مدين

[59] فاطمة أوسحاق ،**آثار القوة القاهرة على الالتزام العقدي في القانون المغربي والمقارن** ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق عين الشق ،السنة الجامعية 2006/2005، ص 45

بحق خوله له العقد لمجرد أن في الحصول على هذا الحق تهديد للمدين بخسارة فادحة.

- **التيار الذي يعتبر السبب كأساس لنظرية الظروف الطارئة :**

يعتبر السبب من الأركان اللازمة لقيام العقد ونشأته بحيث أن عدم وجوده أو انتفاءه يعني بطلان العقد وقال أصحاب هذا الأساس أن الالتزام العقدي إذا تجاوز الحد المتوقع لدى المتعاقدين وأصبح مرهقا بسبب الظروف الطارئة فحينها يصبح التزاما لا يستند إلى سبب كامل فيتعين انقضاؤه، لأن القدر الزائد في عبئ الالتزام والناتج عن الظرف الطارئ هو في منطق هذا الفقه لا يقابله شيء من السبب وقد انتقد هذا الرأي بحجة أنه لا يقوم على تصور سليم أو فهم صحيح لفكرة السبب، فلا يجوز أن توصف تلك الفكرة بأنها ناقصة أو زائدة، حيث إنها تقوم على مقاييس معينة ولا شأن لها بمسألة القيم أو الكم كما لا يشترط في نظرية السبب وجود التعادل الاقتصادي، وإن وجد فلا يشترط استمراره وإلا لكان الغبن سببا في إبطال العقد.

- **تيار مبدأ الإثراء بلا سبب كأساس لنظرية الظروف الطارئة :**

حاول البعض تشبيه الظروف الطارئة بحالة الإثراء بلا سبب مشروع، حيث ما ينجم عن الظروف الطارئة من إخلال في التوازن الاقتصادي يؤدي إلى إثراء الدائن بلا سبب مشروع على الظروف الطارئة ارتفاع قيمة الالتزام العقدي لصالح الدائن، وتمسك هذا الأخير بتنفيذ العقد في مواجهة المدين، رغم أن في ذلك التنفيذ إرهاق للمدين وتهديد له بخسارة فادحة، يعين على المحكمة التدخل لتعديل العقد ومنع الدائن من الإثراء بلا سبب مشروع على حساب المدين.

- **تيار فكرة التعسف في استعمال الحق كأساس لنظرية الظروف الطارئة :**

هناك من رأى بأن أساس نظرية الظروف الطارئة هو مبدأ التعسف في استعمال الحق، فإذا نشأت ظروف طارئة لم تكن متوقعة لدى المدين وترتب عليها أن أصبح تنفيذ الالتزام مرهقا ,فإن الدائن يكون متعسف في استعمال حقه إن طالب المدين بتنفيذ التزامه في ظل تلك الظروف.

- **تيار فكرة المبادئ العامة للعدالة كأساس لنظرية الظروف الطارئة :**

يرى المنادون بهذا الأساس أن العدالة هي الأساس الذي ينبغي أن تستند إليه الظروف الطارئة، وأن العدالة كمبدأ أخلاقي فوق الإرادة، بالتالي فأحكام هذه النظرية مستلهمة من فكرة العدالة. ويرفض آخرون هذا القول بحجة أن استقرار التعامل ينبغي أن يقدم على العدالة، بحيث إن العدالة ليست هي الغاية الوحيدة

للقانون، فليست كل قاعدة قانونية تحقق مصلحة عامة تتفق بالضرورة وروح العدالة.[60]

لقد أجمعت النظم القانونية على ضرورة توفر مجموعة من الشروط لقيام نظرية الظروف الطارئة، ويترتب عن غياب أحد هذه الشروط سقوط تطبيق هذه النظرية :

- **الشروط المتعلقة بالعقد :** لكي تقوم الشروط المتعلقة بالعقد، ويمكن على ضوئها تطبيق نظرية الظروف الطارئة يجب توفر عنصر التراخي في تنفيذ العقد وتقابل الادعاءات وأن يكون العقد محددا أو احتماليا.

1. **عنصر التراخي :** العقود المتراخية هي التي يتطلب تنفيذها فترة زمنية، ووفقا لهذا الشرط ينبغي أن تكون العقود التي تطبق فيها نظرية الظروف الطارئة متراخيا، بحيث لا يكون تنفيذها واجبا فور انعقادها، أي أن يكون هناك فاصل زمني مابين صدورها وتنفيذها، ويكون عنصر الزمن عاملا مهما ويكتسب أهميته من ناحيتين، الأولى؛ وهي ضرورة أن يتراخى في تنفيذ العقد في المستقبل حتى يؤدي الظرف الطارئ إلى إحداث الإخلال بالعقد، أما الثانية؛ فيجب أن يكون هناك متسع من الوقت يسمح بتأثير هذا الظرف الطارئ على الالتزام التعاقدي قبل تمام تنفيذه، فإذا وقع الظرف الطارئ في وقت انعقاد العقد فإن المدين يجب أن يكون عالما بالنتائج التي يحدثها الظرف، فإن وجد في العقد ما يشير إلى وجود تحوطات لمواجهة هذه الظروف، فلا يكون هناك محل لتطبيق النظرية مع وجود شرط الرضا.
2. **شرط تقابل الادعاءات :** هناك من يرى بأن تطبيق نظرية الظروف الطارئة ينحصر في العقود الملزمة للجانبين دون العقود الملزمة لجانب واحد، لأن المقصود من النصوص القانونية الخاصة بالنظرية هي العقود التي تترتب عنها التزامات متقابلة بين المتعاقدين، وهذا ما يعني أن العقود التي تنشأ التزامات متقابلة بين المتعاقدين تخرج من نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود وإن انتفى عنصر التقابل بين الالتزامات العقدية، وذلك لأن نصوص النظرية في مختلف التشريعات لم تورد هذا الشرط، ولا تحتوي على ما يفهم منها ضرورة توفر شرط تقابل الادعاءات.

[60] خالد بني أحمد ، **الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة ، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي** ، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ، العدد 2، 2006.

وقد ذهب بعض الفقه إلى القول بأن الاتجاه القائل بعدم ضرورة توفر تقابل الادعاءات لتطبيق النظرية هو الأرجح، وذلك أن أساس النظرية هو التخفيف من عبئ الالتزام عندما يصبح تنفيذه مرهقا ومهددا بخسارة فادحة بسبب حدوث ظروف طارئة، وبالتالي فليس هناك مدعاة لتمييز العقود عن بعضها البعض، كما أن فكرة العدالة التي تقوم عليها نظرية الظروف الطارئة تأبى أن يلحق الظلم بمتعاقد بمجرد أن الالتزام العقدي الذي التزم به لا يقابله التزام من الناحية الأخرى، فإن تطبيق شروط النظرية بالالتزام العقدي الذي أصبح مرهقا وليس بالضرورة وجود التزام آخر مقابل، لأن نظرية الظروف الطارئة مستلهمة من فكرة العدالة ولا تتعارض مع المبادئ القانونية العامة.

3. **أن يكون العقد محدد أو احتمالي :** العقود عموما قد تكون آثارها محددة القيمة مند لحظة انعقادها فيستطيع كل من المتعاقدين أن يحدد القدر الذي يعطيه أو يأخذه، وقد تكون آثار العقد غير محددة القيمة، بحيث لا يستطيع أحد المتعاقدين أن يحدد ما يأخذه وما يعطيه كعقود التأمين والرهن. و في هذا الصدد انقسم الفقهاء لفريقين؛ أحدهما يرى أن النظرية لا تطبق على العقود الاحتمالية، فيحتجون بأن العقود الاحتمالية كعقود التأمين والمضاربة في البورصة عادة ما تعرض بطبيعتها أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو كسب كبير، بالتالي فإن عنصر الإرهاق في تنفيذ الالتزام هو عنصر أساسي يتلاءم مع طبيعة هذه الطائفة من العقود الاحتمالية لأن المتعاقد يعلم أو يجب أن يعلم مند لحظة إبرام العقد أن هناك احتمال بحدوث إخلال جسيم بين الادعاءات العقدية بسبب ما قد ينشأ من خسارة باهظة من ناحية، أو كسب طائل من ناحية أخرى، وهذا العلم يعني أن المتعاقد كان يتوقع سلفا بما سيؤول إليه تنفيذ التزامه من إرهاق، وفي هذا التوقيع ما يكفي لاستبعاد نظرية الظروف الطارئة. أما الفريق الآخر، فيرى أن العقود الاحتمالية جميعها تفترض احتمال الكسب والخسارة في جانب طرفيها إلا أن بعضها يقوم على المضاربة والمخاطرة مثل البيوع الآجلة، بعضها الآخر يقوم على توازن احتمالات الكسب والخسارة في جانب الطرفين كالتأمين، هذا النوع الأخير من العقود الاحتمالية يجب أن يمتد إليه تطبيق نظرية الظروف الطارئة، فلو كان هناك عقد تأمين على منزل من الهدم أو على سفينة من الغرق وقامت حرب بعد انعقاد التأمين، إلا أن هذا التوازن يختل لمصلحة المؤمن له وضد مصلحة المؤمن نتيجة

قيام الحرب وتزايد احتمالات تحقق الخطر المؤمن منه مما يوفر الاعتبارات اللازمة لإعمال نظرية الظروف الطارئة.[61]

- **الشروط المتعلقة بالظروف الطارئة :** لقيام الظرف الطارئ يجب توفر مجموعة من الشروط نجملها في ثلاثة شروط، أن تقع بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة، أن يكون الظرف ليس في الوسع توقعه أو دفعه، وأن يجعل الظرف الالتزام مرهقا.

1. أن تقع بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة : يمكن أن تشمل الحوادث الاستثنائية الزلازل أو الحروب و أو الإضراب المفاجئ، أو قيام تسعيرة رسمية أو إلغاءها أو ارتفاع باهظ في الأسعار، أو نزول فاحش فيها، أو وباء ينتشر أو جراد يزحف أسرابا[62] ولا يشترط أن يكون الظرف الاستثنائي راجعا إلى فعل الطبيعة أو نتيجة واقعة مادية، بل من المتصور أن يكون راجعا إلى صدور قانون جديد. وفيروس كورونا المستجد يشكل مثالا يستأنس به في هذا الموضوع ذلك أنه يمكن القول على أنه حادث استثنائي عام وليس المقصود بالعمومية أن يشمل الدول كلها، بل يكفي أن يشمل دولة أو إقليم دولة فقط، أما إذا كان الحادث الاستثنائي خاص بالمدين وحده، فلا يمكنه أن يستفيد من حكم نظرية الظروف الطارئة لأن الحادث خاص وليس عام . وقد ذهب البعض إلى أن شرط العمومية لا فائدة منه، وبرر ذلك بأن الهدف من الأخذ بنظرية الظروف الطارئة هو مساعدة المتعاقد المنكوب من عثرته، والدليل اشتراط كون الخسارة فادحة، ويجب أن ينظر إلى فداحة الخسارة بالنسبة للمتعاقد من خلال ظروفه الخاصة، إذ كيف يعقل أن نطالب المدين بضرورة الوفاء بالتزامه بمجرد أن الظرف خاص وقد هلك ماله مثلا، فكيف ينفذ التزامه في هذه الحالة؟ لذلك كان من الأفضل أن تطبق النظرية سواء كان الظرف عاما أو خاصا.[63]

2. أن يكون الحادث الاستثنائي ليس في الوسع توقعه أو دفعه : يعد عدم التوقع شرطا جوهريا يؤدي إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة، حيث أن كل عقد لابد وأن يحمل في طياته بعض المخاطر، والمتعاقد الحذر هو الذي ينتبه لتلك المخاطر ويقدرها حين إقدامه على إبرام العقد، أما إذا تهاون في ذلك فعليه أن يتحمل كل النتائج المترتبة عن هذا التقصير، لأنه من غير المعقول أن يتوقع ظهور هذه النتائج في بداية التعاقد ثم يطالب بتطبيق نظرية الظروف الطارئة عليه، عندما تصبح تلك النتائج حقيقة واقعية، في

---

[61] عبد الوهاب محمد عبد الوهاب العطار، **الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ الالتزام التعاقدي - دراسة تحليلية -** بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القانون، كلية القانون جامعة الخرطوم السودان، 2005/2004 ص 48

[62] عبد الرزاق السنهوري، **مرجع سابق**، ص 706

[63] حسين عامر وعبد الرحيم عامر، **المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية** ،مطبعة دار المعارف القاهرة، الطبعة الثانية 1989.ص 256

حين يؤمن المتعاقد ضد الظرف الذي يفوق كل تقدير يمكن أن يتوقعه المتعاقدان فإذا كانت متوقعة أو يمكن توقعها فلا سبيل لتطبيق نظرية الظروف الطارئة. ويتفرع على أن الظرف لا يمكن توقعه أن يكون مما لا يستطاع دفعه، لأن الظرف الذي في الإمكان دفعه يستوي في شأنه أن يكون متوقع أو غير متوقع. و على ذلك إذا أمكن دفع الظرف الطارئ كتعطل المواصلات تعطلا عارضا بحيث يمكن التغلب عليه باستعمال طرق أخرى غير تلك التي انقطعت فلا تنطبق النظرية. [64]

ويرتفع وصف عدم التوقع عن الظرف الطارئ، إذا كان طرفا العقد قد ضمنا اتفاقهما بند ينظم مواجهة هذا الظرف في حال وقوعه، وعندئذ يكون أثر الظرف محكوم باتفاق المتعاقدين ولا يكون هناك مجالا لتطبيق أحكام القانون. ومعيار تحديد كون الظرف ممكن تفاديه أو دفعه هو معيار موضوعي قوامه الرجل المعتاد وليس معيارا ذاتيا قوامه ذات المتعاقد، ويترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع دون خضوعه في تقديره لرقابة محكمة النقض لأنه يطبق واقع ولا يطبق قانون.

3. أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ العقد مرهقا لا مستحيلا : يعد شرط الإرهاق من أهم الشروط الواجب توفرها لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، فتحقق هذا الشرط هو الذي يضع النظرية موضع التنفيذ وينقلها من الميدان النظري إلى الميدان التطبيقي، فالظروف الطارئة مهما بلغت درجة خطورتها ودرجة عدم توقع حدوثها فلا يكون لها أي تأثير على العقد إلا إذا ترتب على حدوثها إرهاق في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، ولذلك فإن القاضي يبدأ دوما بالبحث عن تحقق شرط الإرهاق عندما يطلب منه تطبيق نظرية الظروف الطارئة، ثم يبحث بعد ذلك عن شروط أخرى ويخضع شرط الإرهاق للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة النقض مادام استخلاصها سائغا، كما يجب التمسك بهذا الشرط أمام محكمة الموضوع وإلا فلا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يعلق باعتبارات موضوعية خاصة بالصفقة. [65]

---

[64] إدريس العلوي العبدلاوي ،**النظرية العامة للالتزام ، نظرية العقد** ،الجزء الأول ،مطبعة النجاح الجديدة ، طبعة الأولى ، 1996.ص 145

[65] سليمان مقرس، **الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات**، المجلد الأول، **نظرية العقد والإرادة المنفردة**، الطبعة الرابعة، 1987

الفرع الثاني : تأثير نظرية الظروف الطارئة على مبدأ سلطان الإرادة

معلوم أن العقد غالبا ما ينشأ على مصالح متوازنة بين المتعاقدين، سيما وإذا كان عقدا صحيحا لا يشوبه أي عيب من عيوب الرضا، هذه المصالح المتوازنة هي التي تدفع الشخص إلى بناء تطلعات يسعى إلى تحقيقها من وراء إبرام العقد، غير أن هذه المصالح قد تصبح غير متوازنة بفعل خلل معين خارج عن إرادة المتعاقدين. إذن وجب التدخل من أجل إعادة هذا التوازن وجبر الضرر عن المدين الذي صار التزامه مرهقا، وبالتالي تعديل العقد بالرغم من قوته الملزمة.

ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاءها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" و بالتالي يتبين من خلال استقراء هذا الفصل أن المقصود بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، أن العقد مند تمامه تصبح أحكامه هي القواعد المنظمة لعلاقة طرفيه بالنسبة لموضوعه و وبتعبير آخر فهو ما اتفق عليه الأطراف بمحض إرادتهم، ولا يمكن لهما بعد ذلك التملص من الالتزامات الملقاة على عاتقهم، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك أو في الحالات التي ينص عليها القانون.[66]

ومبنى هذه القاعدة أسس ثلاث، أولهما مبدأ سلطان الإرادة، إذ الفرد لا يلتزم إلا بما شاء وإذا شاء أن يلتزم فلا يحول دون ذلك حائل، وثانيهما أساس أخلاقي يقوم على وجوب احترام العهود والمواثيق، وثالثهما اجتماعي مستمد من ضرورة استقرار المعاملات، فإذا كانت العقود لا تلزم عاقديها فإن الناس ستعزف على إبرامها، و منه يشيع في المجتمع الفوضى ويعم القلق، وتنعدم الثقة بين الأفراد، لذلك كان من المحتم إعطاء العقد قوة إلزامية، بحيث يمتنع على أحد الطرفين المتعاقدين الإنفراد بنقض العقد أو بتعديله كما يمتنع على القاضي عدم الاعتداد به.

و باستقرائنا لبعض مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية تنقضي إذا ارتضى المتعاقدان ذلك عقب إبرام العقد التحلل منها طبقا للقانون، كما أنه يجوز لهما نقض الالتزام أو تعديله وذلك باتفاق فيما بينهما، وليس بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، إذ لا يوجد مانع يمنعهما بعد أن أبرما عقد أن يتحللا منه بإرادتهما واعتباره كأن لم يكن،وهذا ما يسمى بالإقالة الاختيارية التي تكون سببا لانقضاء الالتزامات التعاقدية، ويترتب عليها عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها وقت إبرام العقد.

---

[66] مأمون الكزبري ، **نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي** ،الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة الثانية 1979، ص 638

والمشرع المغربي لم ينظم نظرية الظروف الطارئة لا في قانون الالتزامات والعقود ولا في القانون التجاري ولا القانون الاجتماعي بنص تشريعي عام وصريح بحكم مختلف العلاقات التعاقدية من مدنية وتجارية وعمالية وغيرها، كما فعلت بعض التشريعات العربية الحديثة، ومن بينها التشريع الجزائري، وإنما هناك بعض التطبيقات التشريعية المتفرقة بين النصوص الخاصة وتلك، في حين أخذ القضاء الإداري المغربي بنظرية الظروف الطارئة في غياب نص تشريعي عام وصريح يفرضها ويبين شروطها ويحدد مختلف الآثار القانونية المترتبة عليها، وتعتبر مسألة أخذ القضاء الإداري بهذه النظرية جد طبيعي، لأن القانون الإداري هو قانون قضائي بالدرجة الأولى، وتتلخص أسباب مراجعة العقد في المجال الإداري في حالة خطأ الإدارة المتعاقدة ، إذ قد تقوم بفعل غير مشروع يؤدي إلى الإضرار بالمقاول، بحيث يحمله أعباء إضافية غير منتظرة، أو في حالة الصعوبة المالية غير المتوقعة، والتي قد تعترض المقاول أثناء تنفيذه للعقد وأخيرا في حالة الظرف الطارئ.

هكذا إذن نستخلص أنه أصبح من الضروري إضافة فقرة جديدة عامة وصريحة إلى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود تقيد من إطلاقه وتلين من صرامته، قدوة بما سارت عليه التشريعات المدنية الحديثة التي تبنت النظرية، لأن مسألة تبني هذه الأخيرة لم يعد أمر اختياري وإنما أصبحت تفرضه الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة، والتحولات والتطورات التي عرفها الفكر القانوني، وهو ما يستدعي ضمان حماية الطرف المدين والوقوف بجانبه لاجتياز محنته الطارئة دون إرادته، ولعل مسألة إغفال المشرع المغربي للظروف الطارئة يعود لأسباب تاريخية لم تكن سائدة عند وضع قانون الالتزامات والعقود ولم تكن تستدعيها الضرورة العلمية في ذلك الوقت.

وبالتالي فالحاجة إلى هذه النظرية في التشريع المدني المغربي أصبحت ضرورة ملحة خاصة وأن أهميتها تزداد بتطور الزمن، وأن تقدم المجتمعات الحديثة رهين بتقدم العناصر المحيطة بها كذلك والظروف الطارئة واحدة من هذه العناصر، لذا فإن دائرتها في توسع مستمر، توسع بات يهدد مختلف مجالاتها الاقتصادية، ويهدد استقرار المعاملات بين المتعاقدين، ولحماية هذه الأخيرة فإنه من الواجب وضع نص تشريعي يجعل المتعاقد مطمئن وهو يقوم بإبرام أو تنفيذ التزام تعاقدي.لأن الأصل العام هو أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق أطراف العقد أو للأسباب التي يقررها القانون، ولكن هناك استثناء لهذه القاعدة، مضمونه أنه وفي الحالات التي تظهر فيها حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً يجاوز سعة المدين، ويهدده بخسارة فادحة، جاز عرض الأمر على المحكمة ليتدخل القاضي موازناً بين مصلحة الطرفين، وله سلطة تقديرية لرد الالتزام المرهق للحد المعقول، متى اقتضت العدالة ذلك.

المطلب الثاني : نظرية القوة القاهرة

تمثل القوة القاهرة وسيلة قانونية هامة تسمح للمدين الذي ارتبط بالتزام عقدي أصبح مستحيل التنفيذ بسببها، بالتحلل من هذا الالتزام، إضافة إلى أنها تعد وسيلة قانونية تسمح للمدين بالتخلص من المسؤولية المدنية عموما . ولكي تشكل الواقعة، قوة قاهرة لابد أن تتحقق فيها بعض الشروط، لكي يسأل المدين عقديا، يجب أن يكون قد أخل بالتزامه العقدي . ومن بين صور الإخلال بهذا الالتزام، من طرف المدين؛ عدم تنفيذ العقد في الوقت المتفق عليه، وهذا هو التماطل، ومادام عدم تنفيذ العقد في الوقت المتفق عليه يشكل من الناحية القانونية صورة من صور الأخطاء العقدية فإن هذا يرتب على المدين المسؤولية المدنية، بناء على الفصول 230 ، 245 ، 255 من قانون الالتزامات و العقود غير أن هذه المسؤولية قد ترتفع عن صاحبها إذا ما تمسك بأحد الأسباب الأجنبية عنه والمعفية منها وتمثل القوة القاهرة أحد أهم صور السبب الأجنبي.

تخضع جميع العقود لقاعدة عامة تتمثل في التزام الأطراف بتنفيذ ما ورد بها من التزامات، ولكن هذه القاعدة تصطدم بقاعدة أخرى وهي أن يكون هناك توازن بين التزامات الأطراف من الناحية الاقتصادية في مرحلة تكوين العقد وتنفيذه، ويتم مواجهة أي اختلال يصيب هذا التوازن في مرحلة التعاقد عبر نظرية الإذعان، أما في مرحلة التنفيذ فيتم مواجهته عبر نظريتين هما نظرية القوة القاهرة و نظرية الظروف الطارئة، وما يهمنا في هذا المجال هو الاستثناء الثاني المتعلق بالقوة القاهرة أثناء التنفيذ.

الفرع الأول : الأساس القانوني للقوة القاهرة

لقد عرف الفقيه الروماني **Ulpien** القوة القاهرة بأنها "كل ما لم يكن في وسع الإدراك الآدمي أن يتوقعه ، وإذا أمكن توقعه ،فإنه لا يمكن مقاومته"، كما عرف البعض القوة القاهرة **Force majeur** أو الحادث الفجائي **Cas fortuit** ، هي حادث لا يمكن توقع حصوله وغير ممكن دفعه، أو التغلب عليه، وهذا الحادث لا يكون منسوبا للمدين، أي يكون خارجيا عنه أو مستقلا عن إرادته، و يكون من نتيجته استحالة تنفيذ الالتزام.

وقد تضمن القانون المدني الفرنسي في تعديله لسنة 2016 في مادته 1218 تعريفا للقوة القاهرة في إطار المسؤولية العقدية على أنه : " يشكل قوة قاهرة، في المسائل التعاقدية الحادث الذي لا يخضع لسيطرة المدين، والذي لم يكن بالإمكان على نحو معقول توقعه عند

إبرام العقد، ولم يكن بالإمكان تفادي أثاره باتخاذ إجراءات مناسبة ، ويحول دون تنفيذ العقد"[67]

وقد تطرق المشرع المغربي للقوة القاهرة في الفرع الثاني من القسم الرابع من قانون الالتزامات و العقود، فتولى تعريفها بنفسه في الفصل 296 بأنها : "هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف و العواصف و الحرائق و الجراد) وغارات العدو وفعل السلطة ، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام عملا مستحيلا.

ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.

وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين".

ويعد هذا التعريف مشابها لما ورد في مجلة الالتزامات والعقود التونسية في مادتها 283 ، فنستشف من خلال الفصل 269 من قانون الالتزامات و العقود، أن المشرع المغربي وضع الإطار العام لنظرية القوة القاهرة بحيث بين لنا مفهومها، وأعطانا أمثلة عنها، وقام بتحديد شروطها.

وتجدر الإشارة أن المشرع المغربي لم يفرق بين مصطلحي القوة القاهرة و الحادث الفجائي، واعتبرهما كمترادفين يؤديان نفس المعنى[68].

و لتحقق القوة القاهرة لا بد من توافر مجموعة من الشروط، و تنقسم هذه الشروط إلى قسمين :

1. **شروط تشريعية :** ونقصد بالشروط التشريعية الخاصة بالقوة القاهرة، تلك الشروط التي تجد أساسها في النصوص التشريعية، وقد حدد المشرع المغربي هذه الشروط في الفصل 269 من قانون الالتزامات و العقود و هي كالتالي :
   أولا : عدم التوقع؛
   ثانيا : استحالة الدفع؛
   ثالثا : عدم صدور خطأ من المدين المتمسك بالقوة القاهرة.

---

[67] Article **1218** du code civil français (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2) **: «** Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles ***1351*** et ***1351-1***. **»**

[68] محسن عبد الحميد، **اختلال التوازن الاقتصادي للعقد من خلال نظريتا القوة القاهرة و الظروف الطارئة**، 2020، ص 236.

- **القوة القاهرة حادث غير ممكن التوقع :** و يقصد بذلك ألا يكون بوسع المدين توقع حصول الحادث نظرا لأن الحادث غير اعتيادي و نادر الوقوع ، فالعبرة في تقدير عدم إمكان توقع الحادث هي بوقت إبرام العقد ، فإذا كان متوقعا وقت إبرام العقد فلا يمكن وصفه بالقوة القاهرة ، ولا يمكن للمدين التذرع به للإعفاء من المسؤولية عدم التنفيذ فعدم التوقع يقدر بمعيار موضوعي.

إن الوقائع التي تجعل الالتزام التعاقدي مستحيل التنفيذ، والتي تكون من الناحية القانونية حالة للقوة القاهرة، تعفي من تقررت لصالحه من المسؤولية المدنية،و يجب أن تكون غير متوقعة الحدوث من لشخص المدين الذي يتمسك بها . فإن أمكن لهذا الأخير توقع حدوث هذه الوقائع، بكيفية أو بأخرى، فإن تلك الوقائع لا تمثل في حد ذاتها، بالنسبة إليه قوة قاهرة من الوجهة القانونية وفق ما أكده المشرع صراحة من خلال نص الفصل 269 من قانون الالتزامات و العقود.
ويراد بعدم التوقع، أن يكون الفعل طارئا بطبيعته في حدود المعقول والمألوف، فلا وجه للتوقع مثلا في سيول أو فيضان لم يسبق أن شهدت مثلها منطقة تنخفض فيها نسبة التساقط . وعلى العكس من ذلك لا يمكن مثلا للمدين التمسك بالأضرار الناتجة عن تساقط الأمطار كواقعة مكونة للقوة القاهرة في منطقة يعتبر سقوط الأمطار فيها في فصل الشتاء أمرا معتادا، وهذا ما سايره العمل القضائي حيث جاء في حكم قضائي للمحكمة الإدارية بالرباط بخصوص مسؤولية الدولة والجماعات الترابية عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات بأن : "الأمطار الغزيرة والاستثنائية المسببة للفيضانات لا تشكل قوة قاهرة وإنما قرينة على ترتيب المسؤولية لكون وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سبب للإعفاء من المسؤولية ".
وانطلاقا مما سبق، لا يعد من قبيل القوة القاهرة كل ما كان بإمكان المدين توقع حدوثه فمثلا في العقود الدولية لا يعد تذبذب أسعار الأسهم في البورصة بشكل يختل معه توازن السوق قوة قاهرة، ذلك انه متوقع فيها وكثيرا ما يحدث ويبقى المدين فيها ملزما بتنفيذ العقد أو تعويض الضرر الحاصل.
كذلك المتعاقد ي ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية لا يمكن له أن يحتج يما بعد بالقوة القاهرة كذريعة لعدم التنفيذ، ذلك أن هذه الاضطرابات كانت مؤشرات تنذر بوجود أزمة أو حرب أو غير ذلك. و بالتالي فهي متوقعة وعلى العكس من ذلك، لو أن الحرب كانت نتيجة عدوان خارجي مفاجئ، فان ذلك يعد من قبيل القوة القاهرة.
لذا نلاحظ أن خاصية عدم التوقع هي خاصية تتكيف حسب الظروف وليست شرطا له ضوابط محددة بل تخضع لتقدير كل حالة بشكل منفرد، ويبقى على القاضي في ظل كل حالة دراسة ملابساتها وظروفها[69].

[69] Clément DIAZ Avocat Droit Immobilier/copropriété/règlementation Airbnb au Barreau de NICE

وتجدر الإشارة إلى أن عدم توقع وقوع الحادثة المكونة للقوة القاهرة فيما يخص المسؤولية العقدية يكون وقت إبرام العقد . وعليه، متى كان الحادث غير ممكن التوقع وقت التعاقد، كان هذا وحده كافيا حتى ولو أمكن توقعه بعد التعاقد وقبل التنفيذ، وهذا بخلاف ما يخص المسؤولية التقصيرية حيث يكون عدم التوقع وقت وقوع الفعل الضار ذاته.

- **القوة القاهرة حادث غير ممكن الدفع والمقاومة :** عند تناول فكرة إمكانية الدفع أو مقاومة القوة القاهرة نميز بين استحالة دفع الحادث من جهة واستحالة دفع نتائج الحادث بعد وقوعه من جهة ثانية. فالقوة القاهرة مستحيلة الدفع هي التي لا يمكن دفعها أو تلفيها، فلا يكفي للمدين إثبات أن الحادث كان غير متوقع، بل يجب أن يبين الطابع القهري لهذا الحادث الذي جعله عاجزا عن تنفيذ التزامه . وانطلاقا من ذلك، نستنتج أن استحالة الدفع تعني أن الواقعة المكونة للقوة القاهرة، تتجاوز من حيث قوتها الطاقة العادية للشخص العادي، وعليه، لو استطاع المدين دفع الواقعة أو الوقائع المتمسك بها وبالتالي تفادي تأثيرها على تنفيذ الالتزام التعاقدي ولو ببذل بعض الجهد والمشقة، فإن القوة القاهرة لا تقوم من الناحية القانونية ولو توفر شرط عدم التوقع. وما نخلص له أن الحادث الذي يشكل قوة قاهرة يجب أن يجعل من تنفيذ التزام المدين مستحيلا استحالة مطلقة، ولا يمكن دفعه بأي وسيلة كانت.

Il est précisé que le cas de force majeure :
- permet d'activer la clause dite « de force majeure » du contrat, si elle existe, qui peut prévoir le non remboursement d'une partie ou de la totalité du prix stipulé au contrat ;
- permet de s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, par exemple en cas de préjudice invoqué par le client du fait du défaut d'exécution de la prestation (frais de transport ou d'hébergement déjà engagés par exemple).

Conformément à l'article 1218 précité du code civil, la force majeure suspend l'exécution du contrat.
Dans l'hypothèse où le report de l'obligation ou de l'évènement est possible, l'exécution du contrat est suspendue jusqu'à la fin de la période d'interdiction et reportée à la date fixée.
La procédure suivante peut être adoptée :
- une nouvelle date est fixée dans un délai raisonnable,
- une notification du report est adressée au cocontractant,
- le contrat est suspendu jusqu'à la date prévue et les versements conservés.

C'est seulement lorsque l'empêchement est définitif que le contrat est résolu de plein droit, c'est-à-dire annulé avec effet rétroactif.
La mise en œuvre du stade 3 de lutte contre l'épidémie peut s'apparenter à un empêchement absolu.
Il est précisé qu'en l'absence de clause contractuelle particulière, les acomptes doivent être remboursés lorsque la prestation n'est pas exécutée. Ce, même en cas de force majeure.
Les seuls cas où les acomptes n'ont pas à être remboursés sont les suivants :
- la prestation a été partiellement exécutée à hauteur, au moins, du montant de l'acompte.

- **عدم صدور خطأ من المدين (خارجية القوة القاهرة)** : يقصد بخارجية الحادث هو انتفاء العلاقة السببية بين الحادث و عمل المدين، أي ألا يمكن إسناد هذا الحادث ولا بأي شكل من الأشكال إلى عمل المدين تحت أي ظرف سوءا بصفة مباشرة وحتى غير مباشرة.

وبمعنى آخر، أن يكون سلوك المدين سلوكا معتدلا فلا يخطئ ولا يتسبب في القوة القاهرة، ولا يقوم بما يؤدي إلى استفحال نتائجها.

وقد اختلف الفقه والقضاء الفرنسي وتباينت مواقفهم بخصوص شرط خارجية حادث القوة القاهرة، بينما يرى جانب من الفقه أن عنصر الخارجية لا يعد شرطا من شروط القوة القاهرة،و يؤكد جانب آخر بأنه من أهم عنصرها وأوضح شرط بالنسبة إليها.

أما القضاء الفرنسي في عمومه يميل إلى الاعتداد بهذا الشرط، سواء تعلق الأمر بالمسؤولية التقصيرية أو العقدية.

وقد ظهر هذا الشرط لأول مرة في القضاء الفرنسي عندما قررت محكمة النقض سنة 1896 أن العيب الخفي في الشيء، والذي كان سببا في إحداث الضرر، لا يعتبر أمرا معفيا من المسؤولية المدنية، مادام أنه داخليا وليس خارجيا عن الشيء محل الحراسة، وبالتالي عن محيط الحارس[70]، أي أن السبب الذي ليس خارجيا عن الشيء لا يعتبر سببا أجنبيا معفيا من المسؤولية لأنه متصل بتكوينه و تركيبه.[71]

وقد ربط القضاء الفرنسي هذا الشرط في البداية بالشيء ذاته أو عيوبه الخفية المتصلة به، ثم بعد ذلك انتقل هذا الشرط إلى المحيط المادي الذي يباشر فيه المدين نشاطه. ثم بعد ذلك انتقل من المحيط المادي للمدين إلي شخصه هو.

---

[70] في نفس هذا المعنى، بأن العجز المادي أو الشخصي للمستخدمين في تنفيذ العقد يمكن أن يكون Carbonnier لقد بـ ّين الأستاذ كربونيي غير متوقع وغير قادر على رده من قبل المدين، إلا أنه لا يمكنه أن ينتفع منها ويعتبرها قوة قاهرة، لأنها داخلة في نطاق مشروعه، أي أن عنصر للقول بأن خارجية السبب بالنسبة للشيء هي المعيار الحقيقي الوحيد للقوة Tuncالخارجية لم يتحقق؛ وأهمية هذا الشرط دفعت الأستاذ تينك القاهرة، ويشترط هذا الأمر أكانت المسؤولية عقدية أم تقصيرية، فالمادة 1231-1 في مجال المسؤولية العقدية جعلت جانباً من الفقه يؤكد على أن الحادث المكون للقوة القاهرة يجب أن يكون غير منسوب للمدين وخارجاً عن مشروعه، والأمر نفسه على مستوى المسؤولية التقصيرية، ولهذا عن الخارجية بقوله: إنها أمر لا بد منه لا باعتباره شرطاً للقوة القاهرة، بل إن السبب الداخلي في الشيء يكون من Bessonعبر الأستاذ بيسون الأفعال التي يسأل عنها الحارس، فالقرينة التي أتت بها المادة 1242 من القانون المدني الفرنسي، هي التي تسوغ هذا المعيار لأننا لو قبلنا بجعل السبب الداخلي في الشيء باعتباره سبباً معفياً للحارس، طالما إنه غير متوقع وغير ممكن الدفع، فإن ذلك يعني قلب النظام المنطقي للأمور.
Carbonnier J., Les obligations, droit civil, Tome IV, PUF, Thémis, 1994, n°162, p.271; Noguéro D., La maladie du débiteur cas de force majeure: D. 2006, p. 1556; Mayaud Y., Le malaise brutal et imprévisible, cas de force majeure pour l'auteur d'un accident de la circulation, obs. sous C. cass. crim. 15 Nov. 2005, RSC 2006, chron., p. 61; Nocquet P., L'interdiction de la cession de l'officine et la force majeure, Bulletin de l'ordre 378, 2003 p87-90

[71] حمزة بنخدة، **قراءة في أهم مستجدات الإصلاح الجذري للقانون المدني الفرنسي لسنة 2016**، ص 12

وبعيدا عن الفقه والقضاء الفرنسي نتساءل حول وجود هذا الشرط في التشريع المغربي؟

حقيقة الأمر أن المشرع المغربي لم ينص صراحتنا على هذا الشرط، غير أنه يمكن استنتاجه بشكل ضمني من مجموعة من النصوص :

إن مختلف الأمثلة التي أشار إليه المشرع من خلال الفصل 269 من قانون الالتزامات و العقود هي كلها عبارة عن ظواهر طبيعية أو أفعال إنسانية خارجية لا علاقة لها بتاتا بالمحيط الداخلي للمدين.

إن المشرع المغربي قد اشترط من خلال مقتضيات الفصل 268 من قانون الالتزامات و العقود أن يكون السبب المعفي من المسؤولية أجنبيا عن المدين.

كما أن المشرع المغربي قد اشترط من خلال مقتضيات الفصل 269 السالف الذكر أنه لكي ترتب القوة القاهرة آثارها، ألا يكون للمدين دخل في تحريكها.

2. **شروط قضائية :** ليستفيد المدين من أحكام القوة القاهرة عليه أولا إثباتها، والقاعدة العامة أن البينة على المدعي بناء على ما جاء في الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود[72]، وأن ما أثبته المدعي يكون من حق المدعى عليه دحضه بالدليل المعاكس حسب منطوق الفصل 400 من نفس القانون.[73] وعليه فإن المدين الذي تعذر عليه تنفيذ ما التزم به في العقد الذي يربطه بالدائن، يمكنه أن يتخلص من ذلك التنفيذ نهائيا، بل من المسؤولية المدنية كذلك، لكن شريطة أن يثبت أن المانع كان عبارة عن قوة قاهرة و أن يثبت هذه الأخيرة. والواقعة المكونة للقوة القاهرة والتي يتمسك بها المدين، ويدعي كونها هي السبب وراء عدم تنفيذه لالتزامه تعد في هذه الحالات مسألة من مسائل الواقع والتي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، بمعنى أن القاضي يأخذ بها إذا اطمأن إليها وتحققت شروطها، ويستبعدها متى اتضح له خلاف ذلك. ومادام الأمر هنا يتعلق بإثبات وقائع مادية فإن الإثبات يتم بكافة الوسائل الممكنة . ونظرا لخطورة الآثار التي تترتب على التمسك بالقوة القاهرة، فإنه يجب على محكمة النقض الحرص على مراقبة قاضي الموضوع أثناء إعماله لسلطته التقديرية.

« La réclamation possible contre un débiteur en cas d'exécution tardive d'un contrat est essentiellement tributaire des conséquences de celle-ci sur le créancier. Ainsi, si le retard n'occasionne au créancier que le simple inconvénient de ne pas avoir eu sa marchandise (par exemple, de ne pas

[72] ينص الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود على أن : **" إثبات الالتزام على مدعيه "**

[73] ينص الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود على أن : **" إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه "**

recevoir celle-ci au moment où il s'y attendait), il pourra être compensé par l'octroi de dommages « moratoires » (ou dommages dus pour le retard de l'exécution de la prestation). Si, par contre, le retard équivaut à une inexécution totale (exemple: le couturier qui livre la robe de mariée le lendemain des noces), le créancier peut alors réclamer tous les dommages directs, immédiats et prévisibles résultant d'une inexécution complète de même que la résolution de l'engagement. »[74]

الفرع الثاني : تكييف الجائحة بالقوة القاهرة

عرف الفقهاء القوة القاهرة بأنها: كل آفة غير متوقعة وغير مقدورة الدفع تؤثر في محل العقد، فتؤدي إلى استحالة تنفيذه وانفساخه، فالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، حدث منبت الصلة عن
نشاط المدين، يمكنه أن يحتج به لطلب الإعفاء من تنفيذ الالتزامات. وقد اختلف الفقهاء في التفرقة بين المصطلحين، إلا أن الراجح هو أنه لا فرق بينهما، والأمر نفسه سواء على مستوى نصوص القانون الفرنسي التي لا تعطي أي تلميح للتفرقة بينهما أو على مستوى القضاء الفرنسي الذي لم يقم هو أيضاً بالتفرقة بينهما.

والمتمعن في كل من مفهومي القوة القاهرة والحادث الفجائي، وفي مختلف صورهما، سيجد بما لا يقبل الشك، بأنهما عبارة عن أمر واحد يعفي من المسؤولية المدنية عن عدم تنفيذ الالتزامات عموما في حالة توفره على شروط محددة،[75] ويقاس الأمر على معيار موضوعي متمثل في أن الحادثة غير ممكن توقعها ومستحيلة الدفع حتى من أشد الناس حرصاً ويقظة، وأن يكون الضرر خارجاً عن مكونات الشيء، أي أجنبي عن الشيء ذاته، وهذا المعيار منضبط لا يقوم إلا على مدى كفايته في قطع العلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر.[76]

---

[74] Jean-Louis Baudouin, ancien juge à la Cour d'appel du Québec et Patrice Deslauriers, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et avocat.

[75] وضعت معايير للتفرقة بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ، فمعيار نسبية التأثير: فالأولى تمثل قوة لا يمكن مقاومتها في حين أن الحادث الفجائي هو حادث لا يمكن للحذر الإنساني توقعه، لكن لا يمكن لنا التعويل على هذا المعيار؛ لأن كلاً من القوة القاهرة والحادث الفجائي لا يمكن توقعهما أو مقاومتهما.
والحقيقة أن تطبيق مبدأ الالتزام بضمان السلامة في نطاق المسؤولية عن الأشياء، وحوادث العمل، وحوادث النقل وغيرها من الالتزامات الموجبة على المدين التزاماً بتحقيق نتيجة معينة يغني عن البحث في صفة التفرقة ما بين الحادث المفاجئ والقوة القاهرة، حيث يضع هذا المبدأ حلاً حاسماً وميسوراً للتطبيق يعتمد على أن المدين لا يستطيع التخلص من المسؤولية إلا إذا استطاع أن يثبت أن سبب الحادث راجع إلى أمر غالب لا دخل للمدين ولا للشيء في إحداثه، ولا يمكن توقعه ويستحيل دفعه. وهذه الشروط يذكرها المشرع الفرنسي بوضوح، فلو رجعنا إلى نصوص القانون المدني الفرنسي، نجدها تتكلم عن الشروط الواجب توافرها لكي يشكل الحادث قوة قاهرة في المادة 1218 في حين اكتفت بالكلام عن الأثر الإعفائي المترتب عليها في المادة 1231-1 فتكلمت عن أسباب الإعفاء، وقد أشارت إلى لزوم أن يكون السبب غير منسوب إلى المدين، ويمكن أن يكون ذلك بمثابة إشارة إلى الشرط الأول الذي يجب توافره في القوة القاهرة، وهو شرط عدم نسبة القوة القاهرة للمدين.

[76] انظر: قرار محكمة الاستئناف في باريس التي أشارت إلى مفهوم القوة القاهرة في حديثها عن فيروس إيبولا
Cour d'appel de Paris, Pôle 1, Chambre 3, Arrêt du 29 Mars 2016, Répertoire général nº 15/05607.

فإن توافرت شروط القوة القاهرة وفقاً للمفهوم العام لها والتي يمكن أن نتبينها من خلال المادة 2181 من القانون المدني الفرنسي،والتي تتطلب شروطاً يلزم توافرها لاعتبار جائحة كورونا سبباً موجباً لإعادة النظر في الالتزامات العقدية.

1. **عنصر الخارجية للجائحة :** أثار هذا الشرط خلافاً فقهياً وقضائياً، فجائحة كورونا يتوافر فيها هذا الشرط المؤدي لاستحالة تنفيذ الالتزامات، بشرط أن لا يثبت وجود إهمال من الطرف المدعي للضرر، فمثلاً لو طالبت شركة استيراد لبضاعة بتعديل التزاماتها العقدية بسبب جائحة كورونا، يلزم عليها أن تثبت عدم وجود إهمال وتأخير بالتنفيذ عن الموعد المحدد لهذا التنفيذ، وأن تثبت بذلها العناية اللازمة في حفظ المواد المستوردة، وإلى أن الجائحة هي التي أخرت التنفيذ خوفاً من التلوث، ولنفاذ هذا الشرط يلزم إثبات أن عنصر الخارجية هو سبب التأخير في التنفيذ، فلا يعد عنصراً خارجياً إن ثبت أن الشركة -في مثالنا- لم تتبع التعليمات التي صدرت من الجهات المختصة مثلاً في منع استيراد البضاعة من الصين بعد الإعلان عن الوباء فيها، فخطأ الشركة هو السبب في عدم التنفيذ[77]، فيلزم إذا ما تسبب ذلك بضرر للدائن، بأن تقوم بتعويضه، وقد يبدو هذا الأمر متفقاً مع قواعد العدالة في اعتبار ذلك سبباً داخلياً لا يمكن الشركة من الاحتجاج بالجائحة ،لكن ما يجدر بيانه أننا لا يمكن أن نأخذ الأمر السابق كمسلمة، إذا علمنا أن جانباً من الفقه يرى أن فكرة الخارجية نفسها لا يمكن تصورها إلا بالنسبة للمسؤولية المبنية على الخطر، ومن غير المعقول أن يقوم المشرع الفرنسي بوضع نص بهذا الشكل ومن هنا يمكننا القول، باحتمالية اختلاف القضاة في تفسير جائحة كورونا كقوة قاهرة، ففي حالة تعدد الالتزامات العقدية قد تتعثر الشركة بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بجائحة كورنا، لكن بإمكانها تنفيذ بقية الالتزامات، فمثلاً شركة تطوير عقاري توقفت عن استيراد مواد إنشائية سبق وصول وجبات من هذه المواد، فهل يلتزم المطور العقاري حينها بالتوقف أم يلزمه الاستمرار بنشاطه حتى نفاذ المواد الإنشائية التي بحوزته كسبا للوقت، فمثل هذه الفرضية ستكون محل جدل لو عرض ما يشابهها أمام المحكمة، فيحكم أحد القضاة بمسؤولية المطور العقدية عن التوقف عن تنفيذ التزاماته، في حين يرى قاض آخر أنه أمر داخلي في المشروع.[78]

وقد يبدو من الأفضل عدم استخدام لفظ الخارجية لأنه مثير للاختلاف، والعبرة هي أن تكون القوة القاهرة غير منسوبة للمدين على نحو أو آخر، ووضع شرط

---

[77] الفرنسية، التي حكمت بأن العاصفة الثلجية التي قطعت التيار الكهربائي Montpellier يقاس ذلك على حكم لمحكمة الاستئناف في مونبيليي لا تعد قوة قاهرة تعفي شركة الكهرباء من التزاماتها بتوريد الكهرباء، طالما قد ثبت وجود إهمال في الصيانة بالنسبة لمحطة توليد الكهرباء.
C.A. Montpellier, 2e ch. 16 Novembre 1932, Jurisprudence, Gaz.pal., 1933, 1e sem. p.191.

[78] وما يعزز قولنا بإمكانية حصول مثل هذه الاختلافات هو أن اتجاه محكمة النقض الفرنسية الجديد هو عدم الاعتداد بعنصر الخارجية، وذلك عندما اعتبرت أن وجود قوة قاهرة تمثلت بمرض المدين وأعفته من تعويض المتضرر. انظر:
Cass. Ass. Plén. 14 Avril 2006, Recueil Dalloz, 2006, n° 23, Note Jourdain Pp. 1577-1582.

الخارجية يضع قيداً لا مسوغ له، فما دام أن القاضي المختص بهذا الموضوع قد اطمأن إلى أن المدين ليس له صلة بالحادث الذي لا يمكن مقاومته ولا توقعه، فإنه سيلزم إعادة النظر بتنفيذ الالتزامات العقدية.

2. **عدم إمكان توقع الجائحة :** هذا هو الشرط الثاني، فتكون عادية الواقعة هي الفاصل ما بين الحوادث الممكن توقعها، والتي لا يمكن توقعها، فالمدين يجب أن يتوقع الأمور العادية دون الأمور الاستثنائية، لذا يلزم أن تكون الجائحة غير متوقعة، فلو التزمت الشركة باستيراد بضاعة من الصين قبل العلم بتفشي فيروس كورونا، فعدم التوقع قائم؛ لأن العبرة هو عدم توقعها عند إبرام العقد لا في فترة التنفيذ، ولا في المكان الذي سيتم فيه التنفيذ، ولا يتغير من الأمر عدم اعتبار الفيروس في أوله وباء، فما دام لم يسبب اضطرابا في المكان الذي يلزم المدين باللجوء إليه لتنفيذ التزامه (مثل استيراد البضاعة من الصين،) فإن ذلك يعد غير متوقع، لكن شرط التوقع مختل بخصوص العقود التي أبرمت بعد ظهور المرض، ووصوله لدرجة الوباء في الصين. وبذلك ومن أجل أن يدفع بالقوة القاهرة كسبب للإعفاء من المسؤولية، عليه أن يثبت عند إبرام العقد أنه لم يكن يتوقع أن الحادثة ممكنة الوقوع، ويتم تقدير ذلك وفقاً لمعيار موضوعي مجرد لا شخصي، فلا يكفي أن يكون المدين غير متوقع للحادث، بل يجب أن لا يتوقعه الرجل العادي عندما يكون في الظروف نفسها، فعدم إمكان التوقع يقدر بطريقة مطلقة وليست نسبية، فلا نأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للفرد المدين، وإنما يتم الأخذ بالظروف الخارجية والعامة.

فلو أتى إبرام العقد بعد حصول جائحة كورونا، وكان مكان استيراد البضاعة من بلد لم ينتشر فيه الوباء، فإن الشركة لها أن تحتج بعدم التوقع عندما تقوم السلطات الإدارية في مكان تنفيذ العقد بمنع الاستيراد مؤقتاً، فعندها أتى عدم التوقع بمناسبة الجائحة ويعد سبباً لتعديل الالتزامات أو الإعفاء منها، لكن لو توقع حصول ذلك فلا يعفيه، حيث إنه لا يمكن أن يعتبر ذلك مثل القوة القاهرة.[79]

ومجمل الأمر، فإن جائحة كورونا لن تمر بدون تأثير على العقود التجارية التي ستبرم بعد انكشاف غمته، حيث ستظل الريبة من استيراد المواد الغذائية والصحية من الصين بشكل يجعل الشركات المستوردة حذرة في مسألة تعديل الالتزامات العقدية خوفاً من ظهور وباء آخر.

[79] As a result of the COVID-19 pandemic, it has now become rather well known that a debtor may defend himself for the non-performance of an obligation or for a delay in the performance of an obligation by claiming (and proving) force majeure. But is it really such a cure-all for non-compliance with contractual obligations? Force Majeure - Not your get out of jail free card, **WH Partners** - Davinia Cutajar and Nathan Catania, Malta August 31 2020

3. **عدم القدرة على دفع الجائحة :** ينظر إلى الأمر من زاويتين: الأولى عدم القدرة على منع نشوء القوة المعتبرة قوة قاهرة؛ والثانية عدم التمكن بعد أن تتحقق الواقعة، من التصدي للآثار المترتبة عنها، فيلزم التفرقة ما بين الاستحالة والصعوبة، فالمدين بالتزامات تعاقدية لا يعفى من المسؤولية في اللحظة التي يصعب عليه تنفيذ الالتزام، أي عندما يصبح التنفيذ بوضع أكثر كلفة له، بل يجب أن تتحقق استحالة مطلقة لا يمكن التغلب عليها.

فارتفاع كلفة المواد الأولية التي تلتزم الشركات بتوريدها لا يعفيها من تنفيذ التزاماتها، إذ لا يمكن أن يزيد السعر للحصول على المواد، إلا إذا كان مصدر البضاعة في جهة انتشرت فيها الجائحة، ولا يمكن استيراد البضاعة نتيجة الاستحالة -التي تتجاوز من حيث قوتها سواء في أصلها أو في آثارها- قدرة الشركة الاعتيادية، وبالتأكيد فإن للقاضي سلطة تقديرية في تعديل الاتفاق من عدمه.

وبتوافر الشروط الثلاثة سيمنح المدين فرصة طلب تعديل شروط الالتزامات العقدية، أو طلب الإعفاء من المسؤولية عند عدم تنفيذ الالتزام، لكن يلزم الحذر في تطبيق الشروط، فقد تختبئ بعض الشركات خلف الجائحة للتهرب من تنفيذ التزامات عقدية مركبة، فمثلاً: توقف المقاول عن البناء مطالباً المالك بزيادة مدة عقد المقاولة، وزيادة المبلغ لارتفاع الأسعار يلزم أن لا تؤخذ هذه الالتزامات في الاعتبار جملة وتفصيلاً، وعلى القاضي وضع التساؤل الآتي: ألم يكن بإمكان المقاول الاستمرار بالعمل أو القيام بعمل آخر لحين توافر المواد الإنشائية أو التي توقف استيرادها؟ ويتبع هذا التساؤل تساؤل آخر وهو: ألا يمكن استيراد المواد من بلد آخر بالكلفة والجودة نفسها؟ فكل هذا يتطلب رأي الخبراء، ولا يمكن قبول فكرة القوة القاهرة لمنح بطاقة إعفاء من تنفيذ الالتزامات بشكل مجمل.[80]

[80] . KAOUTAR SAJID, Avocate, [MAROC] L'EXÉCUTION DU CONTRAT À L'ÉPREUVE DU COVID-19, 20 juillet 2020 Mise à jour : 7 septembre 2020, L'imprévision diffère du cas de force majeure dans le fait que cette dernière rend impossible l'exécution du contrat tandis que l'imprévision la rend excessivement onéreuse mais pas impossible. Ainsi, les parties peuvent décider de négocier ou de renégocier un contrat sous certaines conditions. En d'autres termes, l'imprévision permet la révision du contrat à la différence de la force majeure où la révision ne peut avoir lieu et par conséquent le contrat devient inexécutable.

المبحث الثاني : تكييف الجائحة بالقياس على ظروف المتعاقدين

تعد الجائحة بصفة عامة -وجائحة فيروس كورونا بصفة خاصة- من أهم الأسباب المؤثرة على الالتزامات التعاقدية- والتي تظهر تأثيراً على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي يعد من الأسس الثابتة فقهاً وقانوناً والمتوافق مع قيم العدالة، وإلا فما قيمة العقود إن لم تلزم أطرافها؟

لكن قوة الإلزام التي منحتها هذه القاعدة للعقد ليست مطلقة، فالعدالة في منحها قوة الإلزام هي التي تسمح باستثناءات عليها، لكن يلزم أن تكون الاستثناءات واضحة لكي لا تصبح هي الأصل، فتفرغ القاعدة السابقة من محتواها. وفي مسعى منا لمناقشة آثار جائحة كورونا التي سببت الخسائر الاقتصادية للكثير من الشركات التجارية، ومحاولة هذه الشركات اتخاذها سبباً لتعديل عقود العمل أو حتى فسخها. فإننا ارتأينا في نطاق هذا البحث، وفي الجزء الأخير منه، ضرورة مناقشة جائحة فيروس كورونا وبيان أبعادها القانونية والصحية والاجتماعية، ومناقشة الأسس التي تعتمد إذا ما تم خرق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومدى قبول آثار هذه الجائحة في تعديل الالتزامات العقدية[81].

من خلال استعراض مفهوم الجائحة فقهاً وقانوناً، فإننا بحاجة لتحديد مدى اعتبار فيروس كورونا والذي اعتبر جائحة، سببا في تعديل بنود العقد، فهل يكون ذلك بصورة تلقائية، بمعنى أن يطالب الطرف المتضرر من تنفيذ التزاماته بإعادة تعديل الالتزامات العقدية؟ أم يتطلب الأمر تدخل القضاء أو حتى لجان فض المنازعات، وإجراء التسوية في كل علاقة عقدية على حدة، ولا تقاس الالتزامات العقدية على ما يشابهها وإن اتحدت في العلة؟

المطلب الأول : إعادة حالة التوازن في العلاقة القائمة بين الدائن و المدين

لما كانت جائحة كورنا سبباً لخلق قوة قاهرة تجعل تنفيذ بعض الالتزامات العقدية مستحيلاً، في حين تكون ظرفاً طارئاً تجعل تنفيذ الالتزامات مرهقاً في عقود أخرى، حيث ستؤدي كسابقاتها من الجوائح إلى وجود متعاقدين تأثرت التزاماتهم العقدية أو على الأقل يدعون ذلك، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تكييف أثر الجائحة على الالتزامات العقدية، أتكون قوة قاهرة أم ظرفا طارئًا؟ لأن المتعاقدين قد لا يمكنهم التمييز بينهما، حيث يشتركان في أن كلاً منهما يأتي بعد إبرام العقد وقبل التنفيذ، فالجائحة تؤثر على نتيجة التكييف، فلو فرضنا أن اتفاقاً أبرم بين متعاقدين وقد اشترطا في بنود

[81] ياسر عبد الحميد الإفتيحات، **جائحة فيروس كورونا وأثرها على تنفيذ الالتزامات العقدية**، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة الثامنة - ملحق خاص – العدد 6 –شوال 1441هـ – يونيو 2020م

العقد على استبعاد القوة القاهرة بشرط في العقد، فعندها إذا كيفت الجائحة على أنها قوة قاهرة سيكون هذا الشرط صحيحاً؛ كونه لا يتعلق بالنظام العام، في حين لو كيفت الجائحة ظرفاً طارئاً فلا قيمة لهذا الشرط. وتكييف جائحة كورونا في علاقة عقدية على أنها قوة قاهرة ستعطي المدين حق فسخ العقد، فيكفي وقوع حوادث فردية خاصة تتعدى شخص المدين، رغم أنها قد لا تكون قوة قاهرة في علاقات عقدية مشابهة، على عكس الظرف الطارئ الذي يلزم أن تتصف الجائحة بالعمومية، التي تشمل طائفة معينة مثل التجار من صنف التاجر الملتزم نفسه أو تجار في منطقة جغرافية معينة، وينتج عن الاختلاف في تكييف امتناع المدين عن تنفيذ التزامه كونه قوة قاهرة أو ظرفا طارئًا لمسألة الإثبات التي يلتزم المدين بإثباتها في الظرف الطارئ.

الفرع الأول : دور التشريع في تحقيق التوازن العقدي

الأصل إذا انعقد العقد صحيحاً مستوفياً أركانه وشروطه صار ملزماً لطرفيه استناداً لقوله تعالى : **"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"**[82] ولقوله صلّى اللهَ عليه وآله وسلّم: **"المُسلِمون عند شروطهم إلاّ شرطا أَحل حراما أَو حرم حلاَلاً "**[83] ويعد ذلك تأكيداً على مبدأ الرضائية في العقود، وأنه مصدر القوة الملزمة للعقد، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية التدخل اللاحق من قبل القضاء، حال اختلال التوازن بين الأطراف بحصول الجائحة. ففي هذه اللحظة يجب البحث عن معيار يسمح للقضاء بالتدخل وحدوده على اعتبار أن ذلك استثناء عن الأصل في وجوب احترام إرادة الأطراف، وأن التدخل هدفه إعادة الموازنة في حدها الأدنى كونها استثناء عن هذا الأصل.

إن حرية الفرد في إبرام العقود تعد من أهم الركائز، الشيء الذي أدى إلى ضرورة حماية رضا المتعاقدين وعدم الارتباط إلا بإرادتهم الخاصة، لذا فان أي التزام من طرف الإنسان لا يقوم و لا يستقيم إلا إذا كان نابعا من إرادته الحرة. إلا أنه قد يلجأ المتعاقد إلى التعاقد دون أي تفحص لشروط العقد أو استفسار عن آثارها القانونية وبالتالي يجد نسه ي مواجهة عد غير متكافئ أي عقد يختل فيه التوازن ما بين أطرافه المتعاقدة.

وهنا يطرح التساؤل عن كيفية إعادة التوازن لهذه العلاقة التعاقدية؟ وبالرجوع إلى قواعد قانون الالتزامات و العقود المغربي الذي كان يحكم هذه العلاقات العقدية، وذلك قبل

[82] **سورة المائدة**، الآية رقم 1

[83] الإمام أبي بكر أحمد البيهقي، **السنن الكبرى**، الجزء السابع، الطبعة الثالثة، دار الكتب العالمية، بيروت، 2003 ص 406

إصداره القانون القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك 31.08 نجد بأن مقتضياته وضعت في ظل سيادة مبدأ سلطان الإرادة حيث يعتبر إرادة المتعاقدين هي أساس العقد.[84]

و لتطبيق روح الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود باعتباره المؤطر الأساسي للعلاقات التعاقدية، ارتأينا أن استحالة تنفيذ العقد في فترة الحجر الصحي هي استحالة مؤقتة لا يمكن لمدين التمسك بها من أجل التملص من التزاماته، بل ينتج عنها إمكانية تأخير تنفيذه، و اعتبار عدم أداء الالتزام دين في ذمة المدين يؤجل برضا الأطراف أو بحكم من المحكمة دون أن يترتب على ذلك أي مطالبة قضائية بالتعويض عن التماطل أو فوائد قانونية عن تأخير تنفيذ الالتزام.

وفي هذا الصدد نسجل الموقف الايجابي لقضاء المغربي من خلال ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بطنجة في حكم صادر لها بتاريخ 2020/12/01 الذي تعرض لإشكالية المطالبة بالواجبات الكرائية بخصوص محل تجاري ذلك أن المدعي طلب من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأداء الواجبات الكرائية المتخلفة بذمته مع التصريح بأن المدعى عليه في حالة مطل و الحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء و إفراغه. وبناءا على ذلك أسست المحكمة مقاربتها للإشكالية القانونية المطروحة باعتبار أن المدعى عليه تنتفي حالة المطل ف حقه على أساس أن عدم أدائه لواجبات الكراء كان لسب مول و هو المتمثل في إغلاق المحل التجاري بسبب جائحة كوفيد 19 وذلك أثناء المدة المطلوبة في الأداء حيث جاء في الحكم المذكور ما يلي : "وحيث انه بمقتضى الفصل 254 من قانون الالتزامات و العقود فانه يكون المدين في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.

وحيث أن الفترة المطالب عنها الأداء و الممتدة من 2020/04/01 إلى 2020/06/30 توافق الفترة التي كان المغرب خلالها خاضعا للحجر الصحي و الطوارئ الصحية بسبب جائحة كوفيد 19، و أن هذه الحالة أدت إلى إغلاق الأنشطة التجارية و من بينها النشاط الممارس من طرف المدعى عليه و المتمثل في بيع الثواب، والذي تأثر لا محالة سلبا بهذه الوضعية، و هو ما يبقى معه توقفه عن أداء واجبات الكراء استنادا إلى سبب مقبول تنتفي معه حالة المطل في حقه خاصة. ومن تم تبقى هذه الواجبات دينا في ذمة المكتري يتعين عليه أداؤه دون أن يترتب وقوعه في حالة المطل المبررة لفسخ العقد و الإفراغ"[85]

غير أن الإشكال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذا التأخير يتطلب موافقة الطرفين معا من خلال الاتفاق مجددا على تأجيل مدة تنفيذ العقد الذي يربط بينهما وذلك وفق أحكام الفصل

[84] نهاد أخزان، **دور التشريع و القضاء في تحقيق التوازن العقدي**، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون المدني و الأعمال، طنجة، 2020/2019، ص 13.

[85] لبنى الغومرتي، **تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل الجائحة الزمنية "فيروس كورونا المستجد كوفيد 19" نموذجا**، مجلة عدالة للدراسات القانونية و القضائية، عدد 13/ السنة الرابعة 2021، ص 31.

230 من قانون الالتزامات و العقود؟ أم يتطلب الأمر اللجوء إلى المحكمة لأخذ مهلة قضائية كما ينص على ذلك الفصل 234 من نفس القانون؟

تعتبر الشريعة الإسلامية سباقة في تنظيم الميسرة في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، فقد جاء في كتابه عز و جل "وان كن ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"،[86] أما دليلها في الحديث " من أنظر معسرا أو وضع له، أظله اله في ظله"

وقد عرف الفقه الميسرة على أنها "مهلة التنفيذ أو الأجل القضائي التي يمنحها القاضي للمدين حسن النية إذا استدعت حالته ذلك، ولم يلحق الدائن من ذلك ضرر جسيم، وذلك حتى ينفذ التزامه ويتوخى الفسخ"

أما المشرع المغربي فقد نظم أحكام مهلة الميسرة في الفصل 243 من قانون الالتزامات و العقود، سيرا على طريق معظم القوانين المدنية في العالم، حيث أنه انطلاقا من مقتضيات هذا الفصل ، تتجلى شروط منح المدين مهلة ميسرة في مراعاة مركز المدين من خلال حالته المادة التي يجب أن يبين أنه معسر وغير قادر على تنفيذ التزامه، وهو ما يبدو متوفرا في ظل الجائحة لأن جل المتعاقدين أعسروا من خلال توقفهم عن العمل، وبالتالي لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية داخل الأجل المحدد لها. هذا فضلا على أن القاضي وفي إطار سلطته التقديرية يتعين عليه أن يمنح للمدين المعسر آجالا معقولة تجعله قادرا على الاستمرار في تنفيذ التزامه التعاقدين شريطة عدم وجود نص قانوني خاص يمنع تمتيع المدين المعسر بآجال جديدة.

ومن مظاهر التدخل القانوني لحماية المدين رغم إناطته بالتزام يتوجب عليه تنفيذه أحكام الإعسار، فالقاضي يعطي المدين بالدين نظرة الميسرة كي يتدبر أمره ويستطيع تنفيذ أداء التزامه أو دينه، ويمكن للمدين رغم حجز أمواله لدائنيه أن يطالب بتسديد ما يسد نفقته ونفقة من تجب لهم عليه فنظام الإعسار تدخل من القانون لصالح كل من الدائن والمدين ،فإذا تصرف المدين لا يسري تصرفه على دائنيه بأن يكون غاشا لهم بتفويت أمواله كي لا ينفذ عليها.[87]

و بالتالي فانه وتحقيقا للتوازن العقدي في ظل الجائحة، فان المشرع عمد إلى تحديد مجموعة من النصوص القانونية و المساطر التي يمكن للمدين للجوء إليها و الاستفادة منها لتأجيل تنفيذ التزامه، فمهلة الميسرة تكريس في آخر المطاف لنظرية سلطان الإرادة أكثر مما يقيدها ما دامت تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الحقيقي للرابطة التعاقدية بتخويلها

---

[86] سورة البقرة، الآية 280.

[87] محمد بن يعيش ، **كوفيد 19 و أثره على الالتزامات التعاقدية، آثار جائحة كوفيد 19 على المنظومة القانونية**، العدد الرابع من مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، الطبعة :الأولى 2020، الرباط، ص 16

الحق للقاضي أمكانية تعديل العقد من أجل ملائمته مع الظروف الاقتصادية دون قيد أو شرط.[88]

و في هذا الصدد، يمكن الحديث عن **التدخل التشريعي غير المباشر في تحديد مضمون العقد،** ويقصد بهذا التدخل أن يقوم المشرع بتقرير صلاحيات للقاضي تبيح له تعديل العقد أو إلغاء بعض شروطه التعسفية التي وضعها أحد الأطراف إضرارا بالطرف الآخر، وأيضا يحق للقاضي إعادة التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد، بالإضافة على ذلك يحق للقاضي تفسير العقد في حالة غموضه للبحث عن النية المشتركة للأطراف.

فالقاضي يستطيع أن يغير ويحد من أثر الإرادة الفعلية للأفراد، فتارة نراه يوسع من مضمون العقد، ليضيف إليه التزاما لم يفكر فيه الطرفان، وتارة ينتقص مما اتفق عليه العاقدان، هذه هي بصورة عامة الصورة التي انتهى إليها مبدأ سلطان الإرادة ومن أمثلة الصلاحيات التي قررها المشرع للقاضي تلك المتعلقة بعقود الإذعان، حيث يستطيع القاضي تقويم بعض السلبيات التي تنجم عن فقدان التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد في عقود الإذعان، وانفراد أحد أطراف العقد في وضع صيغته وإملاء شروطه، ففي عقد الإذعان تنعدم إرادة المتعاقد في التفاوض بشأن العقد المراد إبرامه، ويقتصر مبدأ سلطان الإرادة على جانب واحد يتعلق بقبول التعاقد أو رفضه، حتى أن هناك شكا في مدى توافر هذا الجانب أيضا ، إذ أن الاحتياج إلى السلعة أو الخدمة محل العقد يدفعه إلى قبول بنود العقد كما وضعها الشخص المحتكر دون مناقشة.[89]

الفرع الثاني : التدخل القضائي لإعادة حالة التوازن العقدي

إذا كان القانون المدني في ثوبه التقليْدي لا يسعى سوى لتحقيق التوازن القانوني بين أطراف العلاقة التعاقدية، فإن هذا الأمر قد يسبب اختلالا كبيرا على مستوى التوازن الاقتصادي نظرا لاستغلال المتعاقد القوة لمركزه الاقتصادي المتفوق عن طريق فرض شروط تعاقدية مجحفة في حق المتعاقد الآخر الضعيف كما هو الحال في عقود الإذعان، بل حتى في بعض العقود الرضائية كعقد الاستهلاك مثلا، والذي قد يتضمن بعض الشروط التعسفية أو الشروط الجزائية مع ضرورة التمييز بين كل منهما، مما يجيز التدخل القضائي لإعادة التوازن العقدي والتمرد بالتالي على قدسية العقود أي الحرية التعاقدية.

---

[88] محمد شليح، **سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغري، أسسه ومظاهره في نظرية العقد،** رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،1983، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بالرباط، ص 272.

[89] The Theory of Emergency Conditions and their Impact on the Economic Balance of the Contract "Analytical Study of the Civil Transactions Act in the United Arab Emirates No. (5) Of 1985"

إذا كان الأصل في جميع المعاملات أنها تتم بحرية تامة بين الأطراف المتعاقدة بشأنها استنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة وإلى القوة الملزمة للعقد،فإنه في عصرنا الراهن كثيرا ما نلاحظ اتسام بعض العقود المستحدثة بطابع التعسف سواء أثناء إبرامها أو حتى بعد تنفيذها. وعلى الرغم مما أورده المشرع المغربي من مقتضيات حمائية مضمنة في ق.ل.ع إلا أنها ظلت عاجزة عن تحقيق نوع من المساواة العقدية أو ما يعرف بالتوازن العقدي سواء تعلق الأمر بالنظريات التقليدية (مبدأ حسن النية) أو نظرية عيوب الرضا (الغلط، التدليس، الغبن) الأمر الذي أعطى بموجبه للقضاء الضوء الأخضر للتدخل في بنود العقد عن طريق إعماله لتقنيتي (التفسير والتكييف) بغية تعديل الشروط التعسفية المضمنة فيه بهدف خلق نوع من التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة.

إن نظرية الظروف الطارئة قد واجهت معارضة قوية من الفقه والقضاء عند بداية ظهورها، وترجع تلك المعارضة إلى أن هذه النظرية تخرج القاضي عن دائرة اختصاصه ووظيفته وهي تفسير العقد إلى إطار أوسع بكثير يتمثل في تعديل شروط العقد، وهذا التعديل ليس من اختصاصه .ليس هذا فقط بل يعد إخلالا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومن ثم فإن هذه النظرية من وجهة نظر المعارضين تعطي المجال لتعديل الالتزامات العقدية للأطراف ، كما أنها تهدم مبدأ القوة الملزمة للعقد، وتزعزع الاستقرار الاقتصادي للمعاملات وتساعد المتعاقد سيئ النية على التهرب من التزاماته الواردة بالعقد.

الأمر الذي دفع العديد من التشريعات الوضعية لمواجهة تلك السلبيات الناتجة عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة بوضع ضوابط محددة على السلطة الممنوحة للقاضي للتدخل في العقد لتعديله بسبب الظروف الطارئة بغرض إعادة التوازن الذي اختل بسبب تغير الظروف تحقيقا للعدالة، بحيث يلتزم القاضي بمراعاة تلك الضوابط عند إجراء تعديل للالتزامات الأطراف ، وتتمثل هذه الضوابط في مراعاة القاضي للظروف المحيطة، والموازنة بين مصلحة الطرفين، ورد الالتزام المرهق للحد المعقول.

إن القاضي خلال تناوله للقضية التي تتضمن تطبيق نظرية الظروف الطارئة لرد الالتزام المرهق فإنه يقوم ببحث هذا الأمر في إطار الظروف المحيطة بالعقد التي تنفذ فيها الالتزامات التعاقدية، بمعنى أنه لا ينظر إلى الالتزام المرهق بمعزل عن الظروف المحيطة به لأن هذه الظروف هي التي ساهمت في إضفاء صفة الإرهاق على هذا الالتزام، ولذا فإنه يجب على القاضي أن يقوم ببحث هذه الظروف ليتبين مدى آثارها على التزام المتعاقدين وما إذا كان هذا الظرف الطارئ ذا تأثير مستمر أم مؤقت وحدود واستمرارية هذا التأثير ومدته، كل ذلك من أجل وصول القاضي إلى حل عادل ومناسب للفصل في النزاع القائم أمامه.

وفي هذا المجال يقدم لنا الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري مثالا يوضح لنا مدى أهمية أن يقوم القاضي بمراعاة الظروف المحيطة بالقضية حال الفصل فيها بمقاول يتعهد بإقامة

مبنى وترتفع أسعار بعض مواد البناء كحادث طارئ ارتفاعا فاحشا ، ولكن هذا الارتفاع يوشك أن يزول وهذا لقرب انفتاح باب الاستيراد، فيوقف القاضي التزام المقاول بتسليم المبنى في الموعد المتفق عليه حتى يتمكن المقاول من القيام بالتزامه دون إرهاق إذا لم يكن في هذا الوقف ضرر جسيم يلحق بصاحب المبنى.[90]

وهكذا فإنه يتعين على القاضي أن يقوم ببحث جميع الظروف بالدعوى سواء المتعلق بالعقد أو بالتنفيذ لأن هذه الظروف هي التي أضفت على التزامات المدين وص الإرهاق وكان السبب الرئيسي في تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

إن نظرية الظروف الطارئة لا تعني رفع الإرهاق كله عن كاهل المدين، ولا تعني إلقاءه كله على عاتق الدائن، وإنما تهد هذه النظرية إلى الموازنة بين الطرفين، ومن هنا تظهر أهمية هذا الضابط المتمثل في إلزام القاضي بإجراء المقارنة بين مصلحة كل من المتعاقدين وعلى ضوء ما ينتج عن هذه المقارنة يكون اختيار الحل المناسب، بمعنى أن هذا الضابط يقوم على إعادة توزيع الأعباء الطارئة مباشرة بين طرفي العقد، وهذه هي الغاية الأساسية من تطبيق نظرية الظروف الطارئة والمتمثلة في إعادة تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد الذي اختل بسبب الظروف الطارئة.

وحين الموازنة بين مصلحة الطرفين نجد أن مصلحة كل طرف تختل تماما عن مصلحة الآخر، فمصلحة المدين تتطلب الوقوف بجانبه ومساعدته في الأضرار الفادحة التي لحقت به من جراء الظروف التي طرأت بعد إبرام العقد، بينما مصلحة الدائن تتمثل في رغبته في قيام المدين بتنفيذ التزاماته الواردة بالعقد في الميعاد المحدد خاصة بعد أن اتضح له ارتفاع الأسعار وزيادة كبيرة في المكسب نتيجة فارق الأسعار، ومن ثم لا يوجد فقط اختلال مصالح ولكن يوجد أي ا تضارب مصالح بين الطرفين، وإذا كان العقد حين نشأته كان يقوم على مصالح متوازنة ومتساوية ويهدف إلى تحقيق مصلحة معينة بين طرفيه، إلا أنه بسبب تغير الظروف أدى ذلك إلى اختلال التوازن الاقتصادي بين تلك المصالح وانعدم التعادل بين مصالح طرفي العقد، الأمر الذي دفع المشرع إلى النص صراحة على إلزام القاضي بالموازنة بين مصلحة الطرفين تحقيقا لإعادة التوازن العادل للعقد.

والقاضي حينما يقوم ببحث مصلحة الطرفين لتحقيق التوازن بينهما فإنه يقوم بعدة أمور للتوصل لهذا التوازن وذلك وفقا لسلطته التقديرية حيث يتولى بحث هذه المصلحة في ضوء الحاضر فقط دون النظر إلى ما تم في الماضي من ربح أو خسارة، وكذلك بصرف النظر عن المستقبل الذي تكتنفه احتمالات عدة، ومن بينها احتمال زوال آثار الظروف الطارئة. كما أن إجراء الموازنة بين مصالح الأطراف هو أمر نسبي يختل من حالة إلى أخرى ومن عقد إلى

[90] عبد الرزاق السنهوري، **مرجع سابق**، ص 725

آخر ومن هنا كانت سلطة القاضي في هذا المجال تقديرية حتى يتمكن من بحث كل حالة على حدة في ضوء الظروف المحيطة بها وإجراء تلك الموازنة بين مصلحة الأطراف.

ومن ناحية أخرى، يعد مبدأ رد الالتزام المرهق للحد المعقول بواسطة القاضي هو الغاية من تطبيق نظرية الظروف الطارئة، والمقصود برد الالتزام المرهق أن يشترك طرفا العقد الدائن والمدين معا في الخسارة التي لحقت بالمدين بسبب الظروف الطارئة وغير المتوقعة، مما مفاده عدم تحمل المدين وحده تلك الخسارة الفادحة، فبقدر المكسب تكون الخسارة.

وإذا كان القاضي حال بحثه الحد المعقول يأخذ بعين الاعتبار الفرق الناجم بين قيمة الالتزام في العقد وقيمته بعد وقوع الحادث أساسا للتحديد وفق المعيار الموضوعي، إلا أن ذلك لا يحول دون قيام القاضي ببحث الظروف الخاصة بالمدين وأخذها بعين الاعتبار ولكن في أضيق الحدود، ومن ثم يكون في سلطة القاضي التقديرية اللجوء للمعيار الشخصي للمدين للتخفيف من وطأة المعيار الموضوعي المادي.

بالإضافة إلى ذلك فإنه على الرغم من أن المبدأ المستقر عليه في نظرية الظروف الطارئة هو اتسام العبء الطارئ أو الخسارة غير العادية بين الطرفين، إلا أنه لا يشترط أن يتم هذا التقسيم بالتساوي ومناصفة بينهما، فالتشريعات السابقة لم تحتم هذه المساواة في تحمل العبء الطارئ، وبالتالي فإن القاضي يختص بسلطة واسعة في تقدير الحصة التي يجب أن يتحمل بها كل متعاقد في الخسارة غير المتوقعة أو العبء الطارئ، وهذه السلطة الواسعة للقاضي لا يوجد عليها أي قيود سوى قيد المعقولية أو ضابط المعقولية، فالقاضي مقيد بنص القانون، ومن ثم لا يستطيع أن يبالغ في رد الإرهاق أو يخرج عن الحد المعقول، بل يجب عليه أن يراعي في ذلك ما يفرضه ضابط المعقولية من الوقوف عند حد معين وعدم تجاوزه. ويظهر حد المعقولية الذي يلتزم به القاضي حال حسم النزاع القائم بين الأطراف بناء على نظرية الظروف الطارئة بصورة واضحة في بعض النقاط الأساسية والمتمثلة في أن القاضي لا يستطيع أن يقوم بإلقاء كل العبء الطارئ أو الخسارة كلها على عاتق أحد الطرفين مع إعفاء الطرف الآخر، كما لا يستطيع القاضي أن يقوم بتقسيم الخسارة الناتجة عن الظروف الطارئة على كلا المتعاقدين بالرغم من أن الظروف تسمح بإرجاء التنفيذ إلى ميعاد آخر في المستقبل بسبب الطبيعة المؤقتة أو الانتقالية للظرف الطارئ.[91]

لقد اتفقت غالبية التشريعات على منح القاضي سلطة تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد لإعمال نظرية الظروف الطارئة في حالة توافر شروطها، حيث يتولى القاضي معالجة أو إزالة الاختلال في التوازن وبما يؤدي إلى رفع الإرهاق الواقع على أي من الطرفين، وبذلك خول القانون للقاضي سلطة تجاوز حدود مهمته العادية وهي التفسير، فأجاز له في هذه الحالة أن يعدل العقد.

[91] عبد الرحمان الشرقاوي، **دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي**، طبعة 2002، ص 64.

إن قاعدة حرية التعاقد تنبثق منها العديد من الحريات والمبادئ ومنها حرية الفرد في التعاقد أو في الامتناع عن التعاقد، وأيضا حريته في اختيار المتعاقد الآخر، وفي تحديد مضمون العقد، وبالنسبة للمبادئ نجد أن المبادئ الأساسية تتمثل في مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ القوة الملزمة أو التنفيذية للعقد، ومن ثم فإن الإرادة تلعب دورا بارزا في التعاقد، فالإرادة هي التي تنظم تكوين العقد وتحديد مضمونه وحقوق والتزامات الأطراف. ومع مرور الوقت لم تعد قاعدة حرية التعاقد قاعدة مطلقة في الوقت الحاضر، فقد يتدخل القانون مباشرة بتقييد هذه الحرية بنصوص قانونية آمرة، وقد يتدخل بطريق غير مباشر بتقييدها عبر منح القاضي سلطة تعديل العقود لأسباب محددة.

المطلب الثاني : البديل المستحدث للتعويض عن التأخير

تلقي الجوائح كوقائع مادية بآثارها السلبية على ملامح النشاط الإنساني، ويظهر أثرها بوضوح على العلاقات القانونية بشكل عام، والعلاقات التعاقدية بشكل خاص، ويظهر ذلك جليا مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ أثرت هذه الجائحة بشكل واضح على المعاملات الوطنية، وتعاظم هذا التأثير على مستوى معاملات التجارة الدولية بسبب إجراءات الإغلاق وتعليق عمليات النقل الدولي المصاحبة لتدابير منع تفشي الوباء ، فأصبح من المستحيل أو على الأقل من الصعب تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية .ومن هذا المنطلق أثارت جائحة فيروس كورونا المستجد مسألة تغير ظروف تنفيذ العقد والحلول القانونية ممكن إعمالها وتبقي على العقد ضمن تحقيق المصلحة التي تخدم طرفيه.

ولما كان تحقيق المصلحة الاقتصادية للعقد هو الغاية الأساسية لاستمراريته، فقد أوجد الفقه تقنية جديدية كبديل مستحدث لتفادي التعويض عن التأخير و هي تقنية إعادة التفاوض و ذلك لمواجهة تغير ظروف تنفيذ العقد، كنتيجة لعدم مواكبة الحلول التقليدية - نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة-للتطورات الحاصلة خلال الجائحة الزمنية كوفيد-19.

وعليه فإن إعادة التفاوض هي تقنية قانونية حديثة وليدة الممارسات العقدية في مواجهة مشكلة تغير ظروف تنفيذ العقد، و هو ما يستدعي الوقوف عند مضمون هذه التقنية **(الفرع الأول)**، و مدى استيعاب هذه الآلية للتكييف القانوني لجائحة كورونا **(الفرع الثاني)**.

الفرع الأول : مضمون تقنية إعادة التفاوض

تعرف تقنية إعادة التفاوض على أنها الشرط الذي يدرجه الأطراف في العقد ويتفقون فيما بينهم عندما تقع أحداث من طبيعة معينة يحددونها، سواء في العقد ذاته أو في اتفاق منفصل، وتكون هذه الأحداث مستقلة عن إرادتهم، وتوقعاتهم عند إبرام العقد، ويكون من طابعها الإخلال بتوازن العقد وإصابة أحد المتعاقدين بضرر فادح.

يعطي هذا التعريف الطابع الاتفاقي لشرط إعادة التفاوض، ونية الأطراف في الإبقاء على العقد وملائمته مع الظروف المستجدة عليه، بحيث أن هذا الشرط يسمح بإيجاد حلول للإبقاء على العقد، وعليه فهو لا يتخذ صورة واحدة في كل العقود، إنما يختلف باختلاف العقود، واختلاف المصالح التي يرغب الأطراف في حمايتها، ويتم إعمال شرط إعادة التفاوض متى وقع الظرف الطارئ في الفترة الزمنية الواقعة بين انعقاد العقد وتنفيذه، إضافة إلى تتحقق عناصر في الحادث ذاته وبمدى اتصال الحادث بالمدين وفقا لما يلي:

1. **العناصر الواجب توفرها في الحدث :** لإعمال شرط إعادة التفاوض يستوجب أن تتحقق في الحدث العناصر التالية :

- **عمومية الحدث** والمقصود بها أن يشمل الحادث طائفة معينة من الناس، وأن يغير في الظروف التي أبرم العقد في ظلها، أي لا يكون خاصا بالمدين فقط.
- **استثنائية الحدث** يكون الحدث استثنائيا عندما لا يندرج في عدد الحوادث التي تتعاقب وتقع وفقا لنظام معلوم، ولا يكفي أن يكون مجرد وقوع الحدث غير مألوف، بل أن تكون الجسامة التي وقع بها غير مألوفة لندرة وقوعها، والهدف من اشتراط عنصر الاستثنائية هو من أجل تقليص مجال الخروج على مبدأ القوة الملزمة للعقد إلى الحد الذي يمكن من خلاله التوفيق بينها وبين استقرار المعاملات.
- **أن يحدث الحدث اختلالا في توازن العقد** :يعتبر هذا الشرط منطقيا في الحدث حتى يتم إعمال شرط إعادة التفاوض، لأنه لا يكفي وقوع الحدث الاستثنائي، بل يتوجب أن يؤدي هذا الأخير إلى اختلال واضح في أداء العقد، مما يترتب عليه أن تنفيذ الالتزام التعاقدي أصبح مرهقا للمدين، ويهدده بخسارة فادحة.

2. **اتصال الحدث الطارئ بالمدين** : من بين الشروط الواجب توفرها لإعمال شرط إعادة التفاوض

هو اتصال الحدث الطارئ بالمدين، وهذا الاتصال يتحقق بتوفر العناصر التالية :

- **عدم توقع الحدث من قبل المدين** :يعد عنصر عدم توقع الحدث من قبل المدين، عنصرا جوهريا لإعمال شرط إعادة التفاوض، ويدخل عنصر عدم توقع الحدث

في العناصر المكونة لشرط القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، وهو ما جاءت به غرفة التجارة الدولية في الشروط النموذجية للقوة القاهرة والظروف الطارئة لسنة 1985، إذ نصت على أنه "في حال وقوع أحداث غير متوقعة من الأطراف من شأنها أن تعدل بشكل أساسي توازن العقد الحالي وتؤدي إلى وقوع أعباء غير عادلة لأحد الأطراف أثناء تنفيذ التزاماته التعاقدية"

- **استقلال الحدث الطارئ عن إرادة المدين** :يعتبر شرط توفر استقلال الحدث عن المدين شرطا منطقيا في الحدث حتى يتم إعمال شرط إعادة التفاوض، لأنه من غير المنطق أن يتسبب المدين في إعاقة تنفيذ التزاماته ثم يتمسك بشرط إعادة التفاوض وهنا نكون بصدد إعادة التفاوض عندما تقع أحداث تهدم بشكل أساسي توازن الأداءات العقدية، وتفلت من سيطرة الطرف المضرور، و يسمح هذا الشرط بحماية المتعاقد من تدخل المتعاقد الآخر سيء النية في أحداث التغيير بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتم التعبير عنه بعبارات مثل "حدث خارج عن سيطرة الأطراف" أو "حدث أجنبي عن الأطراف".

و يتم تقدير استقلالية الحدث عن المدين بالأخذ بأحد المعيارين؛ الأول، هو معيار شخصي يذهب إلى أن المقصود باستقلال الحدث عن إرادة المدين هو أن لا تشارك إرادة المدين في أي وقت وبأي شكل في وقوع الحدث، وأن ذلك يقضي بالضرورة أن يقوم القاضي بتحليل موقف المدين وسلوكياته لمعرفة ما إذا كان قد ساهم بشكل أو بآخر في وقوع الحدث. أما المعيار الثاني، فهو معيار موضوعي لا يكتفي فقط بأن يكون الحدث مستقلا عن إرادة المدين، بل يجب أيضا أن يكون بعيدا عن مجال نشاط المدين.

- **عدم إمكانية المدين دفع الحدث الطارئ وتجنب نتائجه :** أي أن يكون أمام المدين حدث يتجاوز إرادته وحدود طاقته، مما يعكس بوضوح انتفاء ركن الخطأ في سلوكه، وعدم إمكانية دفع الحدث تقاس بمعيار شخصيي يعتد فيه بظروف المدين وإمكانياته الذاتية.

إن الغرض من إعمال آلية إعادة التفاوض في العقد هو الإبقاء عليه واستمراره في مواجهة تغير الظروف عند تنفيذ العقد ، ويترتب على إعمال شرط إعادة التفاوض أمرين أساسين الأول هو: وقف تنفيذ العقد، و الثاني هو الالتزام بإعادة التفاوض.

أولا : وقف تنفيذ العقد

يترتب على وقف تنفيذ العقد، توقف طرفي العقد على تنفيذ التزاماتهما خلال فترة بقاء جائحة فيروس كورونا إلى حين إنتهاء تفشي الوباء، والعمل على التوصل إلى اتفاق جديد لتنظيم الالتزامات التي تأثرت بفعل تداعيات جائحة كورونا ، و بالتالي يعد وقف تنفيذ العقد لحين زوال حدث القوة القاهرة أو الظرف الطارئ أحد الحلول التي يبتغيها مبدأ حسن النية.

يشكل وقف تنفيذ العقد نظاما قانونيا من شأنه الحفاظ على بقاء العقد المتأثر بتغير الظروف لوجود شرط إعادة التفاوض. ويعرف وقف تنفيذ العقد على أنه فترة من الوقت يسكن فيها تنفيذ العقد إلى حين إنتهاء الظرف الاستثنائي الذي يعيق تنفيذ العقد ثم يعود إلى سريانه العادي، فهو إعاقة مؤقتة في تنفيذ العقد، نتيجة حدث فجائي يخرج عن سيطرة الأطراف. والهدف من إعمال نظام وقف تنفيذ العقد هو الحفاظ على الرابطة العقدية خلال فترة الحدث المفاجئ، ثم استئناف تنفيذ العقد مرة أخرى بزوال الحدث الذي يعيق تنفيذه[92]

ولما كان نظام وقف التنفيذ هو سكون وخمول مؤقت للعلاقة العقدية، فإنه يمتد ليشمل التزامات المتعاقدين معا، ولا يقتصر على التزامات المدين الذي تأثرت قدرته على تنفيذ الالتزام بسبب تداعيات الحجر الصحي والإغلاق التي اتخذتها الدول فور إعلان منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد هو جائحة[93]. ومنه فإن الدائن لا يملك الحق بإجبار المدين على تنفيذ التزاماته خلال فترة الوقف. وحتى تتحقق الغاية والهدف من وقف تنفيذ العقد، فيجب أن تكون المدة المتبقية من العقد كافية ومفيدة لتحقيق الغرض من التعاقد.

و يجد نظام وقف أساسه في إرادة أطرافه، استنادا إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وتبعا لذلك يسمح هذا المبدأ للمتعاقدين بإدراج أي شرط تعاقدي، يضمن بقاء العقد وإستمراريته. وهذه الشروط تتخذ عدة صور، إما أن تكون صريحة في العقد أو ضمنية، وعليه قد يتفق الأطراف على إطالة مدة تنفيذ العقد نتيجة لتغير ظروف تنفيذ العقد.

يلتزم أطراف العقد عند أخذهم بنظام وقف تنفيذ العقد لحين رفع تدابير الحجر الصحي والإغلاق؛ التي تفرضها الدول لمجابهة التداعيات الصحية لجائحة كورونا، بضرورة الالتزام بمقتضيات الوقف، التي تظهر في وقف تنفيذ الالتزامات الرئيسية وفرض التزامات جديدة، فضلا إلى الالتزام باحترام الآجال المحددة التي يتطلبها إعمال نظام الوقف. ويترتب

[92] شريف محمد غنام، **أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية**، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،2007، ص 275

[93] Peter, Lauren, Philip Charlton, **Managing contractual obligations and negotiation during the Covid-19,** Australia, 2020, page 12

على وقف العقد المتأثر بجائحة كورونا، والذي استحال استحالة مؤقتة في تنفيذه؛ وقف تنفيذ الالتزامات الرئيسية للعقد، إضافة إلى ذلك فرض التزامات جديدة مرتبطة بتنفيذ نظام الوقف. فتأثر العقد بحدث القوة القاهرة باستحالة تنفيذ التزاماته الرئيسية،يؤدي إلى تأجيل هذه الالتزامات إلى حين زوال العائق من التنفيذ.

ويقضي التزام الأطراف بآجال الوقف، وجوب تحديد المدة التي يسري فيها، وللأطراف الحرية في تحديد هذه المدة، حسب طبيعة العقد، وحدث القوة القاهرة، ومن أمثلة ذلك الشرط الذي ينص على أنه "إذا لم يتمكن أحد المتعاقدين من تنفيذ التزاماته بصفة كلية أو جزئية بسبب حدث القوة القاهرة، سوف يوقف تنفيذ الالتزامات والحقوق الناتجة عن العقد طوال فترة بقاء الحدث"؛ و يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في تحديد مدة الوقف في حال سكوت الأطراف عن تحديدها.

ينقضي الوقف انقضاء طبيعيا بانتهاء مدته، ويصبح استئناف تنفيذ العقد حق لكل متعاقد أن يطالب به إذا تقاعس الطرف الأخر عن التنفيذ، كما يمكن أن ينقضي الوقف قبل انتهاء المدة المحددة له، كأن يصبح التنفيذ غير مجدي، أو تتحول الاستحالة المؤقتة للقوة القاهرة إلى استحالة نهائية، فهنا يجوز لأي طرف إنهاء الوقف وفسخ العقد. كما ينتهي الوقف ضمنيا في حال اتفاق الأطراف بسريان العقد بشروط جديدة.

ثانيا : الالتزام بإعادة التفاوض

يقضي تنفيذ الالتزام بإعادة التفاوض بإيجاد نوع من التوافق والتعايش بين المصالح الاقتصادية المتعارضة للأطراف واحترام روح العقد من خلال التعاون بين أطراف العقد، وهو ما يعبر عنه بمبدأ حسن النية، و يعتبر هذا المبدأ من المبادئ المعترف بها في التشريعات الوطنية، والدولية، ويظهر ذلك من خلال عدم إتيان أي مسلك من شأنه أن يبعث الثقة الزائفة لدى المفاوض الآخر، وعليه يجب عدم الدخول في إعادة المفاوضات دون نية جادة في إعادة التوازن للعقد المختل بسبب تغير الظروف، ويظهر حسن النية في صياغة الأطراف مقترحات جادة ومعقولة ، تهدف إلى الوصول إلى حل بين الطرفين حتى ولو لم يصلا إلى اتفاق محدد بشأن إعادة التوازن للعقد.

إن الغاية من إعمال شرط إعادة التفاوض هو إعادة النظر في الالتزامات التعاقدية التي تأثرت بتغير الظروف، وعليه فإن إعادة النظر في العقد المتأثر بالقوة القاهرة تشكل جوهر إعادة التفاوض، ويترتب على إعادة النظر في الالتزامات العقدية إما التوصل إلى اتفاق جديد، أو فشل المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن مراجعة العقد المختل توازنه. وفي حال نجاح المفاوضات يتم إبرام اتفاق جديد، غير أن هذا الأخير يطرح

إشكالية مفادها؛ هل يعتبر عقدا جديدا أم استمرارية للعقد الأصلي؟ يذهب الفقه[94] إلى القول أنه إذا اتفق الأطراف مسبقا على تحديد طبيعة الاتفاق الجديد فلا إشكال يطرح، ومثال ذلك الشرط الذي ينص على أنه " يجب أن يتقابل الأطراف في مدة ثلاثة أشهر ليتفاوضوا في إبرام عقد جديد غير محدد المدة." غير أنه في حالة سكوت الأطراف على تحديد طبيعة الاتفاق الجديد يبقى الإشكال مطروحا حول طبيعة الاتفاق الجديد. و هنا يذهب جانب من الفقه[95] إلى القول أن الاتفاق الجديد هو عقد جديد طالما أن إعادة التفاوض تتضمن النية نحو تجديد العقد الأصلي لا مجرد تعديله، والتجديد هو عملية قانونية يحل من خلالها الالتزام الجديد محل الالتزام القديم، ومنه يتم خلق التزام جديد مرتبط بانقضاء الالتزام القديم.

الفرع الثاني : استيعاب آلية التفاوض للتكييف القانوني لجائحة كورونا

يأخذ شرط إعادة التفاوض، في الواقع، بعض ملامحه من نظرية القوة القاهرة ويأخذ بعض ملامحه الأخرى من نظرية الظروف الطارئة، ليكون بذلك تقنية عقدية مستقلة مستوعبة للتكييف القانوني لجائحة كورونا سواء بوصفها قوة قاهرة، أو بترتيب أحكام نظرية الظروف الطارئة عليها.

أولا : استيعاب إعادة التفاوض للتكييف القانوني لجائحة كورونا بوصفها قوة قاهرة

إن التقارب بين مفهومي إعادة التفاوض والقوة القاهرة، كان نتيجة تطور مفهوم القوة القاهرة من مفهوم كلاسيكي إلى مفهوم حديث أكثر مرونة، ومنه لم يعد قائما في المفهوم الحديث للقوة القاهرة الاستحالة المطلقة للتنفيذ، وما ساعد على تطور فكرة القوة القاهرة هو عدم اعتبار أحكامها من النظام العام، لذا يمكن للأطراف تنظيمها وفقا لما تتطلبه مصالحهما.

و قد ذهب القانون المدني الفرنسي الجديد إلى اعتبار القوة القاهرة حسب المادة 1218 منه، على أنها "حدث يخرج عن سيطرة المدين لم يكن من المعقول توقعه بتاريخ إبرام العقد، ولا يمكن تجنب أثاره، ويكون من شأنه أن يمنع المدين من تنفيذ بموجبه"[96]، ومن منطلق ذلك ذهبت محكمة "كولمار" بفرنسا في مارس 2020 "أن فيروس كورونا المستجد

---

[94] (P), ACCAOUI-LORFIN**, La renégociation des contrats internationaux,** Thèse pour le doctorat en droit international, Université PANTHEON-ASSAS, Paris II, 2000, p.269.

[95] (D), PHILIPPE, « **les clauses relatives au changement de circonstances, dans les contrats à longue terme »**, conseils aux praticiens et approche de droit comparé, sous la direction de DANIS PHILIPPE, éditions Bruylant, 2012. p.157.

[96] Article 1218 du code civil français : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

في حد ذاته ليس قوة قاهرة، وإنما خطر العدوى وعدم وجود لقاح، وكون المرض مميت هو ما يشكل قوة قاهرة"[97] وفي قرار[98] آخر لذات المحكمة جاء فيه أن جائحة فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الحجر والإغلاق الإداري المرافقة له تشكل قوة قاهرة، وفي حكم[99] أخر لمحكمة "دوي" بفرنسا في مارس 2020؛ جاء فيه بأن إلغاء رحلة جوية من قبل السلطات الايطالية بسبب المخاطر الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد تعتبر قوة قاهرة، ويترتب على إعمال المفهوم القانوني لحدث القوة القاهرة انتفاء مسؤولية المدين وانفساخ العقد.

ولأن الأحكام القانونية المنظمة للقوة القاهرة تتيح للأطراف الاتفاق على تنظيمها مسبقا في العقد، كونها ليست من النظام العام، فان مفهومها يؤدي إلى إيجاد حل على أساس إعادة التفاوض بين الأطراف، فاختلال التوازن الاقتصادي الناتج عن أحداث القوة القاهرة يتم توزيعه على نحو اتفاقي بين الأطراف، وبهذا يبدو الخط الفاصل بين شرط القوة القاهرة وشرط إعادة التفاوض دقيقا. لأن الهدف الرئيسي لكلا الشرطين هو السعي إلى تخفيف الضرر الذي يقع على المدين في تنفيذ العقد نتيجة للظروف التي أحاطت به وأخلت بتوازنه. غير أن التقارب بين شرط القوة القاهرة وشرط إعادة التفاوض لا يعني أنهما متساويان، وإنما الواقع التعاقدي هو الذي فرض علاقة قانونية بين الفكرتين.

و يجد شرط إعادة التفاوض بسبب حدث القوة القاهرة أساسه في إرادة الأطراف، ورغبتهم في الإبقاء على العقد، هذه الإرادة تظهر في الشروط التعاقدية التي يتضمنها العقد ، ومثالها الشرط الذي ينص على أنه " إذا استمر أثر القوة القاهرة أكثر من 120يوم، على كلا الطرفين تسوية تنفيذ العقد من خلال مفاوضات ودية، والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن ".

ثانيا : استيعاب إعادة التفاوض للتكييف القانوني لجائحة كورونا بوصفها ظرف طارئ

تفرض نظرية الظروف الطارئة، وقوع أحداث غير متوقعة تؤدي إلى اختلال التوازن العقدي، بحيث يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا يهدد المدين بخسارة فادحة، لا مستحيلا. ونظرية الظروف الطارئة كما سبقت الإشارة إليها أنها "حوادث استثنائية عامة، خارجة عن إرادة المدين، لا يمكن توقعها وقت نشوء العقد، وتطرأ عند تنفيذه فتجعله مرهقا للمدين لا مستحيلا، تهدده بخسارة فادحة".

مما تقدم، يظهر جليا توفر شروط نظرية الظروف الطارئة على جائحة فيروس كورونا، ومجالها الخصب هو العقود الطويلة المستمرة التنفيذ كعقود التوريد والإنشاءات وغيرها ،

[97] Cour d'appel de Colmar, chambre n° 06, 12mars 2020, n° 20/01098.
[98] Cour d'appel de Colmar, 23 Mars 2020, n°20/01206, n°20/01207
[99] Douai, 4 Mars 2020, n° 20/00395

فتجعل تداعيات الجائحة العقد مرهقا لا مستحيلا، ويترتب عن كون جائحة فيروس كورونا ظرف طارئ؛ هو مراجعة العقد وتحمل الطرفان أثارها، سواء بإنقاص التزام المتعاقد الذي أصابه الضرر أو بزيادة التزامات الطرف الأخر. وعليه تسمح نظرية الظروف الطارئة لأطراف العقد بالتفاوض وديا أو قضائيا ومراجعة العقد أو إنهائه، غير أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يخلق صعوبات كبيرة، لأنه مراجعة العقد نتيجة للظروف الطارئة تعطى للقضاء- وأن أحكام النظرية من النظام العام لا يجوز مخالفتها من قبل أطراف العقد وهو ما يشكل مساس بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، خاصة إذا تم النص في العقد على تنفيذ أحكامه وفقا لما تم الإتفاق عليه أثناء التعاقد، لذلك تقوم القوة الملزمة للعقد مقام القانون في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، ومن ثم فلا يجوز تعديله ولا نقضه إلا بإرادة الأطراف.

وتبعا لذلك فإن الترابط بين إعادة التفاوض ونظرية الظروف الطارئة يجد أساسه في درجة تأثير كل منهما على توازن العقد الذي يرتب اختلال في التوازن بين أداء العقد على نحو يلحق ضررا جسيما بأحد أطراف العقد أو بكليهما.

إن أهمية إعادة التفاوض كتقنية تعاقدية مرنة قد أبانت عن فاعليتها في مواجهة تغير الظروف في العقود المدنية، مما جعل التشريعات الوطنية تتبناها في تعديلاتها، فقد وجدت تقنية إعادة التفاوض تطبيقها في تعديل التشريع المدني الفرنسي لسنة 2016، وما ساعد في تبني إعادة التفاوض في التشريع المدني الفرنسي هو أن هذا الأخير لم تنظم أحكامه تقنية مزاحمة لإعادة التفاوض تعالج مشكلة تغير ظروف تنفيذ العقد، لذلك ألقت قبولا خصوصا في ظل بروز الحاجة إلى تبني آلية لمعالجة تغير الظروف وتهذيب مبدأ القوة الملزمة للعقد، وقد جاء في نص المادة 1195 من القانون المدني الفرنسي الجديد على أنه إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام العقد جعلت من تنفيذه مرهقا بشكل حاد بالنسبة لأحد طرفيه، فلهذا الأخير الذي لا يقبل تحمل هذه المخاطر، الحق في أن يطالب بإعادة مناقشة بنود العقد مع المتعاقد الأخر، بذات الوقت الذي يستمر فيه في تنفيذ التزاماته خلال هذه المرحلة، وفي حال رفض المتعاقد الأخر أو فشل هذه المفاوضات، فيمكن لأطراف العقد أن يقوموا بفسخ العقد وفق الشروط والمدة التي يتفقون عليها، أو أن يطلبوا بموجب اتفاق مشترك من القاضي المباشرة في إعادة تحديث العقد مع الظروف المستجدة، بخلاف ذلك، يمكن لأحد الأطراف أن يضع نهاية لهذا العقد، بالتاريخ والشروط التي يحددها القاضي.[100]

[100] Article **1195** Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 : Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation.
A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y

و تنبغي الإشارة إلى أنه قبل تعديل القانون المدني الفرنسي سنة 2016 وتبني فكرة إعادة التفاوض كآلية لمراجعة العقد المتأثر بتغير الظروف؛ ظهرت بعض المرونة في قرارات المحاكم الفرنسية تجاه المدين المتضرر بتغير الظروف، حيث ركز الفقه في تتبع فكرة إعادة التفاوض في القضاء الفرنسي إلى ثلاثة أحكام، أبانت عن مرونة القضاء في التعامل مع فكرة إعادة التفاوض، الحكم الأول صدر عن الغرفة التجارية لمحكمة النقض في قضية Huard سنة 1992 حين اعتبرت المحكمة أن الالتزام بحسن نية يجب أن يقود الأطراف إلى ملائمة العقد مع الظروف الاقتصادية الجديدة. أما الحكم الثاني فصدر سنة 1998؛ أقرت فيه الغرفة التجارية المسؤولية القانونية لعدم التفاوض، ليأتي القرار الثالث كأهم القرارات القضائية التي عالجت فكرة إعادة التفاوض كآلية لمواجهة تغير الظروف، صدر هذا القرار في 16 مارس 2004 عن محكمة النقض الفرنسية، بحيث تضمن القرار المسؤولية القانونية لعدم إعادة التفاوض، مع تحديد نطاقه بالأحداث غير المتوقعة التي تحدث بعد إبرام العقد وتؤدي إلى إرهاق في التنفيذ لأحد طرفيه،وهو ما تم تأكيده في قرار آخر لذات المحكمة بتاريخ 29 يونيو 2010.[101]

mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

[101] بن دريس حليمة، **إعادة التفاوض تقنية تعاقدية مرنة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية؛ فأي إمكانية لتنظيمه في القوانين الوطنية**، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 2020، ص 17.

خاتمة

خاتمة

وهكذا فإننا نكون قد انتهينا من بحثنا بفضل الله وتوفيقه حول **التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه - جائحة كورونا نموذجا-** ، حيث تناولنا في البداية الحديث عن مفهوم المسؤولية و تطورها عبر العصور، ثم تم تقسيم البحث إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية، أوضحنا من خلاله مفهوم التعويض عن الضرر و عناصره، إضافة إلى أنواعه و شروط استحقاقه، ثم أتممنا الحديث عن كيفية التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام، حيث أشرنا إلى تدير التعويض و الضرر الواجب تعويضه عند تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

أما الفصل الثاني فكان مخصصا لتأثير جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وتناولنا من خلاله بيان أثر الجائحة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وذلك بالحديث المفصل عن نظرتي القوة القاهرة و الظروف الطارئة، كما تناولنا ضوابط سلطة القاضي في تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد ومدى هذه السلطة في تحقيق هذا التوازن، و أهم ما توصل إليه الفقه من بدائل مستحدثة للتعويض عن التأخير.

فمن خلال ما تم دراسته من أحكام تتعلق بالتعويض الذي يستحقه الدائن في حال تأخر المدين في تنفيذ التزامه، واعتمادًا على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالوقوف عند النصوص القانونية ذات العلاقة بهذا النوع من التعويض وتحليلها بالاستعانة بالمراجع الفقهية، وبمقارنتها مع غيرها من نصوص قانونية، توصنا إلى العديد من النتائج المرتبطة بهذا الموضوع، وهي:

1. إن تأخر المدين في تنفيذ التزامه، يمكن وضعه في موضعين ضمن الأحكام الخاصة بالتعويض في إطار المسؤولية العقدية، فالموضع الأول له، أنه يمثل أحد صور الخطأ العقدي، والموضع الثاني، أنه يصنف ضمن حالات استحقاق التعويض.

2. بعد دراستنا لأحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية ، نقول أن المشرع المغربي أولى عناية بالغة لهذا الموضوع، من خلال نصوص المواد من 77 إلى 264 من القانون المدني .فالعقد يعتبر كالقانون فيما بين المتعاقدين فيما يتعلق بقوته الإلزامية، فلا يستطيع المتعاقد أن يتحلل من قيوده بإرادته المنفردة، كما لا يمكنه أن يدخل تعديلات على بنوده أيا كان نوعها أو أهميتها، ويسري هذا الحكم أيضا على القاضي، فلا يجوز له المساس بمضمون العقد.

3. والتعويض هو حق يثبت للدائن في مواجهة المدين عند تحقق أركان المسؤولية، ويراعى في تقديره ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، وقد يأخذ التعويض صورة نقدية أو أي ترضية أخرى مساوية للمنفعة التي كان سينالها الدائن لو لم يتم الإخلال بالالتزام. ويشترط لاستحقاق التعويض توافر جملة من الشروط الموضوعية المتعلقة بأركان المسؤولية العقدية من خطأ عقدي وضرر وعلاقة سببية، وكذا لا بد من توافر الشروط الشكلية وهي الاعذار وعدم وجود اتفاق مسبق على الإعفاء من المسؤولية العقدية.

4. إن افتراض الضرر باعتباره أحد شروط استحقاق التعويض عن التأخير في أداء مبلغ من المال، افتراضًا غير قابل لإثبات العكس، يمثل خروجًا عن القواعد العامة للمسؤولية العقدية، التي تشترط لاستحقاق التعويض وقوع الضرر وإثباته، وأن ما قيل في تبرير ذلك من يتعامل مع الاحتمالات على أنها حقائق، فإذا تأخر المدين في الوفاء بدينه قد يلحق بالدائن ضرر وقد لا يلحق، فهذا أمر احتمالي، ويجعل التعويض في الحالات التي لا يصيب فيها الدائن ضرر أو يصيبه ضرر أقل من الفائدة القانونية، قد أثرى بلا سبب، وفي حال زيادة الضرر عن قيمة التعويض، فإن الدائن في هذه الحالة لا يحصل على التعويض الذي يستحقه.

5. الأصل أن القاضي هو الذي يقدر التعويض بناء على سلطته التقديرية، غير أن التعويض قد يكون محددا مسبقا إما بنص قانوني، أو باتفاق بين الأطراف في صورة شرط جزائي، هذا الأخير الذي يأتي إما في العقد الأصلي أو في اتفاق لاحق. غير أن السلطة الممنوحة للقاضي في تقدير التعويض ليست سلطة مطلقة، بل أنها مقيدة بمجموعة من القيود التي يجب على القاضي مراعاتها عند إصدار حكمه بالتعويض، هذه القيود منها ما يتعلق بطلبات الخصوم، ومنها ما يتعلق بالتعويض المحدد قانونا، وكذا حالة الخطأ المشترك، والتقدير الاتفاقي للتعويض. فلا يمكن للقاضي أن يحكم بغير ما طلبه الخصوم، ولا يجوز له مخالفة ما ورد في القانون من تقدير للتعويض، كما لا يمكنه مخالفة ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف من خلال تحديدهم للشرط الجزائي.

6. لما كانت الغاية من التعويض جبر الضرر قدر الإمكان، فإننا لا يمكن أن نتصور تحققها إلا إذا روعي عند تقدير التعويض وقت إصدار الحكم، ذلك لو تم تقديره في يوم وقوع الضرر أو أي وقت آخر، غير يوم إصدار الحكم، فان ذلك يؤدي إلى أن يتحمل الطرف المتضرر" الدائن" الفرق في قيمة الضرر خلال مدة الدعوى، فيكون من مصلحة محدث الضرر" المدين" إطالة أمد النزاع إلى أقصى مدة ممكنة، أما لو قدر

التعويض وقت صدور الحكم فان محدث الضرر وحده هو الذي يتحمل التغير في قيمة الضرر.

7. نجد أن كل التشريعات اعتبرت الضرر شرطا أساسيا لاستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية، لكننا نقول أنه في رأينا لا يمكن منح التعويض في المسؤولية العقدية بناء على ما لحق المدين من ضرر، ذلك أن العلاقة التي تربط الطرفين هي علاقة عقدية، واستحقاق التعويض يكون نتيجة الإخلال بهذه العلاقة دون انتظار ما قد يلحق المدين من ضرر، وهذا تطبيقا لقاعدة القوة الملزمة للعقد، وحمل الأفراد على احترام ما يبرمونه من عقود، فكان الأجدر بالمشرع المغربي أن يستبعد الضرر كشرط لاستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية، وبالتالي استبعاده كركن لقيام المسؤولية العقدية وذلك تمييزا لها عن المسؤولية التقصيرية، فبالرغم من وحدة المسؤولية إلا انه تبقى المسؤولية العقدية ناتجة عن الإخلال بالتزام عقدي الذي يوجب القانون احترامه وتنفيذه حسب ما تم الاتفاق عليه.

8. لقد تبين لنا أهمية احترام مبدأ سلطان الإرادة، وأن التدخل الممكن حصوله يلزم أن يبقى استثناء يتم تفعيله بأضيق الأحوال، فالفقه فضلا عن القوانين بين كيف يتم خرق مبدأ سلطان الإرادة بنظريتي القوة القاهرة والظرف الطارئ، حيث إن الجائحة هي من أهم مسبباتهما.

9. هذه الجائحة قد تكون حدثا يحصل وينتهي لتبقى آثاره كما في حالة فيضان أو زلزال، أما الجائحة طويلة الأمد، ويمكننا أن نسميها الجائحة الزمنية، كوباء كورونا، فلا يعلم مدة انتهائها، فقد تنتهي في أيام قليلة وقد تمتد لأشهر طويلة، فالنوع الأول يحصل فوراً وينتهي لتبقى آثاره، فتطبيق نظريتي القوة القاهرة أو الظرف الطارئ والحدود الفاصلة بينهما أكثر وضوحاً، فمثلاً حصول فيضان في مكان ما أو زلزال يجعل العقود التي يصعب تطبيقها منفسخة بالقوة القاهرة والتي في تنفيذها إرهاق، تطبق نظرية الظروف الطارئة، أما لو كانت الجائحة زمنية، فإن تداخل نظريتي القوة القاهرة والظرف الطارئ تبعا لمدة العقد يكون أكثر توقعاً، مما يجعل القضاة أكثر اختلافاً في تطبيقهما حسب الجائحة وتأثيرها على العقد وفقاً لمعايير متعددة، فالأمر مرتبط بنوع العقد هل هو فوري أو زمني، فالعقود الفورية من المفترض عدم تطبيقهما – القوة القاهرة والظرف الطارئ- عليها إلا في حالة تأخر التنفيذ عن تاريخ إبرام العقد، وحتى في العقود الزمنية قد يكون عقد توريد على سبيل المثال منفسخا كون أن مدة تنفيذه حصلت خلال حصول الجائحة، في حين عقد توريد آخر قد يمتد لمدة أطول، فالأول يمكن تطبيق نظرية القوة القاهرة عليه، في حين الثاني تطبق عليه نظرية الظرف الطارئ.

10. إن الآثار التي تترتب على الجائحة تقاس وفق معايير موضوعية ترتبط في غالب الأحيان بالجانب الاقتصادي للعقد، الذي يختل بوجود الجائحة ليمنح القاضي سلطة رفع الإرهاق عن المدين بعد مطالبة الأخير لذلك، إن لم يحكم بالأساس بفسخ العقد وفقاً للقوة القاهرة.

11. أن نظرية الظروف الطارئة تطبق في الحالات التي يكون فيها تنفيذ الالتزام مرهقا بالمدين، ويكون الجزاء هو رد ذلك الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وذلك بتوزيع الخسارة على الطرفين سواء بإنقاص الالتزام المرهق أو زيادة الالتزام المقابل أو وقف التنفيذ العقد إن كان يرجى زوال أثر الظروف الطارئة في وقت لا يضر معه الوقف بحقوق الطرفين، ولكن لا يقضى القاضي بفسخ التعاقد، وهذا الفرق بينه وبين نظرية القوة القاهرة التي يكون فيها تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا ومن ثم فإن الجزاء يكون فيها فسخ العقد وانقضاء الالتزام.

12. أن المشرع حينما قرر منح القاضي سلطة تعديل العقد خروجا عن المبدأ العام"العقد شريعة المتعاقدين" في حالة الظروف الطارئة، لم يترك هذه السلطة مطلقة بلا قيود، حيث وضع ضوابط يلتزم القاضي بم مراعاتها عند إجراء تعديل للالتزامات الأطراف وتوزيع الإرهاق بين الطرفين، وتتمثل هذه الضوابط في مراعاة القاضي للظروف المحيطة، والموازنة بين مصلحة الطرفين، ورد الالتزام المرهق للحد المعقول.

13. تستوعب آلية إعادة التفاوض كبديل مستحدث للتعويض عن التأخير، التكييف القانوني لجائحة فيروس كورونا سواء بوصفها قوة قاهرة أو ظرف طارئ يؤثر على تنفيذ العقد، هذا الاستيعاب يأتي من درجة التوافق بين فكرة إعادة التفاوض والقوة القاهرة من حيث الشروط الواجب توفرها في الحدث ومن حيث الغاية التي تحققها القوة القاهرة بمفهومها الحديث، أما نظرية الظروف الطارئة فتظهر درجة التأثير في كل منهما على توازن العقد ، إذا يؤثر الحدث المشكل لكل منهما على توازن العقد على نحو يؤدي إلى الإرهاق في التنفيذ لأحد الطرفين.

14. يترتب على إعمال آلية إعادة التفاوض نتيجة تأثير حدث جائحة فيروس كورونا المستجد، وقف العقد، والالتزام بإعادة التفاوض بحسن نية وتفترض هذه الأخيرة إتيان المتعاقدين كل مسلك من شأنه الإبقاء على العقد.

15. أبانت تقنية إعادة التفاوض قصور الحلول القانونية التي ينظمها القانون المدني في معالجة مشكلة تغير ظروف تنفيذ العقد، على اعتبار أن الجانب الاقتصادي هو ما يوجه السلوك التعاقدي والقانوني للمتعاقدين، ومنه فإن تقنية إعادة التفاوض تعتبر الخيار الأمثل في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على تنفيذ العقد.

16. على التشريعات الوطنية أن تهتم بالجوانب الاقتصادية للعقد في ظل تعاظم هذا الجانب في ظل العولمة الاقتصادية، وأن إعادة التفاوض هي الخيار الأمثل لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على العقود، كما أن هذه التقنية تحقق أمن واستقرار المعاملات في ظل التغيرات التي يعرفها العالم، و هو ما يؤدي إلى ضرورة التخفيف من حدة النظام العام الوارد في أحكام نظرية الظروف الطارئة، ومنح إمكانية مراجعة العقد بين عاقديه تحت رقابة القضاء.

وفي الختام فهذه النتائج التي توصلنا إليها، بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد ،هو عمل بشري عرضة للخطأ والنسيان.

وأخيرا؛ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

.....ومن الله التوفيق.....

لائحة المصادر و المراجع

لائحة المصادر و المراجع

أولا : القرآن الكريم

سورة المائدة - الآية رقم 1 و 45 .

سورة البقرة - الآية 280.

ثانيا : المراجع باللغة العربية

1- المراجع العامة

- إدريس العلوي العبدلاوي ،**النظرية العامة للالتزام** ، **نظرية العقد** ،الجزء الأول مطبعة النجاح الجديدة ، طبعة الأولى ، 1996.
- سليمان مقرس :
  - **الوافي في شرح القانون المدني**، الجزء الثاني، **الفعل الضار والمسؤولية العقدية**، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، 1957.
  - **الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات**، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، الطبعة الرابعة، 1987.
- عبد الرزاق السنهوري :
  - **الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، مصادر الالتزام**، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، 1952.
  - **الوسيط في شرح القانون المدني الجديد** ، الجزء الخامس، **العقود التي تقع على الملكية (الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح)**
  - **مصادر الحق في الفقه الإسلامي**، الجزء السادس، دار إحياء التراث العربي.
- عبد القادر العرعاري، **شرح قانون الالتزامات و العقود**، الطبعة الثانية، 2010.

- عبد الرحمان الشرقاوي :
  - **القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، مصادر الالتزام**، الجزء الأول، التصرف القانونين العقد، و الإرادة المنفردة، الطبعة السادسة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2019
  - **دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي**، طبعة الأولى، الرباط، 2002.

- عبد الحق صافي، **الوجيز في القانون المدني، الجزء الأول، المصادر الإرادية للالتزام (العقد و الإرادة المنفردة) دراسة في ق.ل.ع و في القوانين الأخرى**، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2020.
- مأمون الكزبري :
  - **نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي** ،الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة الثانية 1979.
  - **النظرية العامة للالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي**، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام و انتقاله و انقضاؤه، بيروت 1967.
- منذر الفضل :
  - **النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام**، الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان 1996.
  - **النظرية العامة لالتزامات،أحكام الالتزام**، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، طبعة 1998.
- موريس نخله، **الكامل في شرح القانون المدني**، -دراسة مقارنة- الجزء الثالث، منشورات الحلبي القانونية، لبنان 2007.
- حسن علي الذنون، **النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام**،طبعة 1976.

2- المراجع الخاصة و الأطروحات الجامعية

- أشواق الدهيمي، **أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية**، الجزائر، 2013.
- أبي حامد الغزالي، **الوجيز في فقه الإمام الشافعي**، الجزء الأول، دار المعرفة، بيروت، 1979.
- بن دريس حليمة، **إعادة التفاوض تقنية تعاقدية مرنة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية؛ فأي إمكانية لتنظيمه في القوانين الوطنية**، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 2020.
- جلال مصطفى السعيد، **الأحكام العامة لقانون العقوبات الجديد**، الطبعة الرابعة، دار المعارف، مصر، 1962.
- وهبة الزحيلي، **نظرية الضمان في الفقه الإسلامي**، دار الفكر دمشق، 1970.
- مصطفى محمد الجمال، **ضمانات التعويض في ظل تطور المسؤولية العقدية**، 1985.
- سلمان بن صالح،**التعويض عن الأضرار المترتبة عن المماطلة في الديون**، بيروت، 2005.
- محمد الكشبور، **نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة**، الطبعة الأولى 1993.
- حسين عامر وعبد الرحيم عامر، **المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية** ، مطبعة دار المعارف القاهرة، الطبعة الثانية 1989.
- محسن عبد الحميد، **اختلال التوازن الاقتصادي للعقد من خلال نظريتا القوة القاهرة و الظروف الطارئة**، 2020.
- الإمام أبي بكر أحمد البيهقي، **السنن الكبرى**، الجزء السابع، الطبعة الثالثة، دار الكتب العالمية، بيروت، 2003.
- مرزوق ايت الحاج، **محاضرات في المسؤولية المدنية**، مطبعة فولك، طنجة، 2018
- محمد السيد عمران، **حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، دراسة مقارنة**، منشأة المعارف الإسكندرية، جمهورية مصر، 1986.
- شريف محمد غنام، **أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية**، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،2007.

- أحمد شكري السباعي، **نظرية القوة القاهرة في التشريع المغربي**، طبعة 2006، الدار البيضاء.
- عز الدين الديناصوري، **ضمانات التعويض في ظل تطور مفهوم المسؤولية المدنية**، الجزائر، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون الخاص، كلية الحوق، جامعة الشرق الأوسط، 2010.
- فاطمة أوسحاق ،**آثار القوة القاهرة على الالتزام العقدي في القانون المغربي والمقارن** ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق عين الشق ،السنة الجامعية 2006/2005.
- عبد الوهاب محمد عبد الوهاب العطار، **الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ الالتزام التعاقدي - دراسة تحليلية -** بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القانون، كلية القانون جامعة الخرطوم السودان، 2005/2004.
- نهاد أخزان، **دور التشريع و القضاء في تحقيق التوازن العقدي**، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون المدني و الأعمال، طنجة، 2020/2019.
- محمد شليح، **سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي، أسسه ومظاهره في نظرية العقد**، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،1983، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بالرباط.

3- المقالات

- لبنى الغومرتي، **تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل الجائحة الزمنية "فيروس كورونا المستجد كوفيد 19" نموذجا**، مجلة عدالة للدراسات القانونية و القضائية، عدد 13/ السنة الرابعة 2021.
- حمزة بنخدة، **قراءة في أهم مستجدات الإصلاح الجذري للقانون المدني الفرنسي لسنة 2016.**
- خالد بني أحمد ، **الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة ، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي** ، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ، العدد 2، 2006.
- سعيد أحمد شعلة، **قضاء النقض المدني في المسؤولية و التعويض، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض خلال اثنين و سبعين**

سنة من 1931 إلى 2002 ، طبعة 2003، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية.

- ياسر عبد الحميد الإفتيحات، **جائحة فيروس كورونا وأثرها على تنفيذ الالتزامات العقدية،** مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة الثامنة - ملحق خاص – العدد 6 –شوال 1441هـ – يونيو 2020م.
- **آثار جائحة كوفيد 19 على المنظومة القانونية،** العدد الرابع من مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، الطبعة :الأولى 2020، الرباط :
  - محمد بن يعيش، **كوفيد 19 و أثره على الالتزامات التعاقدية؛**
  - المصطفى الغشام الشعيبي، **التكييف القانوني لحالة الطوارئ الصحية بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة؛**
  - مروان بوسيف، **وجهة نظر حول إفراغ المكتري من المحل السكني في زمن جائحة كورونا؛**
  - خليل اللواح ،**حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بين الشرعية والمشروعية.**

4- القوانين

- القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات و الخدمات و بتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.140 الصادر في 16 رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5980 الصادرة في 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)؛ ص 4678.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدني.
- الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود.
- قرار رقم 20310 مؤرخ في 1983/03/02 ، نشرة القضاة 1987، عدد 01.

ثالثا : المراجع باللغة الفرنسية

1- المراجع و المقالات

- Savatier: **Traite de la responsabilité civile en droit Français**, tome 2, deuxième Edition, Paris, 1951.
- Ripert (G.) et Boulanger**: Traite élémentaire de droit civil de Planiol,** tome 2, 4 Edition, 1952,.
- Lucienne Ripert**: La réparation du préjudice dans la responsabilité délictuelle,** thèse, Paris, 1933**.**
- RAYNAUD**: Cours de droit civil, polycopié, Paris, année 1961-1962.**
- Carbonnier J., **Les obligations, droit civil,** Tome IV**,** PUF, Thémis**,** 1994, n°162.
- Noguéro D., **La maladie du débiteur cas de force majeure:** D. 2006.
- Mayaud Y., **Le malaise brutal et imprévisible, cas de force majeure pour l'auteur d'un accident de la circulation,** obs. sous C. cass. crim. 15 Nov. 2005, RSC 2006.
- Nocquet P., **L'interdiction de la cession de l'officine et la force majeure**, Bulletin de l'ordre 378, 2003.
- Kaoutar sajid, **MAROC : l'exécution du contrat à l'épreuve du COVID 19,** 20 juillet 2020.
- Clément diaz – avocat droit immobilier au barreau de Nice, **Le Covid 19 constitue-t-il un cas de force majeure pouvant justifier l'inexécution d'une obligation contractuelle,** 2021.
- Aurelien Bauote, **la responsabilité contractuelle : régime juridique**, 19 novembre 2019.
- Jean Louis Baudouin (ancien juge à la cours d'appel du Québec) et Patrice Duslaure (professeur à la faculté de droit Université MONTREAL et avocat) **, La responsabilité contractuelle civile**, 22 juillet 2020.
- Clément François (SORBONNE), **la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat.**

- Stanilas Dwerncki et Etienne Chesneau et Yannick Graiyon, **Covid-19 Quel avenir pour la force obligatoire du contrat ?**, 30 décembre 2020.
- (D), PHILIPPE***, « les clauses relatives au changement de circonstances, dans les contrats à longue terme »,*** conseils aux praticiens et approche de droit comparé, sous la direction de DANIS PHILIPPE, éditions Bruylant, 2012.
- (P), ACCAOUI-LORFIN**, La renégociation des contrats internationaux,** Thèse pour le doctorat en droit international, Université PANTHEON-ASSAS, Paris II, 2000.

2- القرارات و الأحكام القضائية

- **Code civil français, dernière modification: 2020-09-01, Edition 2020-09-26, Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 -art. 2 .**
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, Chambre 3, Arrêt du 29 Mars 2016, Répertoire général nº 15/05607.
- Cass. Ass. Plén. 14 Avril 2006, Recueil Dalloz, 2006, n° 23, Note Jourdain
- Cour d'appel Montpellier, 2e ch. 16 Novembre 1932, Jurisprudence, Gaz.pal., 1933, 1e sem.
- Cour de cassation : 3éme chambre civile arrêt n° 16-19426 (14 septembre 2017).
- Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt, n° 13-20306 (16 septembre 2014).
- Cour d'appel de Colmar, chambre n° 06, 12mars 2020, n° 20/01098.
- Cour d'appel de Colmar, 23 Mars 2020, n°20/01206, n°20/01207

رابعا : المراجع باللغة الانجليزية

- Peter, Lauren, Philip Charlton, **Managing contractual obligations and negotiation during the Covid-19,** Australia, 2020.
- David Nia and Nathan Catania, **Force Majeure : Not your get out of jail free card,** Malta, August 30,2020.
- Nilava and Adhip Kumar Ray, **Force majeure : How successful has the law been post covid in India,** April 24,2021.
- Dominic Hopkins, Simon Biggin, Stewart Morrison, **Covid-19 : Non performance or delayed performance of contractual obligations – What's in the legal toolbox?,** March 18,2020.
- Martin Janku, **Contractual penalty and the right to payment for delays caused by force majeure in Czech civil law under the new civil code.**
- John Stannard, **Delay in the performance of contractual obligations** (2nd edition).

فهرس المحتويات

المحتوى	الصفحة
الإهداء	2
الشكر و التقدير	3
مقدمة	4
الفصل الأول : أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية	13
المبحث الأول : التعويض عن الضرر المترتب عن المماطلة في الديون	14
المطلب الأول : مفهوم التعويض عن الضرر و عناصره	14
الفرع الأول : تعريف التعويض و تمييزه عن النظم المشابهة	14
أولا : تعريف التعويض	14
ثانيا : تمييز التعويض عن النظم المشابهة	17
الفرع الثاني : عناصر التعويض عن الضرر	23
أولا : ما لحق الدائن من خسارة	23
ثانيا : ما فات الدائن من كسب	24
المطلب الثاني : أنواع التعويض و شروط استحقاقه	25
الفرع الأول : أنواع التعويض	25
أولا : التعويض العيني	26
ثانيا : التعويض بمقابل	29
الفرع الثاني : شروط استحقاق التعويض	31
أولا : الشروط الموضوعية لاستحقاق التعويض	31
ثانيا : الشروط الشكلية لاستحقاق التعويض	37
المبحث الثاني : كيفية التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام	41
المطلب الأول : تقدير التعويض عن الضرر بوجه عام	41
الفرع الأول : التقدير الاتفاقي	41
أولا : مفهوم الشرط الجزائي	42
ثانيا : الطبيعة القانونية للشرط الجزائي	44
الفرع الثاني : التقدير القانوني (الفائدة القانونية) و القضائي	50
أولا : التقدير القانوني للتعويض	50
ثانيا : التقدير القضائي للتعويض	53

المطلب الثاني : الضرر الواجب التعويض عند تأخر المدين في تنفيذ التزامه	58
الفرع الأول : التعويض عن الضرر المادي	58
الفرع الثاني : التعويض عن الضرر المعنوي	61
الفصل الثاني : تأثير جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية	64
المبحث الأول : الجائحة و أثرها على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين	65
المطلب الأول : نظرية الظروف الطارئة	65
الفرع الأول : مفهوم نظرية الظروف الطارئة	65
الفرع الثاني : تأثير نظرية الظروف الطارئة على مبدأ سلطان الإرادة	74
المطلب الثاني : نظرية القوة القاهرة	76
الفرع الأول : الأساس القانوني للقوة القاهرة	76
الفرع الثاني : تكييف الجائحة بالقوة القاهرة	82
المبحث الثاني : تكييف الجائحة بالقياس على ظروف المتعاقدين	86
المطلب الأول : إعادة حالة التوازن في العلاقة القائمة بين الدائن و المدين	86
الفرع الأول : دور التشريع في تحقيق التوازن العقدي	87
الفرع الثاني : التدخل القضائي لإعادة حالة التوازن العقدي	90
المطلب الثاني : البديل المستحدث للتعويض عن التأخير	94
الفرع الأول : مضمون تقنية إعادة التفاوض	95
أولا : وقف تنفيذ العقد	97
ثانيا : الالتزام بإعادة التفاوض	98
الفرع الثاني : استيعاب آلية التفاوض للتكييف القانوني لجائحة كورونا	99
أولا : استيعاب آلية التفاوض للتكييف القانوني لجائحة كورونا بوصفها قوة قاهرة	99
ثانيا : استيعاب آلية التفاوض للتكييف القانوني لجائحة كورونا وصفها ظرف طارئ	100
خاتمة	103
لائحة المصادر و المراجع	109
فهرس المحتويات	118